



Elementi di diritto commerciale nell'era digitale

Punti principali da sapere prima di iniziare

- **Capacità giuridica** → attitudine di essere titolari di diritti e doveri, si acquisisce con la nascita e si perde con la morte.
- **Diritto** (assoluto e relativo) → anche i diritti assoluti sono coperti dall'art.2043 (es. danno all'immagine).
- **Fonte delle obbligazioni** → art.1773, contratto, legge.
- **Fatto illecito** → Codice Civile art.2043.
- **Responsabilità patrimoniale** → (art.2740 Codice Civile) il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (es. ipoteca: diritto reale di garanzia).
- **Responsabilità civile** → obbligazione risarcitoria (da fatto illecito).
- **Diritti di proprietà**
- ▼ **Fonti dell'obbligazione:**
 - Contratto
 - Legge

- Fatti illeciti (art. 2043)
- Responsabilità patrimoniale (art. 2640 cc. → responsabilità civile/patrimoniale)
- Diritti di proprietà (fisica/materiale/intellettuale)

Diritto commerciale



Di cosa si occupa?

- Disciplina dei soggetti
- Disciplina delle attività
- Disciplina dei mercati

Codice Civile → diviso in cinque libri, di cui l'ultimo si occupa delle regole del diritto commerciale

Prospettiva storica e introduzione

Ne guardiamo la prospettiva storica, perché il diritto privato, studiato precedentemente, deriva dall'Impero Romano. In una fase intermedia, poi, è avvenuta una procedura di ibridazione che si è conclusa con la codificazione del diritto privato, libri contenenti le regole del diritto allo scopo di fissare il diritto dei privati, durante/nel sistema della Rivoluzione francese (la legge è uguale per tutti). Recupera in tante parti il diritto romano di 1500 anni prima. Il diritto privato lo troviamo nel nostro codice civile, diviso in libri, escluso il 5 dedicato al lavoro e regole del diritto commerciale.

Il **diritto commerciale** nasce dopo la caduta dell'impero Romano, con il commercio curtense, un sistema nel quale l'economia era **autarchica**. L'idea della chiusura dei campi, dovuta all'insicurezza delle conseguenze della caduta dell'impero romano d'occidente segna il periodo più oscuro, in cui l'economia e gli agglomerati si chiudono. Poi si passa al ceto dei **commercianti**, coloro che non avevano niente da perdere e per tal motivo non avevano paura di rischiare, prendendo il sovrappiù e vendendolo altrove con i rischi del viaggio e di venderlo in terre sconosciute, al contrario dei più ricchi che avevano un patrimonio da proteggere. È in tale clima che è nato il ceto dei commercianti, arricchitosi molto velocemente attraverso il **viaggio**.

Il diritto privato romanistico già esistente era per i latifondisti e non andava bene per i commercianti, che non avevano né terra né la necessità di conservarla, avevano bisogno di regole atte a regolare il loro commercio, che ovviamente mancavano. I commercianti si concentravano sui **comuni**, atti a ricevere le piazze dei mercati, al centro delle mappe dei paesi in formazione. Inizia così una **specializzazione dei beni** grazie alla moltitudine di mercanti provenienti da altri centri o luoghi di commercio.

Dove c'è un mercato ci sono dei problemi dal punto di vista giuridico (es furto, ovvero della vendita di matene rubate) e c'è bisogno di **sicurezza di acquisto**, c'è bisogno della protezione dell'acquirente, ma il diritto privato e il diritto privato romano, non contengono tale regola. L'unica regola a riguardo, attribuisce al proprietario la possibilità di recuperare l'oggetto da chiunque se ne sia appropriato, a prescindere dalla buona o cattiva fede. Dunque nelle piazze di mercato si sviluppa una regola nuova, **possesso vale titolo se il titolo è in buona fede**, quindi con l'acquisto di un bene mobile, sulla base di un contratto astrattamente valido, si acquista di fatto anche la proprietà di tale bene (anche se appartenente a un furto).



La regola nell'**art. 1153 c.c** è una regola secondo la quale quando si compra un bene mobile in buona fede sulla base di un contratto, si acquista la proprietà, anche se chi lo vende non ne è l'effettivo proprietario.

I commercianti si arricchiscono in fretta e iniziano a strutturarsi delle corporazioni, cioè dei club nei quali vi sono coloro che hanno certe qualifiche e ai quali è attribuita una certa attività. Si dotano di un certo meccanismo che si forma per consuetudine. Ad esempio essi inventano le lettere di cambio, che verranno poi convertite in monete, per non essere derubati durante i viaggi e per poter viaggiare leggeri.

Dunque, il diritto commerciale è un diritto consuetudinario, ancora adesso si cercano sempre nuovi metodi.

Il diritto commerciale, quindi, si sviluppa per regolare il mercato e prende piede attraverso corporazione (club all'interno del quale possono rientrare solo alcune persone qualificate e di una certa categoria). Per tale motivo si sviluppa lo **IUS MERCATO**, una sperimentazione di regole che i mercanti trovano funzionali alla risoluzione delle controversie. I mercanti crearono anche un **sistema giuridico delle lettere di cambio**, ovvero la conversione di monete in carta per evitare di viaggiare

leggeri e convertire le monete più facilmente, questi sono gli antenati delle banconote.

Si può fare un paragone con i sistemi di pagamento odierni, quali Satispay o Bitcoin

Ad un certo punto, si formano gli Stati assoluti, con i loro sovrani che cercano di prendersi tutto il potere, e quindi le regole le faceva lui e non i mercanti. Durante l'epoca di Luigi XIV si passa alla fase del **diritto codificato**. Si iniziano dunque a codificare le regole stabilite dai mercanti, solo che ciò non lo definisce più un diritto di consuetudine piuttosto un diritto del sovrano.

Sotto Napoleone vengono scritti un codice civile (regole tra privati non commercianti) e un codice commerciale (norme che si applicano agli atti di commercio → rapporti tra commercianti). La stessa cosa accade in Italia, con la repubblica cisalpina, Napoleone porta i codici tradotti in italiano.

La situazione cambia nel periodo fascista, poiché nel 1942 viene scritto un unico codice civile (quello attuale) → un codice innovativo, poiché segna il superamento della distinzione tra i due precedenti. Questo nuovo codice è una vera e propria ibridazione, questo perché corrisponde all'ideologia fascista che voleva la coesistenza tra imprenditori, lavoratori ecc..

Il **diritto consuetudinario** mette le basi per il futuro codice di commercio nell'era di Napoleone, quando viene messo per iscritto un codice civile, al quale viene inserito anche un codice commerciale che riprende le regole riguardanti rapporti tra commercianti e non. (Lo stesso accade poi in Italia). .

In **Italia** la situazione cambia in epoca fascista, periodo nel quale prende piede il *codice del diritto privato attuale*, un codice innovativo, perché unificato e riorganizzato, in pratica vi è stata una commercializzazione del diritto privato, un'ibridazione nata nel commercio e in ambito non commerciale.

Il diritto commerciale attuale ha delle regole proprie rispetto al diritto civile nel Libro 5.

Troviamo regole relative al soggetto, abbiamo definita la categoria dell'imprenditore funzionale all'applicazione dell'**imprenditore** nello statuto dell'imprenditore. Cioè l'imprenditore come oggetto commerciale, destinatario di un set di regole specifiche. Il diritto commerciale è composto anche dal **diritto societario**, ovvero società come soggetto dell'ordinamento giuridico; come enti e non persone, una creazione

giuridica. Una società (es: Ferrero) capace di essere titolare di diritti e regole del diritto societario, create attraverso un contratto stipulato da vita ad un ente intestatario di un'impresa (ovvero ideazione, fabbricazione ecc.). Vi sono una serie di problemi concreti da risolvere a seconda della differenza (es. Ferrero e pasticciere)

Si preoccupa di identificare l'imprenditore, poi lo assoggetta alle **regole dello statuto commerciale**.

Nel diritto commerciale troviamo le regole per aprire un e-commerce, regole sull'attività economica e non sul soggetto singolo, troviamo le regole del mercato, com'è disciplinato il mercato come luogo d'incontro tra domanda e offerta di servizi, inoltre regola anche le antitrust nei mercati.

È un'insieme di regole che disciplinano attività economiche di natura pratica sul mercato, regole pratiche di agevolazione per un buon funzionamento del mercato.

Per avviare un'attività commerciale vi è l'obbligo di iscriversi ad un **registro pubblico delle imprese**, che consente la rapida acquisizione di informazione di attività commerciali sul mercato, con l'obiettivo di garantire un certo grado di trasparenza.

Regola di liberalizzazione sul commercio online → Nel commercio online, vi è la regola secondo cui a chi voglia avviare un'attività non viene richiesto nulla.

L'impresa

- Impresa come attività
- Impresa come organizzazione
- Impresa come centro di imputazione di rapporti giuridici
- Impresa individuale
- Impresa collettiva

Sapere se svolgere un'attività economica può essere riconosciuto come essere un imprenditore è utile perché gli imprenditori devono sottostare allo statuto dell'imprenditore, che ha regole importanti come ad esempio il fallimento

La nozione di impresa servirà per capire il funzionamento del mercato, della concorrenza sleale, quando parleremo degli istituti del diritto industriale e ci servirà sapere che presuppone l'applicazione di una serie di norme come ad esempio quelle che riguardano il fallimento.

La legge non definisce cos'è l'impresa, definisce chi è l'imprenditore.



Art. 2082 cc. → è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.

Abbiamo una serie di **elementi** enumerati da questa norma. **Tutti** devono sussistere purché un soggetto possa essere qualificato come imprenditore. Innanzitutto vediamo che si parla di **attività produttiva** o di **scambio di beni o servizi**, questo requisito serve a escludere e non considerare imprenditori coloro che si limitano ad attività di mero godimento di ciò che hanno, cioè dell'esercizio di un loro diritto.

Es. se si vende l'auto usata, si sta esercitando il nostro diritto di proprietà (lo si sta trasferendo), non si sta realizzando al contrario un'attività produttiva o di scambio.

Un'attività è **considerata produttiva o di scambio quando crea un'utilità che prima non c'era**, quindi può essere un'attività di fabbricazione di un prodotto o la prestazione di un servizio.

Es. un'auto officina svolge un servizio di riparazione e crea un'utilità che prima non c'era.

Esistono anche le **attività di intermediazione della circolazione di ricchezza prodotta da altri**.

Es. compravendita di auto usate

Es. offerta in dotazione di una casa vacanze su Airbnb, in questo caso bisogna capire se ci si limita alla sola allocazione dell'immobile o se insieme a quella vengono offerti altri servizi, nell'ultimo caso si offre di più di un quid che in assenza dell'iniziativa non ci sarebbe.

Un soggetto per essere imprenditore deve integrare altri requisiti, **l'attività deve essere economica**, quindi l'imprenditore è un soggetto che punta a guadagnare dalla sua attività produttiva, ma ci si chiede se **è sempre necessario il lucro perché ci sia economicità**.

Es. lo Stato o le attività pubbliche o le cooperative, non puntano al lucro, ma anche solo ad avere un pareggio di bilancio, con lo scopo attribuire ai soci dei vantaggi, senza l'obiettivo di realizzare lucro. Le cooperative (ecc...) possono essere imprese, perché l'opinione pubblica ritiene che l'economicità non postula che vi sia un lucro e che per integrare il requisito dell'economicità sia sufficiente il pareggio tra costi e ricavi.

Ma se l'imprenditore è sfortunato e gli affari vanno male e non riesce a coprire i costi con i ricavi, è lo stesso imprenditore o non lo è ?

Se così fosse egli rischierebbe il fallimento, ma l'essere un imprenditore è uno dei presupposti del diritto fallimentare. Se il soggetto che non realizza un pareggio di bilancio cessasse di essere un imprenditore non fallirebbe nemmeno, poiché presupposto. Quindi, l'opinione largamente prevalente ritiene che la nozione di impresa e l'economicità dell'attività siano compatibili anche in situazioni di patologie (fallimento). Quello che conta è che il lucro o il pareggio di bilancio siano perseguiti a livello di obiettivo. **Perciò il carattere dell'economicità sussiste quando un soggetto svolge la sua attività produttiva col metodo economico e con l'obiettivo di avere lucro o quanto meno un pareggio.**

Un soggetto per essere imprenditore deve svolgere **un'attività** che sia anche **organizzata** al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. Quindi vediamo il **terzo requisito**, cioè **l'organizzazione**. L'attività è considerata imprenditoriale solo se è svolta con un'**organizzazione produttiva**, che consiste nei **mezzi di produzione**, cioè il capitale

Capitale → beni di qualsiasi natura, materiali (il fondo, la terra) oppure immateriali (tutti i diritti che in senso lato chiamiamo diritti di proprietà di cui si parla con la proprietà intellettuale, i diritti d'autore, brevetti, liste clienti, marchi...)

Es. un'impresa editoriale avrà per la sua produzione dei computer, dei software, delle macchine per stampare i libri ed eventualmente i diritti d'autore, i marchi e altri segni distintivi. Tutti questi beni vanno a comporre la parte dell'organizzazione costituita dal capitale.

Oltre al capitale l'organizzazione si compone anche della **forza lavoro** dei dipendenti. Perché vi sia impresa è necessario che vi sia un minimo di apparato di

beni o di lavoro organizzato per l'attività produttiva, **possono esserci solo uno o l'altro elemento. Il minimo richiesto perché si possa parlare di organizzazione** è che tutti svolgano il proprio lavoro avvalendosi di qualche strumento.

Es. lo scrittore per semplificare usa una penna e un foglio

Questa non è un'organizzazione rilevante, perché a questo punto saremmo tutti imprenditori. Quindi ci si chiede quale sia il livello minimo posto che la penna dello scrittore non è sufficiente e si arriva alla conclusione che i **mezzi che possono essere utilizzati per fare qualsiasi attività non costituiscono un'organizzazione**. L'organizzazione rilevante è integrata soltanto dai **mezzi espressivi**, cioè non generici, idonei e sufficienti allo svolgimento di una specifica attività. Quindi la penna è chiaramente un mezzo inespressivo, mentre il computer è un caso poco chiaro, perché può essere generico in linea di principio, infatti quando uso il computer sulla scrivania della scuola è considerato un mezzo inespressivo, però nel caso della Nasa è intuitivo che il computer sia considerato un mezzo espressivo. Perciò nel caso in cui si usi un computer dotato di software costosi che servono per specifiche attività computazionali, l'attività sarà considerata organizzata.

Es. un professionista che svolge l'attività di consigliare ai suoi clienti come riempire le loro vetrine con delle pubblicità più adatte, ha solo un computer con cui manda le mail e un telefono, quindi manca un'organizzazione, allora non sarà considerato un imprenditore ma un lavoratore autonomo, poiché si limita sostanzialmente a organizzare il lavoro di se stesso, cioè non ha un'etero-organizzazione, ma ha solo una auto-organizzazione, cosa non rilevante per la nozione di impresa.

Il **quarto elemento** della nozione è quello della **professionalità**, l'imprenditore svolge professionalmente un'attività economica. Nel senso comune la parola professionale rinvia alla figura del professionista, cioè un soggetto dotato di particolari conoscenze che svolge una professione di tipo intellettuale, ma la professionalità dell'imprenditore non è questa.

Es. medico, avvocato, consulente ecc..

Il requisito in questione **richiede** che l'attività sia svolta in maniera **abituale, stabile e reiterata**, quindi non è professionale un'attività sporadica. Nell'esempio di colui che dà in dotazione l'immobile manca l'attività produttiva ed è anche probabile che manchi la professionalità. Lo **stabilimento balneare** neanche è aperto tutto l'anno, però non possiamo concludere che colui che lo gestisce non sia un imprenditore, perché in questo caso si verifica una **situazione particolare**, perché l'**interruzione**

dell'attività non dipende dalla volontà del soggetto che lo gestisce, ma dipende da situazioni che sono al di fuori del suo controllo.

Non è nemmeno richiesto che l'attività sia realizzata attraverso una pluralità di affari, si ritiene che un soggetto sia egualmente imprenditore quando realizza un'attività che richieda un'organizzazione particolarmente rilevante (interferenza tra organizzazione e professionalità)

Es. chi deve costruire un ponte

Es. quando si ricevono dei regali che non ci piacciono e poi si mette un annuncio su subito, e quando questo si verifica abitualmente, questo è un caso limite perché mancano molti requisiti tra cui l'organizzazione, ma non è un'attività professionale perché l'attività è comunque contingente anche se c'è una reiterazione, perché dipende da quante volte ricevo un dono non gradito.

Quando sono integrati questi quattro requisiti si è imprenditore per la legge. Esistono però dei **soggetti che non sono mai imprenditori**, cioè il **professionista intellettuale**



Art. 2238 cc. → Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II. In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

Vi sono vari criteri per definire un professionista intellettuale. I professionisti intellettuali sono coloro che appartengono alle **categorie protette** (avvocato, medico, notaio...), però ci sono anche professionisti intellettuali che non appartengono a queste categorie, come il professionista di marketing. Quindi si guardano i contratti che operano, in particolare **un soggetto è un professionista intellettuale quando opera attraverso contratti di prestazioni d'opera intellettuale**, la caratteristica di questo contratto è quella di **richiedere di presupporre particolari conoscenze e un minimo di personalità della prefazione**, cioè il professionista intellettuale deve avere specifiche conoscenze e deve essere importante nella logica del contratto col cliente che la prestazione (attività oggetto dell'obbligazione che il professionista si obbliga a compiere) sia eseguita solo da lui, cioè non possa essere svolta da chiunque.

Il motivo per cui il **professionista non è considerato imprenditore** si ricava dal 2238 cc, secondo cui se l'esercizio della professione costituisce un elemento di un

attività di impresa, il soggetto è imprenditore (quindi la norma è formulata al contrario). Quindi se il professionista svolge la sua attività come elemento di un'attività più ampia d'impresa allora egli, seppur professionista, sarà anche imprenditore, da questo deduciamo che **quando il professionista si limita alla sua attività non è imprenditore**, quando invece il professionista costituisce un elemento più ampio può essere anche imprenditore.

Es. un medico che gestisce anche una sua clinica privata (l'unico caso in cui un professionista intellettuale può lo stesso essere un imprenditore).

Distinzione tra imprese

Imprese piccole e imprese medio-grandi, l'oggetto dell'attività si distingue tra **impresa commerciale** e **impresa agricola**, **tutte le imprese non agricole sono commerciali**, la categoria dell'impresa commerciale la ricaviamo per sottrazione. Non c'è un terzo genere "professionale", perché i professionisti non sono imprenditori.

È importante distinguere le due perché dalla differenza discendono una serie di conseguenze giuridiche. **L'imprenditore agricolo è sottratto** all'applicazione di alcune norme del diritto commerciale, è sottratto **al fallimento** e **all'obbligo di tenere le scritture contabili**, cioè registri che la legge impone di tenere agli imprenditori commerciali. Ragione di questo trattamento di favore è in parte storica, perché un tempo l'attività agricola aveva un'organizzazione di capitale abbastanza semplice, poiché c'era il fondo e poco altro e quindi era difficile che avessero grandi debiti col rischio di vedere i creditori insoddisfatti, e per ragioni di politica legislativa si è scelto di continuare l'applicazione di queste leggi.

- **Impresa agricola vs impresa commerciale** → Una volta era un'impresa agricola quella che usava i fondi, adesso **sono attività agricole quelle che utilizzano o possono utilizzare un fondo**, quindi l'utilizzo di esso non è essenziale, però è essenziale che consista nella cura di un **ciclo biologico** di qualsiasi essere vivente, per esempio i tristi allevamenti di polli in batteria costituiscono attività agricola, in particolare si tratta di **attività agricole essenziali**. Oltre a queste attività un soggetto, **rimanendo imprenditore** agricolo, può svolgere altre **attività trasformative** purché siano realizzate con materie prime che provengono da attività agricole essenziali, come la vinificazione, la realizzazione di farina, polenta, insaccati (ecc...). **Non sempre** queste attività trasformative **sono agricole**, ad esempio se possiedo una cantina vinicola e l'uva non la produco ma la compro, sono un imprenditore commerciale e non agricolo, perché manca la prevalenza delle materie prime

dall'attività essenziale, poi ci sono quelle di produzione di beni o di servizi che utilizzano prevalentemente le attrezzature dell'azienda agricola, come le attività di ristorazione, che sono tipicamente commerciali.

- **Impresa piccola vs impresa medio-grande** → Questa distinzione è importante per la stessa ragione della distinzione tra impresa agricola e commerciale, anche il piccolo imprenditore è esonerato dal fallimento e dalla tenuta delle scritture contabili. Il **piccolo imprenditore** è colui la cui organizzazione imprenditoriale è data prevalentemente dal lavoro proprio e dei suoi famigliari. L'impresa medio grande, invece, è ogni impresa diversa da quella piccola, quindi è destinataria di tutto il complesso di norme del diritto commerciale. Se il piccolo imprenditore svolge attività attraverso una grande società si applicano anche altre norme. È previsto un **registro delle imprese** che ha la funzione di **garantire la trasparenza su alcuni dati** relativi alla vita dell'impresa, per trasparenza si intende la pubblicità, la conoscibilità da parte di chiunque di alcuni dati, chiunque può accedere a questo registro e vederne il contenuto.

Ora ci si chiede quali sono le imprese che devono essere iscritte a questo registro. Un tempo dovevano iscriversi solo le imprese commerciali non piccole. Adesso, invece, c'è **un proliferare di sezioni speciali che coprono tante imprese, anche quelle piccole**. Deve esserci scritto **chi è l'imprenditore, qual è l'attività imprenditoriale, qual è la sede dell'impresa qual è la ditta, il nome con cui l'imprenditore si presenta sul mercato, i mezzi** (ecc..). Più aumenta la grandezza più aumentano gli obblighi di trasparenza.

Es. il piccolo artigiano che agisce come persona fisica ha obblighi di trasparenza molto ridotti.

Gli **effetti** della pubblicazione delle informazioni nei registri, in alcuni casi sono **costitutivi**, cioè l'iscrizione nel registro ha l'effetto di rendere efficace l'atto, se e quando la legge prevede che l'iscrizione ha efficacia costitutiva, l'atto non produce i suoi effetti prima dell'iscrizione. L'atto costitutivo di alcune società deve essere scritto nel registro. Per altre società, l'iscrizione dell'atto ha **efficacia costitutiva**, cioè prima dell'iscrizione la società non esiste.

L'iscrizione nel registro delle imprese, in altri casi, ha **effetto dichiarativo**, ovvero l'iscrizione fonda una presunzione di conoscenza da parte di tutti di quello che c'è scritto.

Es. se io scrivo nel registro che ho cambiato la sede delle società, la legge presume che tutti lo sappiano.

Alcune volte l'iscrizione ha **efficacia normativa**, cioè comporta l'applicabilità di norme diverse. Se non è iscritta e l'efficacia è normativa si applica una normativa diversa.

L'azienda



Art. 2555 cc. → L'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività d'impresa.

Azienda non è sinonimo di impresa.

La nozione di azienda è abbastanza simile a quella di organizzazione, però non troviamo la forza lavoro, ma solo i beni organizzati: **l'azienda è un insieme di beni organizzati per l'attività di impresa**. Quindi può comprendere cose mobili, immobili, materiali, immateriali.

- **Concetto di avviamento** → è la capacità di profitto dell'azienda, cioè l'attitudine di un'azienda a produrre utili, data da tante cose.

Talvolta **l'azienda può dividersi in più rami**, si pensi ad una fabbrica automobilistica, avrà al suo interno un reparto cambi, uno motori, sono **entità** che si possono immaginare come **autonome** dalle altre e che possono funzionare anche separatamente dalle altre componenti dell'azienda, le possiamo chiamare **rami di azienda**, quindi ogni articolazione potenzialmente autonoma è un ramo d'azienda. La nozione di azienda è importante perché dipende dall'applicazione di una serie di norme che disciplinano il **trasferimento d'azienda**, che è una disciplina che si applica tutte le volte che un soggetto trasferisce ad un altro un'azienda o un ramo d'azienda.

- **Prima regola relativa al trasferimento d'azienda** → Se due parti si accordano per trasferire l'azienda, automaticamente si considerano oggetto del contratto tutti i beni che fanno parte dell'azienda, le parti possono anche decidere che alcuni beni che fanno parte dell'azienda non vengano trasferiti, però se ne escludono troppi, non sarà più l'azienda ad essere trasferita ma solo un insieme di beni, perciò non c'è più trasferimento quando viene escluso un complesso di beni che sia essenziale.

Vedere se un contratto è qualificabile come cessione dell'azienda è importante perché c'è una disciplina che si applica.



Art 2557 cc. → Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente e' valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.

Se nel patto e' indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.

Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.

Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

L'alienante si deve sostenere dal compiere atti di concorrenza nei confronti dell'acquirente. Riguarda cessioni d'azienda commerciali, e qualora sia un'azienda agricola, il divieto si applica soltanto alle attività connesse. L'oggetto di questo divieto di concorrenza riguarda l'inizio di una nuova attività in concorrenza con quella dell'imprenditore che ha acquistato l'azienda. Se invece l'imprenditore cedente aveva più attività anche potenzialmente in concorrenza tra loro può continuare l'attività con l'azienda che ha trattenuto.

Es. Se un soggetto ha un solo bar e lo vende, non ne può aprire uno a 10 metri più in là. Però, se un soggetto ha un bar a Torino e lo vende potrà iniziare una nuova attività analoga a Genova, perché si rivolge ad una clientela differente.

Questo divieto ha una durata di 5 anni, è derogabile in diminuzione ma non in aumento. Altra conseguenza della stipulazione di un contratto di cessione d'azienda

riguarda i contratti.



Art 2558 → Se non e' pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.

Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto dell'affitto.

Opera il principio del subentro automatico dell'acquirente dell'azienda in questi contratti, l'acquirente quindi subentra nei contratti relativi all'azienda. Questa è una particolarità della disciplina perché, come sappiamo, per modificare una parte del contratto è necessario l'accordo tra le parti originarie, invece quando è ceduta l'azienda automaticamente avviene una modifica delle parti del contratto. Questo succede per una logica di semplificazione, chi compra un'azienda ha interesse a portarla avanti.

Es. se c'erano delle commesse, chi compra l'azienda le tiene.

Questa regola non si applica ai contratti di carattere personale, cioè quelli per il cui svolgimento necessitano delle qualità specifiche dell'imprenditore. La funzione di questa norma è **tutelare l'interesse del terzo contraente**. Sempre a tutela del terzo la legge prevede anche che **egli possa recedere dal contratto** (uscire dal contratto) **nel termine di tre mesi** purché esista una giusta causa

Es situazioni di comprovata inimicizia tra il terzo e il nuovo imprenditore che ha acquistato l'azienda.

Questa disciplina si completa con altre **due regole** che riguardano: i **crediti** e i **debiti** relativi all'azienda che viene trasferita.

Tre discipline diverse:

- Crediti
- Debiti

- Contratti (si compongono di più posizioni giuridiche soggettive)

Se abbiamo un contratto di compravendita, applichiamo la disciplina del contratto quando il contraente non ha pagato. Applichiamo la disciplina del debito quando il venditore dell'azienda deve ancora consegnare la merce ma il terzo contraente me l'ha già pagata, rimane il diritto relativo alla consegna della merce. Relativamente ai debiti nella pratica **la legge si trova a dover fare un bilanciamento tra i vari interessi in campo.**

Es. acquisto un bar, mi informo come vanno gli affari, e in teoria vanno bene, ma dopo un mese che ho comprato l'azienda arriva un creditore che dice di avere un credito di 8 milioni di euro nei confronti dell'imprenditore che ha ceduto l'azienda, il povero acquirente non si aspettava un debito simile.

Quindi oltre alla posizione del creditore a soddisfarsi sull'azienda anche se essa è stata ceduta, la legge deve tutelare anche gli interessi di quello che l'ha comprata. Se non fosse così nessuno comprerebbe più aziende. E quindi la legge attua un bilanciamento tra queste due esigenze



Art 2560 cc. → L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Il comma secondo dice che attraverso il trasferimento di un'azienda commerciale, risponde dei debiti anche l'acquirente, solo se questi debiti risultano dalle scritture contabili obbligatorie. **Per le aziende agricole questa regola non si applica.** Bilanciamento molto saggio perché chi acquista l'azienda è quantomeno in condizione di conoscere i debiti che risultano dalle scritture contabili prima di acquistare l'azienda per verificare che sia tutto in ordine. Anche se non risultano dalle scritture sono comunque sempre opponibili all'acquirente (cioè che deve pagare) i debiti il cui pagamento è richiesto dalla tutela di interessi particolarmente rilevanti: **debiti nei confronti dei lavoratori, debiti nei confronti del fisco.**

- **Disciplina dei crediti** → Il diritto privato dice che il credito può essere ceduto anche senza il consenso del debitore perché a egli non cambia, però **la**

cessione del credito è efficace solo nel momento in cui è notificata.



Art 2559 cc. → La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al d'editore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.

Per ragioni di semplificazione delle procedure prevede che la cessione dell'eventuale credito d'azienda è efficace nei confronti del debitore senza bisogno di notificargliela purché sia iscritta nel registro delle imprese (esempio dell'efficacia dichiarativa nel registro).

La società

La società nasce per rispondere all'esigenza, di più persone, di svolgere insieme un'attività produttiva, dividendo i rischi nell'avvio di qualsiasi attività con la speranza di avere poi dei guadagni da dividere. Normalmente la società è un modo per svolgere un'attività imprenditoriale talvolta anche un'attività professionale e può esistere anche una società senza impresa, però generalmente è un modo per svolgere un'attività d'impresa.

Es: io ho un brevetto, un mio amico è ricco e ha da investire, un altro ha un capannone dove potremmo insediare l'attività produttiva allora ci mettiamo insieme.

Ma la società è definita come **una struttura organizzativa destinata all'esercizio di un'attività produttiva e con una propria dotazione patrimoniale**. L'azienda è un'insieme di oggetti, la società invece è un soggetto astratto, per il diritto. Quindi, nel caso di più soggetti che si mettono in società per fare un'attività produttiva l'imprenditore è la società, in alcuni casi è anche il socio, il soggetto di imputazione fondamentale è la società, essa stipula i contratti (con fornitori e clienti) ci saranno degli amministratori che firmeranno in nome della società.



Art. 2247 → Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Questo articolo in realtà non definisce la società come soggetto ma parla di contratto di società da cui ricaviamo la nozione di società. Innanzitutto si parla di **attività economica**, stessa cosa che abbiamo visto parlando di impresa, poi **"esercizio in comune"**. A prima vista sembra che la società è necessariamente **pluripersonale** ma non sempre è così perché a fronte di questa norma che sembra suggerire ciò, ci sono altre norme che consentono ad alcune società di essere **unipersonali**. Nel caso in cui si mettono insieme più soggetti per svolgere un'attività, questa comunanza realizza una società solo nel momento in cui i soci esercitano in comune l'attività, cioè che condividono il rischio d'impresa, cioè che concorrono a fornire alla società la dotazione patrimoniale (cioè che tutti mettono qualcosa) e che tutti chi più chi meno partecipino alla distribuzione degli eventuali utili, guadagni. Si pensi all'**impresa familiare**, è un contesto in cui più soggetti lavorano insieme, ma generalmente colui che si assume il rischio dell'iniziativa imprenditoriale è un soggetto solo, che si fa aiutare dai suoi parenti. Questa **collaborazione familiare non integra una società, è un'impresa individuale con dei collaboratori**. Per avere esercizio comune quindi è **necessario che tutti mettano qualcosa e che tutti partecipino ai guadagni**. **"Dotazione patrimoniale"** elemento importante, si chiamano **conferimenti**, ciò che i soci conferiscono alla società. Devono esserci per forza i conferimenti, senno non c'è società e **possono essere beni o servizi di qualsiasi natura purché siano suscettibili di valutazione economica**. È ammessa quindi la partecipazione del socio d'opera, un socio mette il denaro, l'altro il capannone e l'altro le sue conoscenze, abilità.

L'**effetto del conferimento**, dal fatto che un soggetto decide di conferire un bene in società, è che questo bene conferito diventi soggetto ad un vincolo di indisponibilità, **anche se il socio esce dalla società** con una operazione di recesso, comunque **non ha diritto alla restituzione del bene** che aveva conferito. Non basta che l'attività sia economica, la società deve avere come scopo la suddivisione degli utili, cioè ci si deve dividere i guadagni. Questo fermandoci ad una interpretazione letterale, però ci sono **alcune norme che qualificano come società anche quelle che per la loro natura non distribuiscono gli utili, ma attribuiscono ai soci dei vantaggi di altra natura**.

Es. la facoltà di poter stipulare un'assicurazione a condizioni più favorevoli di quelle di mercato.

La società consortile attribuisce vantaggi invece che ai soci, alle imprese dei soci, cioè ai soci come imprenditori.

Es. il caso più semplice è quello di una società tra imprenditori agricoli che si occupa di garantire l'irrigazione per tutti i terreni dei soci.

In questi casi c'è quello che si dice **scopo egoistico**, altrimenti non si ha società. Le società sono **atipiche**, non si può costruire una società fatta come vogliamo. La legge prevede **6 tipi** di società e i cittadini possono sceglierne uno, all'interno dei singoli tipi però c'è una certa flessibilità, quindi i soci possono decidere che la società sia regolata in modo particolare secondo le loro esigenze.

Ci sono due macro categorie:

- **Società di persone** → il socio è importante in quanto persona
 - Società **semplice**
 - Società **in nome collettivo**
 - Società **in accomandita**
- **Società di capitali** → il socio è importante per il capitale che ha conferito e che quindi rappresenta:
 - Società a responsabilità limitata (**Srl**)
 - Società per azioni (**SpA**)
 - Società in accomandita per azioni

Tra questi tipi di società è possibile scegliere quello che si preferisce, quello più adatto alle proprie esigenze con **un solo limite, non si può usare la società semplice per svolgere un'attività commerciale**. Le società semplici quindi, possono essere solo attività agricole o professionali, non commerciali.

Caratteristiche

- **Società di persone** → al centro ci sono le persone

Ci deve essere sempre essere almeno **un socio illimitatamente responsabile**, cioè almeno uno deve pagare i creditori in caso in cui la società non paga. C'è una lieve differenza tra la società semplice e la società in nome collettivo perché il creditore di una società semplice può rivolgersi direttamente al socio senza prima provare a intraprendere un'azione esecutiva sul patrimonio della società e

il socio può liberarsi dall'obbligo di pagare il creditore della società solo indicando al creditore quali sono i beni della società sui cui si potrebbe avvalere. Nella società in nome collettivo, invece, il creditore può agire nei confronti del socio solo se dimostra di avere prima provato ad avere agito nei confronti della società senza successo. Se la società in nome collettivo non è iscritta al registro delle imprese si applica la stessa disciplina della società semplice. Nel caso della società in accomandita semplice la situazione è diversa, ci sono due categorie di soci, **ci sono dei soci chiamati accomandanti e dei soci chiamati accomandatari**, la differenza tra le due categorie è che chi gestisce la società sono gli accomandatari e sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni della società nel caso in cui non paghi, gli accomandanti rischiano solo i conferimenti. Quindi il creditore che non viene pagato dalla società può pretendere di essere soddisfatto dagli accomandatari ma non dagli accomandanti e allora gli accomandanti possono star tranquilli purché non fanno danni perché essi perdono il beneficio della responsabilità limitata se compiono atti di gestione.

- **Società di capitali** → al centro c'è capitale

Opera come principio generale quello che tutti i soci godono del beneficio della **responsabilità limitata**, l'idea è che il socio di una società di capitali, nel caso l'attività andasse male, non perderà altro che quanto conferito alla società, il conferimento, cioè non avrà indietro un utile.

Es. se il socio ha messo 10 mila euro a titolo di conferimento non li avrà indietro.

C'è solo un'eccezione, alcune società possono essere anche unipersonali, ma la prima categoria può essere solo pluripersonali. Tuttavia **il socio unico** è soggetto ad un paio di norme particolari:

- deve pagare subito l'intero ammontare del conferimento, altrimenti con più di calma (subito col 25 % e il resto dopo)
- deve depositare nel registro una dichiarazione per rintracciarlo.

Se il socio unico non fa una di queste due diventa illimitatamente responsabile, perde il beneficio della responsabilità limitata. Come conseguenza di questa differenza, la legge non prevede un ammontare minimo dei conferimenti per le società di persone, mentre prevede un valore minimo dei conferimenti, 10mila euro per la srl e 50mila euro per la SpA, per dare un minimo di garanzia ai creditori.

Ripasso

Statuto dell'imprenditore, norme di particolare importanza:

- l'iscrizione al registro delle imprese
- obbligo della tenuta delle scritture contabili

Fallimento

Dal punto di vista del diritto dell'impresa significa che tutti i beni dell'imprenditore vengono assoggettati a un vincolo giuridico. L'imprenditore viene spossessato di tutti i beni che non siano strettamente personali. Questi beni vengono affidati a un giudice che ha il compito di convertire questi beni in denaro e con questo denaro pagare, nei limiti del possibile, i creditori che dicono di aver dato qualcosa agli imprenditori e che non sono stati ripagati. Col tempo questo sistema si è ispirato all'America in cui si pensa che fallire sia un po' come sbagliare a scuola, sbagliando si impara, allo stesso modo, l'imprenditore che si è trovato in una situazione di crisi (incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni) non deve essere espulso dal sistema economico, non deve essere castigato, ma bisogna mettere su un sistema ordinato che metta in ordine la crisi, nei limiti del possibile

- tenendo in vita l'impresa e affidandola ad altri (che la gestiranno meglio)
- a volte anche lasciandola in mano allo stesso
- e se proprio non si potesse proseguire, convertendo le sostanze in denaro con il quale pagare i creditori

Azienda

Non è un soggetto, non è un sinonimo di impresa, ma è un oggetto, un insieme di beni che servono a svolgere una certa attività economica e che come tali sono stati aggregati dall'imprenditore. L'azienda è un concetto giuridico che è stato creato con lo scopo di favorire il trasferimento di questo complesso di beni attraverso il quale è possibile esercitare un'attività economica. Nella legge si trova solamente il concetto di cessione di azienda, non di impresa. La **cessione di azienda** è il negozio giuridico attraverso il quale avviene il trasferimento dell'impresa da un soggetto ad un altro. L'obiettivo della cessione d'azienda è ereditare la clientela che già vi era per una certa attività.

Società

La società è un contratto, il contratto di società, è un contratto particolare perché dà vita ad un soggetto dell'ordinamento giuridico, il soggetto società. Si caratterizza dal fatto di non essere concreta, ma è un ente giuridico, una creazione del diritto che ha una propria soggettività giuridica, cioè una propria capacità di essere titolare di diritti e obbligazioni, che ha un proprio patrimonio, propri beni, che ha una propria ragion d'essere, che è quella di svolgere una propria attività economica, e cioè essere imprenditore, e che è costituita dai soci, che sono i contraenti del contratto di società i quali perseguono l'obiettivo di arricchirsi. Vi sono due categorie di società, il concetto di responsabilità è declinato in due modi:

- responsabilità civile, che è quella da fatto illecito con l'obbligo di risarcire il danno
- responsabilità patrimoniale, che è il principio in virtù del quale la legge dice che il debitore è tenuto all'adempimento delle proprie obbligazioni, con tutti i propri beni presenti e futuri.

Differenza tra società di persone e di capitali

Nelle società di persone vale il principio per il quale normalmente i soci a responsabilità illimitata sono anche incaricati del potere di gestire la società e rappresentarla nei rapporti con i terzi, mentre i soci a responsabilità limitata nelle società di persone sono sempre esclusi dall'amministrazione e dalla rappresentanza della società. Gestire significa amministrare la società, assumere le scelte imprenditoriali, che tipo di prodotti fabbricare, con quali materie prime, quali persone assumere, quali mansioni impartire, fissare il prezzo dei beni, scegliere dove distribuirli...

Amministrare una società vuol dire detenere il potere. Chi amministra o gestisce la società la comanda. Rappresentare significa firmare i contratti in nome e per conto della società: contratti con i fornitori, con i dipendenti e clienti. Il potere di firma è solo degli amministratori. I soci non amministratori, nelle società di persone, non possono ingerirsi nell'attività amministrativa, se mettono le mani in queste attività perdono la responsabilità limitata. Emerge qui un **principio più generale**, valido per l'imprenditore individuale, per le società di persone e anche in qualche misura per le società di capitali ed è il principio secondo il quale **rischio e potere vanno di pari passo**. Chi assume i rischi dell'attività economica è normalmente colui che comanda di più nella società, chi se ne assume meno normalmente comanda di meno.

Società di persone

- Società semplice → tipo di società elementare per l'esercizio di attività non commerciali.
- Società in nome collettivo → tipo di società più elementare per l'esercizio di attività commerciale.



Art. 2290 cc. → Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.

Principio secondo cui tutti i soci sono illimitatamente responsabili verso i terzi, cioè in questa società non ci possono essere soci a responsabilità limitata. Questo significa che se la società fallisce, falliscono anche tutti i soci in estensione. Dunque questo è un tipo di società in cui tutti i soci assumono il rischio di impresa, anche individualmente, quindi il loro patrimonio viene catturato ed usato per pagare i debiti. Tutti i soci hanno potere amministrativo, tutti hanno il potere di rappresentare la società, a meno che non si accordino tra loro.

- **Società in accomandita semplice** → società commerciale più sofisticata rispetto a quella in nome collettivo. Ci sono due categorie di soci, gli accomandatari, cioè a responsabilità illimitata, con potere amministrativo e di rappresentanza, e gli accomandanti, cioè a responsabilità limitata. Sugli accomandanti grava il divieto di immistione, che è quello di ingerirsi nella gestione della società. Anche qui, potere e rischio vanno insieme, perciò comandano quelli che hanno il rischio di impresa più grande.

Società di capitali

La regola è quella secondo cui tutti i soci hanno la responsabilità limitata. Però vediamo riemergere la regola secondo cui potere e responsabilità vanno di pari passo e lo vediamo in relazione al tipo di società di capitali più sofisticata:

- **Società per azioni** → Una società per azioni è una società nella quale la posizione contrattuale di socio, è incorporata in un titolo, che chiamiamo azione. Le azioni, appartenenti alla stessa categoria sono tutte uguali tra loro, hanno lo

stesso valore nominale, attribuiscono gli stessi diritti amministrativi ed economici.

Questa costruzione giuridica serve a rendere semplice e agevole la gestione della posizione di socio, nel momento in cui compro le azioni di una società, ne divento non solo azionista, ma anche socio di quella società. Nel momento in cui le rivendo, dismetto di essere socio della società, e permetto a qualcun altro, che compra le mie azioni, di diventarlo in modo agevole. Nella società per azioni, costituita secondo il modello tradizionale italiano, noi troviamo nella struttura, **tre organi**:

- **Assemblea di soci** → In questa assemblea siedono i soci o azionisti, in termini ateniesi si dice che la proprietà delle società per azioni sta nelle mani dei soci. Il **primo potere** dell'assemblea è decidere, tramite il meccanismo di maggioranza, a chi affidare l'amministrazione della società, quindi chi la gestirà, l'idea è quindi che chi ha più azioni comanda di più. Nelle società per azioni con azioni quotate in borsa, le regole sono più sofisticate, ci sono sistemi che fanno in modo che anche le minoranze abbiano possibilità di esprimersi. Il **secondo potere** dell'assemblea è quello di cacciare l'amministratore nel caso in cui abbia compiuto azioni di mala gestione (e lui non può controbattere). L'unica cosa che riceve l'amministratore revocato è un indennizzo, cioè gli si deve pagare quanto avrebbe guadagnato se avesse portato a termine il periodo di carica, che normalmente è di tre anni. L'assemblea, poi, ha una serie di altre competenze funzionali a controllare la gestione della società in modo indiretto, deve riunirsi tutti gli anni ed approvare i bilanci che si trovano nei registri, quando approva il bilancio, se ci sono dei dubbi, può decidere anche se ripartirli tra i soci (dividendi che vengono distribuiti) oppure se tenerli nel patrimonio della società e autofinanziare la società. Ancora, se l'assemblea ordinaria dei soci ritiene che gli amministratori abbiano compiuto degli atti di mala gestione cagionando così dei danni alla società può decidere di far causa, come società, agli amministratori per il risarcimento del danno. Un'**ultima regola** dice che qualora lo statuto della società lo preveda, l'assemblea ha il potere di dare agli amministratori delle **autorizzazioni** per il compimento di certi atti.
 - Es. se c'è un investimento importante su cui decidere, l'assemblea interviene non per decidere essa stessa ma per darle l'autorizzazione, sono gli amministratori che sono liberi di compiere o meno l'operazione.



Art. 2380-bis cc. → L'assemblea può autorizzare ma non ordinare il compimento degli atti di gestione, non c'è un potere di veto rispetto agli atti degli amministratori, perché la gestione è competenza esclusiva degli amministratori.

((La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.)).

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

Dice testualmente che è competenza esclusiva dell'organo amministrativo la gestione della società. Quindi la società è gestita dagli amministratori finché hanno la fiducia dell'assemblea. Nel momento in cui i soci dell'assemblea non sono contenti degli amministratori potranno revocarli e nominare qualcun altro. Anche qui potere e responsabilità vanno di pari passo, perché chi ha più azioni in una società, chi ha investito di più nella società sceglierà, e allora è normale che conti di più in assemblea, perché ciascuna azione vale un voto, dunque se ho investito tanto per avere tante azioni è giusto che abbia tanti voti in assemblea. Questo perché se poi la società fallirà, il valore delle mie tante azioni verrà azzerato.

- **Organo amministrativo** → da quanto detto prima si vede quanto sia nelle mani dell'assemblea. Ha il potere di revoca.

- **Collegio sindacale** → organo di controllo delle società quotate e ha il compito di vigilare sull'attività degli amministratori e controllare che la gestione e l'amministrazione della società si svolgano nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo

Passaggio dalle piccole società per azioni alle grandi società con azioni quotate in borsa, che magari hanno tanti tanti azionisti e una grande abilità economica e che assumono la caratteristica tipica delle public companies. La **Public Company** è tipicamente una società per azioni quotata in borsa che ha una miriade di azionisti, nessuno dei quali individualmente è in grado di raggiungere la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria.

Quando si ha una società di questo genere, abbiamo davanti una situazione nella quale c'è un po' di scostamento tra questo rapporto, che abbiamo visto essere normalmente valido tra responsabilità e potere, perché nelle società per azioni quotate (Public companies) normalmente ci sono alcuni azionisti che sono azionisti di minoranza ma che però sono dei professionisti, sono degli azionisti che si interessano nell'impresa gestita dalla società, che sono molto attivi nella società, poi c'è una valanga di azionisti minimi o piccoli o che hanno degli interessi puramente speculativi, cioè azionisti che hanno investito un po' di soldi (tanti o pochi a seconda delle caratteristiche) con l'unico obiettivo di riscuotere periodicamente i dividendi. Quando c'è una situazione del genere, gli azionisti comunque riescono a condizionare l'assemblea dei soci e dunque riescono a far decidere alla società quello che loro ritengono giusto (soprattutto dal punto di vista della nomina degli amministratori) pur non avendo una maggioranza delle azioni (cioè una minoranza qualificata), questo perché altrettanti azionisti non partecipano all'assemblea perché puntano alla speculazione per fare trading oppure si tratta di **azionisti**, cosiddetti **istituzionali**, che investono ma non vogliono occuparsi della gestione della società

Es. fondi pensione.

Questi azionisti lasciano che faccia la società. Dunque succede che azionisti di minoranza comandano, ma essendo di minoranza, pur comandando, non rischiano quanto rischierebbero gli azionisti hanno investito molto di più di loro, per questa ragione si parla di scollamento o scostamento tra potere e responsabilità.

Trasparenza

All'interno dello statuto dell'imprenditore abbiamo un set di regole importanti è quello relativo al registro dell'impresa. L'imprenditore, una volta solo quello commerciale, oggi in realtà tutti, è tenuto ad esprimersi in questo registro. Oggi il **registro** è un

database gestito dalle camere di commercio nella quale sono inserite delle schede ciascuna delle quali corrisponde a una singola impresa che agisce in un certo modo. Può essere un'impresa individuale, così come un'impresa esercitata in forma societaria, in questo secondo caso può trattarsi di una società di persone o di una società di capitali. L'elemento che ci interessa richiamare all'attenzione è quando l'impresa è individuale, oppure quando è un'impresa esercitata da una società di persone la scheda che riguarda quell'impresa contenuta nel registro è una scheda molto scarna.

- nome civile dell'imprenditore
- nome commerciale dell'imprenditore (nome della ditta)
- sede dell'impresa
- tipo di attività svolta

Se peschiamo la scheda di una società di capitali, di una società per azioni o anche solo di una s.r.l (società a responsabilità limitata) il novero delle informazioni è molto più ampio. Se si fa una visura camerale relativa una società di capitali troviamo in più:

- il nome dei soci
- indicazioni sulle quote che spettano ai singoli soci
- i bilanci → le società di capitali devono pubblicare i loro bilanci altrimenti incorrono in sanzioni, pubblicarli significa esporre al pubblico, a chiunque voglia consultare il registro, informazioni dettagliate circa il patrimonio della società, i debiti, il capitale...

Questo spiega perché esistono ancora tante imprese individuali e società di persone che sono forme di esercizio dell'attività di impresa più primitive e che recano, per chi le sceglie, il rischio di fallimento, di perdere tutto se l'attività va male.

Es. immaginiamo di inventare un'app e anche il modo per renderla redditizia, bisogna però capire come agire, se è possibile si cerca di ottenere dei titoli per l'invenzione, ma bisogna soprattutto decidere quale di queste due strade prendere:

- **Farsi imprenditore**, cioè trasformare l'idea (in questo caso l'applicazione) nell'oggetto di una nuova impresa, la "mia" impresa.
- **Venderla**, vado a cercare qualcuno che sia interessato a comprarla, che abbia già un'impresa e che quindi non debba costruirla "io", mi da un gruzzoletto e io campo felice per qualche anno, magari investo in azioni.

Lasciando perdere la seconda strada, immaginiamo di voler costruire un'impresa su quell'idea. Anzitutto bisogna decidere in che modo organizzarla e le alternative sono:

- **L'impresa individuale**, non la società, vale a dire avere i soldi in casa, se le cose vanno bene l'impresa fiorirà, se le cose vanno male si perdono i soldi che si hanno investito, e non solo, se si contraggono debiti, i creditori possono venire a togliere la casa. Quindi la prima opzione è rischio io e il potere è mio.
- **La società di persone**, mi trovo qualcuno che sia disposto a fare società con me, questa opzione della società di persone ha pro e contro, se si sceglie la società in accomandita semplice è come scegliere l'impresa individuale poiché non cambia molto, l'unica differenza è appunto il fatto che si ha un socio (ricco magari) che contribuisce con il suo denaro o col suo lavoro, il rischio però resta sempre quello.

Società tecnologiche e start up

Queste società hanno altre esigenze, loro normalmente hanno bisogno di organizzarsi secondo i tipi di capitali, cioè vanno avviate almeno come società a responsabilità limitata. Questo per una serie lunga di ragioni, un po' è l'incentivo normativo, cioè le norme sulle start up innovative, adottate negli ultimi 10 anni allo scopo di favorire la nascita di imprese innovative, sono norme che prevedono come agevolazione specifica un accesso semplificato con l'uso dell'elemento giuridico della responsabilità limitata. L'idea è che in generale le persone, soprattutto i giovani, possano essere più propensi ad avviare un'attività economica innovativa se riescono a limitare il rischio di questa operazione.

Es. se si vuole costruire un'impresa a partire da un'idea, non ci si sente in imbarazzo nel chiedere 5-10 mila euro ai propri genitori se si sapesse che comunque non si rischia il proprio patrimonio, non c'è il rischio di rovinarsi la vita nel caso le cose andassero male, poiché vi è la responsabilità limitata. Tuttavia, 5-10 mila euro per avviare un'attività non sono abbastanza, allora si va a caccia di investitori, quindi una volta costituita la srl start up innovativa, si va a caccia di investitori.

Gli **investitori** che mettono i soldi sono le **banche**, che possono fare dei mutui, che però normalmente non danno molti soldi ai giovani con delle buone idee se non c'è qualcuno che garantisce per loro, e quindi normalmente serve qualcuno che sia disposto a pagare il mutuo se la società non ha modo o capacità di farlo e i soci non hanno un patrimonio capiente per pagare. Però ci sono anche altri investitori in giro, i cosiddetti "**business angels**" che invece hanno una maggiore propensione al

rischio rispetto alle banche e quindi sono più disposti a finanziare le start up e poi naturalmente ci sono strumenti alternativi basati sulle tecnologie, i **crowdfunding**. Tutti questi soggetti sono abbastanza ben disposti a lasciare gran parte del potere di gestione ai fondatori perché i fondatori solitamente sono soggetti molto motivati, anche se il denaro lo mettono per la maggior parte gli altri, è chiaro però che man mano che cresce la misura dell'investimento il finanziatore chiederà di avere un posto nel consiglio d'amministrazione, quindi condividere la gestione di una società.

Il mercato

Il mercato è il **luogo**, in senso figurato, in cui si scambiano **beni e servizi** e nel quale i soggetti, di cui abbiamo parlato, si trovano ad interagire. Il primo aspetto importante è che non è detto che la produzione e lo scambio di beni e servizi debbano avvenire sul mercato, cioè abbiamo la possibilità che le attività produttive e di collocamento dei beni e servizi prodotti non siano svolte in regimi di mercato, ma che siano invece svolte in regime di riserva in favore dello Stato. Dunque l'organizzazione delle attività economiche (affidate all'operare di imprenditori in concorrenza) e la collocazione delle merci e dei servizi (collocata sul mercato concorrenziale) dipendono da una scelta compiuta da chi detiene il potere (sovrano).

Noi non abbiamo mai sperimentato l'economia collettivista, nel senso che nell'ultimo periodo della nostra storia che inizia con la costruzione della costituzione repubblicana, la scelta che è stata operata va nel senso della libertà di impresa nell'economia di mercato.

Nel periodo anteriore a quello fascista, nell'economia valeva in linea di principio l'accesso al mercato.

Per trovare un'economia, nel nostro territorio, che non fosse ispirata alla logica del mercato bisogna risalire all'Italia geografica, quindi con la nascita dei comuni in cui l'economia diventa dominante e si organizza attraverso le corporazioni, in cui vale il principio secondo cui solo chi appartiene alla corporazione è ammesso a svolgere determinate attività economiche.

La corporazione in generale dettava le regole per la produzione, e per il commercio dei beni e poi le amministrava anche attraverso una propria magistratura interna (sistema in cui non vale il principio del libero accesso nel mercato, vale all'opposto il principio secondo il quale solo chi appartiene alla corporazione può svolgere una certa attività economica), non vale la concorrenza perché coloro che non appartengono a una corporazione non si fanno concorrenza. Dunque in passato vi era un sistema nel quale i principi odierni non valevano.

Oggi la situazione deve essere considerata a **tre diversi livelli** dal punto di vista dell'accesso al mercato e del suo funzionamento:

1. **Livello nazionale/ italiano**
2. **Livello Europeo**
3. **Diritto internazionale**

Livello Nazionale

Su questo livello le regole sono stabilite anzitutto al vertice della costituzione repubblicana



Art. 41 Costituzione → L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Questo articolo detta il principio secondo il quale l'iniziativa economica privata è libera, significa che chi vuole farsi imprenditore è libero di farlo (si ricollega alla nozione dell'imprenditore). Non è un principio scontato, è il frutto di una scelta. Nel periodo in cui è stata scritta la costituzione esisteva il blocco orientale, in cui questo principio non valeva. L'Unione Sovietica e i paesi appartenenti a quel sistema non sposavano il principio dell'iniziativa economica, rifiutando l'idea dell'iniziativa privata, del mercato, del capitalismo. I nostri costituenti optano per il sistema occidentale, non senza moderazioni. Nel senso che se scorriamo la costituzione si vede che ci sono una serie di norme, in particolare quelle dedicate ai rapporti economici, che sono delle moderazioni rispetto a questo principio di libertà di accesso al mercato. Già in questo articolo 41 troviamo affermata la possibilità che lo Stato detti delle regole che non derogano necessariamente il principio dell'iniziativa della libertà economica ma che sono dirette a regolare il modo con il quale attività economiche possono essere svolte dai privati a tutela dell'interesse generale. Questo articolo, dunque, ***non è impeditivo delle regole statali***.

Sempre nella costituzione e relativamente alle norme sui rapporti economici, abbiamo l'articolo 42.



Art. 42 Costituzione → La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [cfr. artt. 44, 47 c. 2].

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

In questo articolo si trova il principio secondo il quale i beni economici possono essere pubblici o privati. Ciò significa che i beni produttivi da fabbrica possono essere tanto privati quanto pubblici, allora si può leggere questa disposizione in due modi diversi:

- Il **primo** dice che *i privati possono essere proprietari di mezzi di produzione*, questo è in consonanza con il principio della libertà di iniziativa economica privata. Per svolgere un'attività economica occorre che gli imprenditori possano essere i proprietari dei mezzi di produzione.
- Il **secondo** consente la *proprietà pubblica dei mezzi di produzione*, cioè questo articolo ammette che i mezzi di produzione appartengono allo Stato, pertanto conferma l'idea (già ricavabile dal 41) che attività economiche possono essere svolte oltre che dai privati anche dallo Stato, in regime di concorrenza ma più facilmente in regime di monopolio pubblico.

Sempre nelle norme sui rapporti economici troviamo la **Tutela della proprietà privata** anche dei mezzi di produzione, e al contempo troviamo però l'affermazione

della possibilità che lo Stato possa espropriare i beni ai privati con fini di utilità generale. In generale ne ricaviamo che il nostro sistema è ispirato al principio tendenziale della libertà economica, del libero mercato, della concorrenza sul mercato ma non è incompatibile con la proprietà pubblica, dei mezzi di produzione, attraverso il monopolio pubblico.

Ne deriva un sistema misto in cui c'è privato e pubblico.

Tuttavia, per un lungo tempo, l'economia italiana è stata effettivamente un'economia che ha applicato un modello misto in cui c'erano le imprese private ma anche tante pubbliche.

Poi c'erano i settori in cui lo Stato non agiva in regime di monopolio ma comunque era presente. Le regole domestiche (la costituzione) non sono cambiate ma è cambiato ciò che sta attorno.

Es. la televisione era solo della Rai.

Es. l'Alfa Romeo era in mano allo Stato prima che fosse della Fiat.

Diritto Europeo

Nel 1957 l'Italia ospita la **Conferenza Diplomatica a Roma** nel corso della quale si firma il **Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea**, un trattato internazionale che dà vita ad una organizzazione, la Comunità Economica Europea, che ha alcune caratteristiche specifiche e alcune finalità fondamentali.

- **L'obiettivo** perseguito con la firma del trattato di Roma → siamo in un periodo in cui c'è la cortina di ferro, c'è la costruzione del muro, siamo in un clima di grandi contrapposizioni, durante la guerra fredda l'Europa è un po' il terreno sul quale viene combattuto questo conflitto.

L'idea è quella di cementare il blocco occidentale nella sua componente europea, ma c'è anche l'idea di costruire un quadro giuridico e economico che favorisca la concordia tra i paesi dell'Europa occidentale, la pace, la crescita e il rafforzamento economico.

Dunque la **CEE** nasce con un fine-mezzo, costituito dalla creazione del mercato comune, che viene poi nominato come **mercato interno**, cioè un' area corrispondente al complesso di territori dei paesi membri all'interno della quale merci, servizi, capitali, imprese possano circolare e operare liberamente. Un **luogo senza frontiere interne** nel quale le imprese stabilite in un paese membro possono offrire le loro merci ai consumatori che si trovano in altri paesi membri, un luogo in

cui i capitali possono circolare liberamente, da Stato a Stato, un luogo in cui le imprese possono decidere dove stabilirsi dove meglio credono.

Es. spostando la loro sede da Torino ad Amsterdam senza limitazioni e con l'assicurazione di poter operare indifferentemente dal luogo in cui si ha deciso di stabilirsi . Questo è il fine mezzo.

Un mercato nel quale valgono dettate alcune regole fondamentali contenute già nel Trattato di Roma che sono volte ad assicurare che questo mercato interno abbia una configurazione concorrenziale, cioè, un mercato nel quale chi vuole esercitare attività d'impresa può farlo liberamente, dove sono represses le pratiche degli imprenditori volte a limitare la concorrenza, un mercato nel quale si cerca di incentivare la competizione. Questo è il contesto nel quale le norme costituzionali italiane si trovano ad operare a partire dalla fine degli anni '50.

Attenzione, perché queste fonti (Trattato e Costituzione) non sono strutturalmente incompatibili con la presenza degli Stati nazionali nell'economia, cioè non ci sono norme che vietano in generale la costituzione di monopoli pubblici di attività economiche in settori ben definiti.

E d'altra parte ci sono disposizioni espresse nel Trattato che consentono l'intervento dello Stato a sostegno delle imprese, intervento pubblico dello Stato con funzione di regolatore, in settori dove vi sono esigenze dell' interesse pubblico da difendere. Questo spiega perché certi monopoli pubblici durino ancora per decenni dopo l'entrata del Trattato di Roma nel '57.

Es. nel campo delle telecomunicazioni ma anche dell'emittenza radio televisiva

Restano in piedi perché non sono strutturalmente incompatibili con il Trattato di Roma, quello che però accade progressivamente è l'espansione dell'area di attività delle istituzioni europee e l'espansione dell'area di intervento del diritto comunitario, finalizzato a rendere effettive le libertà fondamentali previste nel Trattato, cioè a rendere effettiva la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali ecc..

Il punto è che, noi possiamo anche avere un Trattato internazionale che dice che i produttori di qualsiasi cosa possono vendere dove vogliono in giro per l'Europa, ma se poi ci sono delle regole che Stato per Stato fissano dei parametri specifici sulla vendita all'estero, allora questa libertà di vendere all'estero tende ad essere teorica, perché i costi di adeguamento dei prodotti Stato per Stato possono rendere impraticabile la loro vendita oltre i confini. Allora quando ci sono questi problemi le istituzioni europee, in virtù dei poteri che possiedono grazie al Trattato, possono intervenire. In particolare per dettare delle norme di armonizzazione dei vari diritti e ordinamenti nazionali grazie alle quali sarà effettivamente più semplice per le

imprese di un paese vendere i propri prodotti indifferentemente ai consumatori nazionali o a quelli stranieri.

Una tendenza è che l'attività di regolazione viene attratta sempre di più a livello europeo, un'altra, che emerge dal livello europeo è quella, nel corso del tempo, di dettare regole che in alcuni settori mirano allo smantellamento dei monopoli pubblici nazionali in favore dell'apertura del mercato alla concorrenza.

Il diritto europeo costituisce il secondo livello da prendere in considerazione quando si ragiona sul tema dell'accesso al mercato.

Diritto internazionale

Quando parliamo di mercati possiamo pensare a diversi mercati: nazionali, europeo, ma anche quelli internazionali. Quello che troviamo a livello internazionale è principalmente il sistema che è stato sviluppato nel corso del tempo per governare gli scambi internazionali che trova oggi il suo compimento nell'Organizzazione mondiale del Commercio.

Questa Organizzazione è stata costituita negli anni '90 del '900 sulla base dell'esperienza pregressa dell'Accordo Generale sulle Tariffe nel Commercio Internazionale.

All'organizzazione mondiale del commercio accedono molti paesi del mondo che si impegnano a rispettare e accettare una serie di regole relative agli scambi commerciali internazionali e che ottengono in cambio il beneficio, per gli operatori economici che si sono stabiliti dentro i loro confini nazionali, di poter esportare le loro merci verso gli altri Paesi aderenti senza soggiacere a restrizioni particolari. In sostanza i Paesi che partecipano a questa Organizzazione, partecipano ad un sistema nel quale, in linea di massima, esiste una certa libertà di esportazione delle merci da un paese aderente verso un altro. Libertà che è condizionata dalla possibilità che vengano applicate delle tariffe o dei dazi all'importazione, ma con l'idea che questi dazi debbano tendere a zero. Laddove vi sia libertà di esposizione e vi sia riduzione a zero dei dazi doganali ciò che ne risulta è il conseguimento di un grado elevato di libertà di commercio. Tra le regole che governano questo sistema troviamo il **principio della Nazione più favorita**:

Accordo in base al quale uno Stato si obbliga a concedere ad altro Stato le

condizioni più favorevoli che esso pratica in una determinata materia, di solito commerciale e doganale.

Questa regola fa sì che le condizioni economiche all'importazione, praticata da un Paese membro, siano le stesse che valgono quale che sia l'origine commerciale dei prodotti importati.

All'interno di questo sistema c'è anche la regola per la quale se uno Stato non rispetta le regole del libero scambio internazionale, gli altri Stati possono applicare delle regole ritorsive.

Es. Durante la presidenza di Trump, egli ha deciso ad un certo punto di alzare i dazi doganali per i prodotti provenienti dalla Cina, in alcuni settori, e lo stesso fece con alcuni prodotti europei, dando vita ad una sorta di guerra doganale.

Nel senno dell'Organizzazione mondiale del Commercio queste discordie non dovrebbero succedere, a meno che non ci siano ragioni di parte.

Es. Trump rivendicava il fatto che la Cina non rispettasse determinate regole di quell'accordo.

Oggi è molto discussa, per quanto riguarda il rapporto tra Europa e Stati Uniti, la politica adottata negli Stati Uniti nelle settimane scorse di investire grandi quantità di denaro pubblico al fine della riconversione green dell'economia Americana, in generale questo è un atto ben visto a livello internazionale, il problema è che hanno deciso di concedere incentivi economici molto rilevanti a coloro che acquistano automobili poco inquinanti a condizione che siano fabbricate sul territorio americano. Gli europei, che non l'hanno presa bene, sostengono che questo non è in linea con il sistema di scambi internazionali nel quale si cerca di operare secondo delle regole che siano conformi veramente al libero scambio. Sull'altro versante gli Americani dicono che il diritto europeo sta evolvendo, nel senso di dettare delle regole applicate al mondo digitale, e in particolare alle piattaforme online, che sono soprattutto americane, regole che sono ritenute da essi impeditive, inoltre gli americani contestano gli europei da lungo tempo per aver dettato regole sulla tutela dei dati personali che ostacolano il loro trasferimento dall'Europa verso gli Stati Uniti. Queste sono contese che hanno a che fare con il commercio internazionale che si collocano diciamo nell'arco di questi rapporti consolidati che sono rapporti del diritto internazionale.

Ricapitolando

A *livello nazionale* vale il principio della libertà di iniziativa economica, fermo restando che la mano pubblica agisca all'interno dell'economia.

A *livello europeo* valgono le libertà fondamentali dei Trattati che mirano alla costruzione di un mercato interno concorrenziale, anche a livello europeo, tuttavia, è possibile l'intervento della mano pubblica sull'economia. In generale però, la tendenza a livello europeo è nel senso della liberalizzazione, del superamento delle regole nazionali che escludono in certi settori la concorrenza, o che comunque la limitano. Libertà di concorrenza a livello nazionale e a livello europeo non significa legge della giungla, significa che è possibile che il legislatore nazionale e il legislatore europeo dettano delle regole che devono essere rispettate da coloro che intendono operare sul mercato. Queste regole appartengono al campo della **regolazione**, quando si sente parlare di regolazione si parla di **regole che confermano l'esercizio di certe attività economiche**, sono per lo più dettate a livello europeo oggi.

Dal punto di vista del *diritto internazionale* dei mercati internazionali esistono degli accordi istitutivi dell'Organizzazione mondiale del Commercio che vogliono favorire il libero scambio, e quindi libera concorrenza tra imprese in diversi paesi.

Nel mondo di ieri, in cui vi era solo la dimensione offline, la possibilità che le imprese operassero soltanto a livello nazionale era la regola, si dava poi la possibilità che esse operassero anche su più mercati nazionali, si dava infine anche la possibilità che operassero su mercati globali.

- **Mercati globali:** la capacità di operare in questi mercati era ristretta solo alle multinazionali, che erano molto poche.

Con la rete le cose sono molto cambiate, oggi anche le imprese molto piccole grazie alla rete possono rivolgersi a consumatori che stanno ai quattro angoli del globo, ciò significa che le regole sviluppate nei corsi dei decenni e secoli per governare i mercati offline si sono trovate oggi (da anni) a fare i conti con l'evoluzione di mercati digitali che per loro natura non hanno confini tracciati lungo i confini degli Stati del mondo. I mercati digitali tendono ad essere globali e questo complica molto le cose, ponendo dei problemi che non possono essere affrontati come si affrontavano una volta.

Es. si pensi al commercio di beni fisici, ad esempio si pensi alle automobili, beni che possono essere spostati nel mondo con qualche difficoltà e costi, se pensiamo al commercio di questi beni possiamo immaginare che gli stati del

mondo possano dettare delle regole che limitino in vario modo la circolazione internazionale di questi beni, l'offerta sui mercati internazionali di questi beni.

Nei primi anni '90 non c'era la libertà di importazione in Europa di automobili provenienti da *mercati extraweb*, provenienti ad esempio sul Giappone, c'erano delle restrizioni quantitative: ogni anno non si potevano importare più di un tot di automobili dal Giappone.

Solo progressivamente sono state eliminate queste limitazioni, che, nel mondo offline potevano essere facilmente applicate. Oggi queste limitazioni sono ancora possibili in relazione a questi beni, ma mettere limiti sulle offerte di servizi in rete non si può fare.

Oggi è molto più complesso il governo dei mercati internazionali, con l'organizzazione mondiale del commercio si discute, dai primi anni '90, l'introduzione delle regole per il governo dei mercati digitali e il commercio elettronico, sono passati trent'anni e non si è ancora combinato nulla.

Dal punto di vista del diritto interno, questo tipo di diritto conta molto poco. Il diritto europeo conta molto di più ed è organizzato intorno all'idea della libertà di accesso ai mercati digitali.



C'è una direttiva del 2000, la **direttiva dell'e-commerce** (direttiva del commercio elettronico), appena riformata, che dice che chiunque voglia prestare un servizio alla società dell'informazione è libero di farlo. Questa è una regola che costituisce il precipitato del principio della libertà dell'iniziativa economica che è ispirato al diritto europeo. Essa è stata ripensata il 27/10, è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'UE un nuovo atto: **Digital services act**, cioè atto sui servizi digitali che riforma il diritto europeo applicabile al commercio online.

L'elemento più interessante di questo atto normativo riguarda l'introduzione di una serie di regole applicabili alle piattaforme digitali. Nelle norme iniziali di questo atto troviamo un principio secondo il quale questo regolamento e le norme in esso contenute, si applicano a tutti i prestatori di servizi della società dell'informazione a prescindere dal luogo in cui siano stabiliti, in Europa, America, Cina, India... quando dirigono i loro servizi verso il pubblico europeo.

E queste regole recano tutta una serie di prescrizioni, ci sono regole, quelle diciamo

con contenuto più oppressivo, che sono dettate per le piattaforme online per le piattaforme molto grandi: Amazon, Google, Ebay...

Coloro che offrono in Europa questo tipo di servizi sono richieste di fare tutta una serie di cose, ma l'aspetto più interessante è il fatto che gli sia richiesto di svolgere un'attività di valutazione dei rischi che i loro servizi procurano o possono procurare ai destinatari e alla società in generale e non solo, devono anche adottare delle misure di minimizzazione del rischio, attenuazione del rischio, devono redigere dei documenti in cui dicono quali sono i rischi e cosa loro fanno per attenuarli, documento che deve essere validato da un ente esterno indipendente (tipo le società di revisione) e poi sottoposto alle autorità europee nazionali di regolazione dei mercati digitali che vengono istituite proprio in virtù di questo nuovo regolamento. Queste autorità pubbliche valutano se le piattaforme in questione hanno ben lavorato nell'identificare rischi e strategie di mitigazione dei rischi, e se effettivamente hanno applicato le misure che hanno dichiarato di voler applicare. Se le piattaforme risultano inadempienti scattano delle misure sanzionatorie. Tutto questo viene fatto a difesa degli interessi diffusi e a volte degli interessi pubblici.

Es. eBay, Amazon → sono dei mercati digitali

Digital market bases, luoghi in cui tutti possono accedere alla piattaforma per offrire i propri beni.

Questo nuovo regolamento dice che queste piattaforme devono, per esempio, adottare delle misure per identificare nel modo più sicuro possibile gli offerenti, devono chiedere a coloro che vogliono vendere dei beni di identificarsi, di dire il loro nome, cognome, indirizzo, p. Iva... e poi la piattaforma deve anche verificare nei limiti del possibile che questi dati siano veri, perché si vuole ridurre il rischio che vengano venduti prodotti contraffatti, in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, ma anche di regole che hanno valenza dal punto di vista della tutela dei consumatori.

Es. vendita di farmaci falsi

Queste sono attività onerose che vengono imposte alle piattaforme di market. Perciò disposizioni di questo genere sono disposizioni che regolano. L'Europa è vista un po' come il territorio delle regole, e vuole applicarle anche a coloro che non sono europei, e questo non piace.

Con il Trattato di Roma del 1957 fanno il loro esordio, in Italia, regole che sono pensate per assicurare che il mercato conservi, quando presente, la propria struttura concorrenziale, è possibile che non ci sia struttura concorrenziale perché il Trattato

di Roma non è incompatibile con l'esistenza di Monopoli pubblici, e dunque quando c'è il monopolio pubblico non c'è il mercato.

Il Trattato di Roma contiene anche regole che sono volte a fare in modo che il mercato interno conservi la propria struttura:

- **Regole sugli aiuti di Stato** → ***gli Stati membri non possono introdurre delle regole che accordano benefici in modo selettivo alle imprese stabilite sul loro territorio.***

Es. gli incentivi eco-bonus per la sostituzione delle automobili. L'Italia ha attualmente in essere dei piani pensati per sostenere le persone che intendono comprare un'auto in bonus, ciò significa che lo Stato ha preso un po' delle sue risorse e le ha investite in questa attività di incentivi, quindi chi vuole comprare un'automobile sa che lo Stato metterà qualche migliaio al posto suo. Queste sono regole che avvantaggiano i consumatori e i produttori delle automobili, se queste regole dicessero che l'eco bonus può essere utilizzato per utilizzare le auto che siano fabbricate in Italia avremmo un ***aiuto di Stato selettivo***, cosa che dal punto di vista del diritto europeo non è lecita, e spiega il perché quando gli Stati introducono delle regole di questo tipo non possono configurare in modo tale da aiutare più i propri produttori di automobili rispetto ai produttori stabiliti in altri Stati membri.

- **Regole antitrust** → ***introducono un divieto sulle intese, orizzontali e verticali, limitative della concorrenza.***

Dicono che le imprese non possono fare cartelli, cioè non possono accordarsi tra loro per non farsi concorrenza. Si pensi al cartello delle imprese assicuratrici che l'assicurazione RCA non può aver un prezzo inferiore a x, questa è un'intesa restrittiva (*intese orizzontali*), poi ci sono le *intese verticali* in cui imprese che operano a livelli diversi si accordano per limitare la concorrenza. Si pensi al produttore di patatine che si accorda con un'impresa di supermercati affinché non vengano vendute altre patatine se non le loro, un'intesa di questo genere è verticale perché non sono imprese in concorrenza tra di loro, ma comunque si accordano per restringere la concorrenza sul mercato.

- **Regole antitrust** → ***introducono il divieto di abuso di posizione dominante***

È un divieto che si applica alle imprese talmente forti sul mercato da poter adottare dei *comportamenti liberi*, non costretti dalle leggi del mercato. L'impresa in posizione dominante è un'impresa che ha una forza sul mercato di certi prodotti e servizi tanto elevata da poter dominare. All'impresa che si trova in questa posizione sono imposti una serie di divieti che valgono solo per essa e

che sono diretti ad evitare che l'impresa abusi di questo suo potere, non c'è un divieto per le imprese di rafforzarsi o acquisire una posizione dominante, o finalizzate a diventare monopoliste (se ci riescono), semplicemente si cerca di limitare l'abuso di potere da parte di queste imprese dominanti sul mercato.

- **Regole antitrust** → ***introducono il divieto costituito dalla disciplina della concentrazione.***

È un'insieme di regole che restringono la possibilità per due imprese di sposarsi, cioè di cessare di operare in concorrenza tra di loro e invece di concentrarsi, fondersi. Quando dalla concentrazione di due imprese possa derivare una restrizione significativa della concorrenza sul mercato interno, la commissione europea può vietare questa fusione oppure porre condizioni.

Es. cedere certi rami dell' attività a terzi

Disciplina che dice che la posizione di infante sul mercato non si può acquisire tramite la concentrazione di due imprese.

In materia di mercato, non sul piano della tutela della struttura del mercato ma su quello della tutela della lealtà dei rapporti concorrenziali troviamo un altro set di regole in materia di **concorrenza sleale**, queste regole dicono che:

Gli imprenditori in concorrenza tra di loro possono, anzi alla luce del diritto di antitrust, devono farsi concorrenza però non devono "esagerare" nel senso che nel contendersi il pubblico dei consumatori non devono adottare strategia concorrenziali leali, niente "colpi bassi".

Sono regole, quelle sulla lealtà concorrenziale, antiche: nella nostra legge la norma di riferimento è l'articolo 2598 del cc che è stato introdotto nel 42 col codice unificato, ma prima ancora c'era già una norma internazionale, che dagli anni venti del novecento prevedeva già delle disposizioni in materia. Queste norme sulla concorrenza sleale sono norme che hanno a che fare con l'illecito civile, articolo 2043cc.

Disciplina della concorrenza sleale

L'Articolo 2598 è una norma introdotta nel nostro ordinamento col codice civile nel 1942, è una delle novità del cc unificato. Essa indica gli elementi costitutivi di un fatto illecito che trova applicazione nei rapporti tra soggetti qualificabili come imprenditori e che si trovano in rapporto di concorrenza tra loro. È una norma speciale rispetto all'illecito civile nell'art 2043, perché entrambe hanno a che fare con il tema dei fatti illeciti, ma questa si applica solo alle controversie tra imprenditori in

concorrenza tra loro, cioè che operano su uno stesso mercato, o su mercati tra loro collegati.



Art. 2598 → Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1. usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2. diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3. si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

1. Prima fattispecie, ipotesi di concorrenza sleale che chiamiamo **confusoria**.
2. Ci sono due diverse ipotesi di concorrenza sleale, quella **per denigrazione** e quella **per appropriazione di pregi**.

Prima che inizi il cc ci sono una serie di regole (*preleggi*) tra cui una regola che governa **l'interpretazione della legge**. Per definire il significato di una disposizione di legge bisogna fare appello al metodo di interpretazione della legge. La legge si interpreta avendo attenzione al **tenore letterale**, cioè bisogna vedere cosa dice la norma, analizzandone il testo, leggendone le singole parole e la loro concatenazione e cercando di evincere il senso della disposizione. Dopodiché la norma va interpretata in chiave sistematica, cioè tenendo conto delle linee generali del sistema giuridico in cui si collocano le norme, così facendo alcuni elementi diventano più comprensibili.

Da questa disposizione, possiamo ricavare che **l'inciso iniziale non è molto chiaro**: “Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto”. Non è tanto chiaro in che modo dobbiamo tenerne conto.

- **Segni distintivi:** in questo inciso si parla di segni distintivi **d'impresa** (perché è una norma che parla di impresa), la norma non lo dice espressamente ma è il contesto che ce lo dice. Ma non ci sono solo i segni distintivi d'impresa, sulla carta d'identità c'è il segno della Repubblica italiana (quindi segni distintivi **dello Stato**), c'è la firma propria (segni **della persona**) e quella del sindaco. Tutto ciò vuol dire che questa norma non parla dei segni distintivi della persona ma solo di quelli dell'impresa.
- **Segni distintivi d'impresa:** segni distintivi utilizzati da soggetti che operano nel mercato svolgendo un'attività economica organizzata, professionale:
 - **Tipici** → sono previsti e disciplinati dalla legge espressamente con norme ad hoc, la legge disciplina espressamente il **marchio registrato**, **la ditta**, **l'insegna**, il **nome a dominio aziendale**.

La legge menziona anche il **marchio non registrato** senza dettare però una disciplina compiuta. La **disciplina dei marchi d'impresa** è contenuta negli articoli da 7 a 28 del **codice della proprietà industriale**, in cui troviamo una definizione di quali segni sono registrabili come marchi di impresa e troviamo l'indicazione di qual è la funzione dei marchi d'impresa, tale funzione è quella di contraddistinguere i prodotti o i servizi immessi in commercio da una certa impresa in modo tale che i consumatori possano fare affidamento su quel segno (il marchio) per riconoscere prodotti o servizi che hanno origine da quella certa impresa, dunque **il marchio è il segno distintivo dei prodotti/servizi di un'impresa**. Se il marchio è registrato è assoggettato ad una disciplina completa, specifica, dettata dalla legge.

La ditta è il segno distintivo dell'imprenditore, è il nome commerciale dell'imprenditore, un segno che egli si sceglie per contraddistinguere la propria attività sul mercato. **L'insegna è il segno distintivo dei locali** presso i quali è esercitata l'impresa, il **nome a dominio aziendale** è la parola con una certa terminazione (".com/.it/.de") che semplifica agli utenti il compito di trovare il luogo su internet di una certa impresa. Ciò consente di capire cosa può voler dire l'inciso iniziale della norma 2598: può voler dire che probabilmente ci sono le norme su segni distintivi tipici e allora se ci dovesse essere una controversia che riguarda questi segni distintivi tipici bisogna andare a vedere quelle norme

Es. se c'è una contesa su un marchio registrato, questo inciso può voler dire che si applica la disciplina del marchio registrato, e quindi bisogna seguire le regole di questa disciplina.

Cosa sono i **brevetti per invenzione**: è un diritto che si ottiene attraverso il completamento della procedura, che si chiama procedura di brevettazione, ed è un

diritto che ha per oggetto un'idea inventiva di soluzione di un problema tecnico. Allora si può pensare che l'inciso iniziale del 2598 serva a dire che se sorgono contese circa l'appartenenza di un'idea inventiva queste contese devono essere risolte sulla base delle regole della procedura di brevettazione e non sulla base della concorrenza sleale.

- **Atipici**

Riflessione sui rapporti reciproci delle azioni del numero 1 ecc..

:

I numeri uno e due hanno ad oggetto delle ipotesi specifiche di concorrenza sleale nominate dalla legge, il numero tre, invece, ha le caratteristiche di una clausola aperta e generica.



La concorrenza sleale è l'illecito compiuto da chi compie, direttamente o indirettamente, atti che vanno contro ai principi della correttezza professionale.

La norma ci offre alcuni **esempi di atti contrari** ai principi della correttezza professionale. Non c'è nessuna norma che comincia elencando quegli atti contrari ai principi della correttezza professionale, l'unica cosa è l'elencazione di quei numeri uno e due del 2598, che è un'elencazione per forza di cose esemplificativa. Allora, come si fa a dire quale comportamento è contrario e quale non lo è ?

Es. arriva Tizio triste che dice che un suo concorrente, Caino, per cercare di buttarlo fuori dal mercato è andato a cercare uno dei suoi dipendenti, lo ha chiamato nei suoi uffici e gli ha promesso un sacco di soldi qualora avesse convinto gli altri dipendenti di Tizio a licenziarsi e andare a lavorare da Caino. Tizio allora si lamenta perché dall'oggi al domani non ha più dipendenti. **Che cosa può fare?** Si direbbe che c'è l'articolo 2598 ma non troviamo la soluzione nella disposizione numero 1, perché riguarda un'ipotesi diversa di concorrenza sleale; neanche nella numero 2, a meno che ci fosse denigrazione o che consideriamo i dipendenti come "pregi" altrui, ma non è così perché letta in prospettiva storica, questa norma, riguarda ipotesi diverse, si parla di pregi come di premi, resta quindi solo la numero 3 per trovare una norma che dia soddisfazione a Tizio. Dunque l'attività svolta da Caino è un comportamento contrario a quei principi? Non sappiamo.

Si ragiona per ipotesi: la prima deriva dal fatto che noi sappiamo che non ci sono norme che dettaglino questi atti contrari, la seconda ipotesi è che si deve verificare che non ci siano dei codici di autodisciplina che gli imprenditori in generale o gli imprenditori di un certo settore abbiano deciso di adottare.

Nel campo dei rapporti concorrenziali il **codice di autodisciplina** più importante, è il **codice dell'autodisciplina pubblicitaria**, molti anni fa è successo che non ci fossero delle regole nell'ordinamento giuridico italiano sulla pubblicità, l'unica norma che poteva in qualche misura intercettare il tema della pubblicità era proprio il 2598, che però ha delle limitazioni intrinseche che non la rendevano una disposizione adeguata per risolvere i problemi che stavano emergendo nella società per via della pubblicità commerciale. In questa fase lontana, si era sviluppato un uso troppo aggressivo della pubblicità commerciale nei confronti dei concorrenti e dei consumatori, a volte i concorrenti reagivano a volte no, ma reagire indica l'intervento di un giudice quindi di molti soldi. Allora gli operatori di quel settore iniziarono ad **autodisciplinarsi**, anche perchè altrimenti i destinatari sarebbero finiti per odiare la pubblicità e sarebbe intervenuto lo Stato reprimendola, reprimendo la nostra attività economica. Allora, le principali agenzie di pubblicità hanno istituito l'**istituto dell'autodisciplina pubblicitaria** al quale è stato affidato il compito di redigere un codice di autodisciplina pubblicitaria, e cioè un insieme di regole sulla pubblicità commerciale che gli operatori del settore della pubblicità si impegnavano a rispettare e a far rispettare indirettamente anche agli inserzionisti, cioè le imprese che utilizzavano le agenzie pubblicitarie e i mezzi per promuovere i propri prodotti e servizi.

Inoltre hanno anche insediato un **Giurì della pubblicità**, cioè un organo imparziale composto di esperti che sono chiamati a decidere sulle controversie relative al mancato rispetto del codice dell'autodisciplina pubblicitaria, una specie di giudice privato. E ancora, hanno istituito un organo specifico, il **comitato di controllo**, che ha il compito di farsi promotore dell'interesse pubblico di iniziative davanti al giurì nei confronti di coloro, che pur essendo vincolati al codice, lo violassero. In questo codice dell'autodisciplina pubblicitaria si trovano delle regole, in particolare quella secondo cui, ad esempio, la pubblicità dev'essere trasparente.

Chi viola le norme di autodisciplina:

- Chi faccia pubblicità ad esempio subliminale
- Chi faccia pubblicità ingannevole
- Chi faccia pubblicità cercando di far leva sui minori
- ecc...

Una serie di regole per preservare le proprie attività e un interesse generale.

Quando abbiamo **regole (codici di condotta)** che i concorrenti si sono autoimposti nei rapporti reciproci, abbiamo di fronte probabilmente degli esempi di **principi di correttezza professionale** che possono essere valorizzati anche all'interno del 2598 (3). Da tempo il legislatore europeo cerca di stimolare le società che operano nel mondo online ad adottare questi codici di autodisciplina, a vincolarsi a regole auto imposte nell'interesse generale della concorrenza. La violazione di quelle regole auto imposte diventano un illecito concorrenziale.

Ma per risolvere ancora il problema di Tizio, bisogna guardare ancora altrove.

In passato, uno studioso illustre della materia, ha fatto una ricerca (anni '70) empirica e sul campo sottoponendo alle imprese di alcuni settori in alcune aree geografiche, un questionario, chiedendo a ciascuna di queste imprese di rispondere dicendo se un certo comportamento dovesse ritenersi conforme o difforme ai principi della correttezza professionale. Una ricerca empirica fatta per cercare di vedere se gli imprenditori rispettano un codice morale condiviso, che pertanto possa essere valorizzato come fonte di principio di correttezza professionale attivabili nei sensi dell'articolo 2598 numero tre.

Questo studio è stato importante perché ha permesso di eliminare dal tavolo l'ipotesi per cui non è possibile ricostruire i principi della correttezza professionale indagando sulla morale degli imprenditori, poiché non ci sono dei principi veramente largamente condivisi ai quali fare riferimento.

Allora ci resta un **approccio intuitivo** che dev'essere verificato nel tempo, attraverso il meccanismo *trial and error*, cioè si prova e si vede se il risultato è un errore oppure no, in sede di rapporti con i concorrenti e in sede di verifica giudiziaria. Con l'esempio di prima è stata intuitiva la reazione. In questo modo si passa la palla al giudice, ma egli si ritrova col problema di dire se quel comportamento è conforme ai principi della correttezza leale o sleale, il giudice a sua volta dovrà necessariamente applicare quella norma interpretando il sentire sociale, cercando di interpretare come questo comportamento sia avvertito nella società nella quale egli vive e tenendo conto che la concorrenza tra imprese non è un ballo a corte, cioè non è un'occasione galante nella quale bisogna danzare insieme senza cercare di pestarsi i piedi. Viceversa è una lotta concorrenziale, il giudice deve ricordarselo, non per stringere la mano ai cattivi, ma perché sullo sfondo ci sono **interessi generali e individuali** da apprezzare con cautela.

Interessi individuali nella contesa tra Tizio e Caino:

- Interessi di **Tizio**:

- tenere aperta l'impresa
- prevalere sull'altro
- preservare l'organizzazione imprenditoriale che si è costituito allo scopo di prevalere sugli altri
- Interessi di **Caino**:
 - prevalere su Tizio
 - rubargli quote di mercato

Se sul mercato c'è concorrenza, ogni cliente guadagnato da un concorrente è un cliente perso per l'altro, per questo la concorrenza non può essere come un ballo a corte, perché il vantaggio egoistico conseguito da uno è per forza di cose un pregiudizio per un altro che concorre sul mercato. In questo senso, l'interesse di Caino non è censurabile: sta facendo il suo mestiere che è mettere in piedi un'organizzazione imprenditoriale efficiente per cercare di prevalere sul mercato (teoricamente), ma comunque si vede che Caino in questo caso ha scelto per prevalere su Tizio, non la strada dell'efficienza ma quella del "bombardamento" dell'impresa altrui.

Volendo analizzare gli interessi individuali coinvolti ci sono anche i **consumatori** e soprattutto i **dipendenti**, perché il loro interesse legittimo è guadagnare di più. Nel momento in cui si ipotizza un atto di concorrenza sleale da parte di chi sta cercando di portare a sé i dipendenti di un altro, e diciamo che quel comportamento è vietato, noi stiamo mettendo i bastoni tra le ruote ai dipendenti i quali sono già in transito e col desiderio di diventare più ricchi. Anche su questa base il giudice deve valutare il caso concretizzando la clausola sulla correttezza professionale e la decisione che assumerà quel giudice varrà come "precedente" di quando dovesse porsi un domani una controversia dello stesso tipo. Quando la decisione del giudice viene resa pubblica, chi opera sul mercato saprà che secondo il giudice "x" nel caso "y" quel tipo di comportamento può essere conforme o difforme in rispetto dei principi della correttezza professionale. Allora man mano che si accumulano le decisioni in relazione a contese analoghe emerge una regola non scritta che costituisce il succo di questi principi della correttezza professionale e che si candida ad essere applicata in futuro.

Caso di Storno di dipendenti

Il caso in cui un imprenditore storna i dipendenti di un suo concorrente, cioè li convince a cambiare casacca e a passare alle sue dipendenze. In questa decisione,

la Corte di Cassazione ha riaffermato ancora una volta il principio secondo il quale ***cercare di sottrarre a un concorrente dei dipendenti non è un'attività di per sé illecita***, è vero che l'imprenditore stornato si lamenta però l'imprenditore stornante in quel modo si è dotata di una risorsa umana utile per la sua organizzazione perchè gli imprenditori **devono** competere tra loro, e per il dipendente non è illecito farsi sedurre. Il problema nasce quando l'assunzione di dipendenti altrui sia uno strumento adottato dall'imprenditore non per arricchire la propria organizzazione ma per affondare quella altrui.

Es. non assumendo un solo dipendente ma assumendo tutti i dipendenti di un certo settore, e lo storno è anche illecito se l'azione non è giustificata.

Clausola 3 art. 2598



Art. 2598 clausola 3 → si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Dobbiamo analizzare chi commette “*direttamente o indirettamente*”, a volte l'autore dell'atto scorretto è direttamente l'imprenditore concorrente, ma altre volte può essere un soggetto complice dell'imprenditore

Es. un dipendente.

Si pensi alla ***concorrenza sleale denigratoria***, quella che si attua attraverso la comunicazione al pubblico volte a screditare il concorrente, si tratta di comunicazioni che possono essere fatte direttamente dall'imprenditore concorrente oppure indirettamente da un dipendente, oppure può essere un cliente, che pensa bene di andare in giro a screditare i concorrenti del suo fornitore.

Ci resta da vedere l'ultima parte “*l'atto deve essere idoneo a danneggiare l'altrui azienda*”.

Questa disposizione è interessante perché ci dice due cose diverse simultaneamente:

- Anzitutto ci dice che **non è un atto di concorrenza sleale l'atto che non reca danno all'azienda altrui**
- Allo stesso tempo ci dice qualcosa che costituisce uno degli elementi di specificità della disciplina dell'illecito concorrenziale rispetto alla disciplina dell'illecito civile:



art. 2043 c.c. → la responsabilità da illecito civile sorge solo e soltanto quando vi sia un danno prodotto da un comportamento doloso o colposo quando questo danno possa qualificarsi come ingiusto, senza danno non c'è responsabilità.

Il 2598 è diverso perché non occorre che l'atto ostile prodotto dal concorrente abbia prodotto un danno, è sufficiente che sia idoneo a produrlo. La tutela è avanzata, i rimedi che possono essere attuati ai sensi dell'art 2598 intervengono già in un momento nel quale non c'è ancora il danno, ma solo il pericolo di danno.

Es. si pensi ad un imprenditore che invita a cena il dipendente di un altro concorrente con l'obiettivo di estrapolare dei segreti che riguardano il concorrente. Anche se non dovesse realizzarsi il danno (cioè l'estrapolazione dei segreti) il comportamento è colpito dal 2598.

I **rimedi** che possono essere utilizzati a fronte di una violazione dell'articolo 2598 sono indicati alle **norme 2599 e seguenti**. Il principale di questi rimedi è costituito dall'**ordine inibitorio**, cioè *dalla possibilità di chiedere al giudice di inibire/vietare nello specifico al concorrente di portare al termine o continuare l'atto di concorrenza sleale*. L'ordine inibitorio può essere accompagnato da delle **penalità di mora**, cioè nel momento in cui il giudice dice di non portare a termine questo atto, condanna già il convenuto a pagare delle somme in denaro, in vantaggio dell'imprenditore che ha agito in giudizio, per ogni giorno di ritardo o per ogni ripetizione del comportamento illecito, come se fossero delle multe che devono essere pagate al concorrente che patisce questi atti di concorrenza sleale.

Dunque, questa è una disciplina che ha una soglia di intervento anticipata rispetto all'illecito civile.

Aspetti delle disposizioni (1) e (2)

Il **numero uno** vieta tutti gli atti di concorrenza che in qualche modo mirano a generare **confusione tra i prodotti, servizi e attività propria con prodotti, servizi e attività di un concorrente**.

Es. una società che fa prodotti simili ad un'altra ma che non ha lo stesso successo può adottare certe strategie di marketing che mirano ad indurre in

confusione il consumatore, facendogli credere che quando compra i prodotti dell'impresa minore sta comprando i prodotti di maggior successo.

Una delle modalità principali per mandare il consumatore in confusione è adottare **segni distintivi confondibili** con i segni distintivi del concorrente,

Es. adottare parole simili oppure parole diverse ma con grafica uguale. → **strategia di concorrenza sleale.**

In generale, la materia dei segni distintivi, ma soprattutto la materia dei **marchi**, è oggetto di regole specifiche, in particolare se il marchio è stato registrato, non si applica la disciplina che si trova nel 2598 n.1 ma quella che si trova negli **art. 7-28 del codice della proprietà industriale.**

Nel **2598 numero uno** allora resta la tutela dei marchi di fatto, cioè i **marchi che l'imprenditore decide di utilizzare senza registrarli.** Questo significa che i concorrenti sono soggetti al divieto di adottare un segno identico o simile a quello che si è scelto chi è arrivato prima di loro quando da questa somiglianza possa derivare confusione dei consumatori. Dunque questa protezione diventa tanto più ampia quanto maggiore è l'uso che l'imprenditore fa del segno e quanto più è ampia l'area geografica nella quale lo utilizza.

Es. se qualcuno dall'altra parte dell'Italia apre una panetteria con lo stesso segno distintivo della panetteria di Torino che però non ha il marchio registrato, quello dell'altra parte dell'Italia non compie un'attività illecita, perché non c'è pericolo di confusione → è inverosimile che chi va a prendere il pane a Siracusa si confonda credendo di andare a comprare il pane alla famosa panetteria di Torino. Tuttavia, se il marchio fosse stato depositato, quindi l'imprenditore gode del codice della proprietà industriale, l'imprenditore avrebbe una protezione che si estende automaticamente all'intero territorio nazionale, anche se il marchio è usato solo a Torino.

Sempre nella condizione 1, troviamo **“l'imitazione servile” dei prodotti del concorrente**, che vuoi dire imitare servilmente. Questo elemento è importante perché mette a fuoco il fatto che questa norma, nel momento in cui vieta l'imitazione servile, non vieta in generale l'imitazione dei prodotti altrui, ma soltanto l'imitazione che sia idonea a creare confusione.

Non può esserci concorrenza se gli imprenditori non possono fare prodotti tra di loro sostituibili, cioè non ci sarà mai

concorrenza di prezzi se i concorrenti non fossero legittimati a fare i prodotti sostituibili, a copiarsi.

Dunque, solo eccezionalmente non si può copiare. Una prima ipotesi è il caso nel quale la forma dei prodotti del concorrente sia particolare, singolare, al punto da essere percepita dai consumatori sul mercato come tratto caratteristico e distintivo proprio e soltanto nei prodotti che vengono da una certa impresa.

Se la forma non ha queste caratteristiche non gode della protezione dell'articolo 2598 n.1 e pertanto è liberamente imitabile.

Non capita molto spesso che venga riconosciuta questa violazione, proprio perché non accade tanto spesso che la forma sia così tanto originale/iconica agli occhi dei consumatori da risultare distintiva.

Es. il tubetto originale delle pringles, il profumo originale a forma di scarpa, la forma delle automobili

Ultimamente, la giurisprudenza ha detto che anche copiare i minimi dettagli più insignificanti è un atto contrario ai principi della correttezza professionale.

- Un caso riguarda i motori a scoppio per le macchine tagliaerba, sembra che ci sia un motore Honda particolarmente efficace che esiste da 40 anni che venga copiato da tutti, il che in generale è legittimo ma uno che ha copiato tutto, ma proprio tutto, anche i difetti, non è più legittimo.

Un'altra situazione in cui la giurisprudenza tende a sanzionare forme di imitazione non confusoria si ha con la **concorrenza parassitaria**: forma di concorrenza non espressa espressamente nel 2598. Si tratta di una *forma di concorrenza che si attua ponendosi sistematicamente sulla scia del concorrente*.

Es. il concorrente fa le merendine a forma di mattoncino → lo fa anche l'altro, il concorrente fa qualcosa e l'altro sistematicamente lo copia. Quando si ha un'ipotesi di questo tipo, la giurisprudenza dice, è vero che si possono imitare prodotti, servizi e attività, ma se uno imita sempre e solo lo stesso concorrente sistematicamente nel tempo allora è considerato illecito.

Articolo 2598 numero 2

Caso che ci aiuta a capire.

Es. qui è successo che un concessionario di auto usate, aveva proposto in vendita una Mercedes con un tot di km percorsi (la truffa più ricorrente è il tarocco dei km), questo rivenditore ha tirato indietro i km.

Un post su facebook può qualificarsi come un atto di concorrenza sleale per denigrazione ? Un eventuale verità dei fatti affermati nei post scrivino rispetto alla concorrenza sleale? Cioè se il soggetto al quale viene addebitata la denigrazione possa difendersi efficacemente dicendo “ma io ho solo riferito al pubblico la verità” ?

Per rispondere a queste domande, il tribunale di Roma, rifacendosi alla Cassazione, dice che **in generale la concorrenza sleale per denigrazione è configurabile anche quando l'informazione che viene divulgata al pubblico è veritiera**. Però se le informazioni che sono state divulgate sono veritiere e i toni che sono stati adottati nel riferire le informazioni al pubblico sono accettabili (se si tratta di toni “garbati”) , allora non c'è concorrenza sleale per denigrazione, se invece l'informazione viene divulgata con toni sgarbati/sensazionalistici allora non va bene, nonostante la verità delle informazioni veicolate, perché si vuole che la concorrenza resti comunque dentro un ambiente di civiltà.

Quando si fa pubblicità comparativa, cioè si pubblicizzano i propri prodotti comparandoli con quelli del concorrente, per fare in modo che questo tipo di pubblicità sia lecito ai sensi della norma 2598 e ai sensi della disciplina specializzata nella comunicazione commerciale, è necessario che la comparazione sia veritiera, cioè deve rispondere a delle prove che sono state fatte che indicano appunto oggettivamente questa superiorità, poi occorre anche che questa comparazione sia condotta con toni che non siano capaci di ledere l'apprezzamento, l'immagine del concorrente e dei suoi prodotti.

Disciplina della proprietà intellettuale



Insieme di diritti legali volti ad assicurare la tutela delle creazioni della mente umana in campo scientifico, industriale e artistico.

Possono essere protetti da p.i. invenzioni, lavori letterari e artistici, simboli, nomi, immagini e disegni.

Quando si parla di proprietà intellettuale si intende un insieme di istituti giuridici che hanno per oggetto una varietà di **beni immateriali**, che tengono in considerazione la

loro dimensione intangibile, il cui utilizzo tende a essere riservato al titolare del diritto in questione.

Es. un'idea, e un'idea esiste ma non si tocca.

Anche quando si parla di un oggetto materiale, se lo consideriamo nella prospettiva della proprietà intellettuale, non ci interessa l'oggetto in sé, fisico e tangibile, ci interessa l'**opera dell'ingegno che è incorporata nell'oggetto**. L'oggetto del diritto non è il bene fisico, ma è l'opera dell'ingegno incorporata al bene. *Questo vale per tutti i diritti di proprietà intellettuale*, sono diritti che hanno a che fare con opere, idee e creazioni che sono entità intellettuali incorporate ai beni fisici/tangibili.

Di solito, i diritti di proprietà intellettuale attribuiscono all'autore l'esclusiva dello sfruttamento del bene materiale, oggetto del diritto.

Es. se un certo quadro è oggetto del mio diritto perché ne sono l'autore, quello che ottengo dall'ordinamento giuridico è il diritto esclusivo di utilizzare nell'attività economica quel quadro, inteso non come bene fisico ma come creazione intellettuale. Il che significa che anche se vendo a qualcuno quel quadro, quel bene fisico non è più mio; io, autore, conservo il diritto di controllare le riproduzioni di quel quadro e se qualcuno lo prende e ne fa una copia, perciò questo diritto non è del nuovo proprietario a cui ho venduto il quadro, poiché lui è solo il proprietario del bene fisico non l'autore e **solo** l'autore può fare causa a chi ne ha fatto una qualsiasi forma di riproduzione che implica un'appropriazione del bene immateriale in quanto l'opera dell'ingegno che è incorporata al bene.

Ragioni che consigliano/sconsigliano la protezione dei beni immateriali

Le tre principali categorie di beni immateriali protette del nostro ordinamento giuridico:

- **Invenzione** → lampadina, qualcosa che non si trova in natura.

Un'invenzione va sempre più ad affinare col tempo i propri utilizzi e tecniche.

La storia della lampadina ci insegna che per arrivare al prodotto che conosciamo serve molto tempo e il lavoro di tante persone e che è importante avere un'idea o un'intuizione che bisogna sviluppare ed inoltre sono necessari anche tanti investimenti.

Un altro aspetto è che nello stesso arco di tempo è possibile che ci siano più persone che studiano la stessa cosa e che arrivano a risultati comparabili, perciò chi prende il brevetto si prende tutto il merito, mentre gli altri no.

Ragioni per cui è una buona idea dare dei diritti a chi si inventa qualcosa e perché questa stessa idea può presentare dei risvolti negativi.

Costi e benefici della tutela delle invenzioni:

- Per la **tutela del lavoro inventivo**
- Per **incentivare** il lavoro inventivo essendo l'inventore, in un regime di concorrenza, colui che ci guadagna di più. Dunque per l'inventore l'incentivo è quello di poter provare ad estrarre dal mercato, per tutta la durata del brevetto, il sovraprofitto monopolistico. → **interessi patrimoniali**
- Per la tutela degli inventori per **interessi morali**

Il motivo per cui, dal punto di vista della collettività, può aver senso attribuire diritti all'inventore sulle sue invenzioni è perché la scienza e la tecnica progrediscono in questo modo. Dunque, incentivare significa "dare per avere", cioè io do all'inventore dei diritti e dei benefici per poi avere in cambio il progresso nell'interesse generale.

Ovviamente, non ci sono solo ragioni che giustificano la concessione della tutela, ci sono anche ragioni che inducono quantomeno a stare attenti nel calibrare questa tutela che si dà agli inventori.

- Uno degli incentivi per l'inventore è fissare un prezzo come se fosse un monopolista, ma il **costo del monopolio** sta nel fatto che il prezzo si colloca ad un livello più elevato sulla curva della domanda e quindi reprime l'interesse della società → si riduce la quantità dei prodotti e si riduce la domanda da parte dei consumatori.
- Un altro aspetto è legato ai rapporti tra innovatori successivi, bisogna stare attenti nel calibrare la remunerazione per l'inventore e gli incentivi, bisogna premiarlo il giusto perché se noi gli diamo un diritto sulla sua invenzione troppo ampio il risultato è che si creerà un **disincentivo ad innovare in modo incrementale**, cioè si disincentiva ad apportare migliorie, per chi parte dalla sua invenzione. C'è il rischio che il progresso sia disincentivato, se tanto non si può godere dei benefici per le migliorie apportate all'invenzione originale.

Profili generali della proprietà intellettuale

Bisogna tenere in considerazione le ragioni degli inventori e dei terzi. Tenere in considerazione significa pensare a delle regole che tutelino adeguatamente l'inventore, stimolando l'attività inventiva e gli investimenti di ricerca e sviluppo, ma che al contempo non riconoscano una protezione troppo ampia, estesa e lunga che andrà a pregiudicare gli interessi dei consumatori, tenendo conto interessi individuali

e generali (come il diritto alla salute) e della necessità di non bloccare l'innovazione, poiché sarebbe una contraddizione dell'obiettivo del sistema di incentivi del sistema brevettuale.

Istituti giuridici che tutelano le creazioni intellettuali:

- **Brevetto** → titolo in forza del quale si conferisce al titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento di un trovato, per un periodo di tempo limitato, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, disporne e farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati.
- **Diritto d'autore** → l'istituto che tradizionalmente protegge le creazioni non di carattere tecnico, ma intellettuali che appartengono al mondo del bello, non dell'utile, e quindi ***le opere dell'ingegno di carattere letterario e artistico che sono l'oggetto del diritto d'autore.***

Anche qui è bene interrogarsi su quali siano i costi e i benefici della protezione:

Dal punto di vista delle argomentazioni che giustificano la tutela alle opere dell'ingegno che garantisce il diritto d'autore, si possono collocare le stesse ragioni che troviamo nel campo delle invenzioni?

Quando si protegge un'opera dell'ingegno non si fa attenzione alla padronanza del mezzo espressivo da parte dell'autore e non abbiamo in mente l'unicità dell'opera intesa come manufatto, perché una volta fatta può essere copiata l'opera.

Es. da chi ha la stessa padronanza del mezzo espressivo.

Il diritto d'autore si interessa dell'opera intesa come frutto dell'attività creativa, in quanto bene immateriale e non solo come manufatto dell'artista. Quando si ragiona su un'opera dell'ingegno, si pensi ad una scultura abbastanza unica, naturalmente si ha a mente il manufatto che costituisce l'opera, ma dal punto di vista del diritto d'autore ci si interessa anche della sua dimensione immateriale, come opera incorporata in quella materia e suscettibile di essere riutilizzata. In altri termini, quando abbiamo qualcuno che fa una fotografia a quest'opera, abbiamo una persona che non realizza una copia del manufatto, poiché la foto non è sostituibile all'oggetto, ma ciò nonostante fa una riproduzione dell'opera dell'ingegno costituita dalla scultura. Si appropriava, la fotografia, in quanto riproduzione del contenuto creativo che c'è in quel oggetto, e quindi una riproduzione dell'opera senza essere una riproduzione del manufatto sostituibile al manufatto originale. **Il diritto d'autore**

si interessa anche del manufatto, ma il diritto sul manufatto deve essere separato concettualmente dal diritto sull'opera incorporata al manufatto, questa distinzione concettuale, tra manufatto e opera dell'ingegno incorporata al manufatto, serve a distinguere la disciplina dell'oggetto dalla disciplina dell'opera incorporata nell'oggetto.

Es. si pensi al momento in cui l'autore pensa a quale scultura rappresentare, nel momento della creazione dell'opera, per il diritto civile l'autore è proprietario dell'oggetto perché specifica la materia prima (prendo un pezzo di marmo e lo trasformo nel David⁹). Anche se la materia che si usa non è propria, l'opera finale sì, la si specifica e quindi l'autore né è il proprietario. Però il diritto che ottiene non è solo quello di proprietà ma è anche il diritto sull'opera in quanto bene immateriale, questo significa che l'autore può anche decidere di vendere la propria scultura. L'acquirente compra la scultura, compra l'oggetto, e di questo oggetto potrà fare uso come ritiene, per lo meno in ambito privato, potrà decidere di metterla nel cortile, o in uno spazio pubblico... ma comunque nei limiti dell'uso privato.

L'autore quando cede l'esemplare dell'opera perde il proprio diritto di proprietà su quell'opera, poiché lo acquista l'acquirente, normalmente però, **l'autore conserva il diritto d'autore su quell'opera**, e questo gli dà certe prerogative:

- Conserva la prerogativa di vedersi riconosciuto il **diritto di paternità** → non si può vendere il diritto morale d'autore
- Conserva il diritto di **sfruttare economicamente** l'opera in questione → es. autorizzando la riproduzione in copia
- Se poi l'acquirente della scultura decide di rivenderla, l'autore ha la pretesa, che si chiama **diritto di seguito**, di ottenere un pezzo del prezzo di rivendita di questa scultura, e il diritto sull'aumento di valore dell'opera in occasione di successiva alienazione.
- Inoltre l'autore conserva il **diritto di sfruttarla anche attraverso la riproduzione digitale**, l'uso dell'immagine dell'opera per rendere servizi di qualsiasi tipo → es. per abbellire un sito web, una campagna pubblicitaria...

Altre argomentazioni che giustificano la tutela da parte del diritto d'autore sono:

- Esigenza della tutela del lavoro creativo
- Esigenza di premiare il progresso nel mondo delle arti
- Esigenza di incentivare la creazione di opere intellettuali

Il diritto d'autore serve per stimolare gli autori, stimolare l'attività creativa, incentivarli, consentendo loro di poter vivere del loro lavoro, attraverso lo sfruttamento dei diritti esclusivi che compongono il contenuto del diritto d'autore, si tratta quindi di una soluzione vantaggiosa anche per la società, poiché il diritto d'autore è uno strumento che incentiva i creativi rimettendo il giudizio, circa la qualità del lavoro svolto dagli autori, al mercato (sistema preferibile a quello antico → il mecenatismo).

Non ci sono dunque molte differenze tra le argomentazioni della tutela degli inventori, di mezzo non c'è più l'utilità materiale, ma il gusto del pubblico. Un ulteriore elemento che troviamo è quello relativo alla **libertà di espressione**, creare un sistema di incentivi che sostenga la creatività di qualunque tipo senza qualcuno che dica cosa va o non va sostenuto. Inoltre vi è un'esigenza più forte della tutela della personalità di chi crea, nel senso che l'opera dell'ingegno letteraria o artistica si ritiene che integri in sé un pezzo della personalità dell'autore, quindi è un po' come se l'autore specificasse se stesso in tante creazioni intellettuali, pertanto oltre al diritto di paternità, **si riconosce un diritto all'integrità dell'opera**, in alcuni ordinamenti anche quello di pentimento e cioè il diritto di ritirare l'opera dal mercato.

*Sul piano dei **costi** invece, sono paragonabili ai costi della tutela delle invenzioni brevettabili? No.*

È intuitivo pensare che **i costi del monopolio qui siano inferiori**. Questo è uno dei tratti caratteristici del ragionamento sul diritto d'autore. Tradizionalmente, questa è una tutela che preoccupa di meno rispetto all'attribuzione di diritti esclusivi alle invenzioni, perché l'oggetto della protezione è sempre futile, nel senso che possederlo non è una questione di vita o di morte, ma se mi ammalo e non ho accesso a un farmaco è una questione più importante, questo spiega perché il brevetto delle invenzioni dura 20 anni al massimo, mentre la **durata della tutela del diritto d'autore dura per tutta la vita dell'autore e per altri 70 anni dopo la sua morte** (questo perché non ci sono grossi costi). Questa differenza è dovuta principalmente dal fatto che **il diritto dell'inventore/di brevetto ha ad oggetto l'idea inventiva**, cioè l'idea di soluzione del problema tecnico a prescindere dalla realizzazione pratica di questa idea, non il bene materiale che inventa.

Il diritto d'autore è opposto, non ha ad oggetto l'idea, **ha ad oggetto la forma espressiva** mediante la quale un certo autore ha scritto una storia, compiuto un'opera...

Si pensi ai vari romanzi che esistono: a seconda delle epoche storiche, i romanzi raccontano delle storie analoghe tra loro, a volte anche prescindendo dall'epoca, a

volte raccontano storie che ridotte all'osso hanno la stessa trama, il diritto d'autore non ha ad oggetto questo contenuto essenziale, ma soltanto le parole che sono state utilizzate dall'autore per raccontare quella storia. Il diritto d'autore è un istituto debole, perché impedisce ai terzi di copiare la forma rappresentativa, quindi si ferma un po' alla superficie e non va in profondità, per questo è un diritto che dura così tanto, perché ha un oggetto e un perimetro limitato, altrimenti non potrebbe permettere agli altri di raccontare la stessa storia cambiando le parole. Ma siamo sicuri che sia così?

- Es. 1 → Harry Potter → se qualcuno volesse raccontare un sequel lo potrebbe fare? No, a meno che riesca a farsi dare il consenso, stando ai principi in materia di diritto d'autore. Sarebbe meglio dire che la protezione dell'opera dell'ingegno però non riguarda proprio solo la forma espressiva esterna dell'opera, meglio dire che possa riguardare anche degli elementi ulteriori di creatività che trovano espressione in quella forma, si tratta di elementi di forma interna, cioè **elementi che costituiscono il frutto della creatività dell'autrice** e che non sono proprio idee, sono idee che sono state elaborate a modo proprio. Chi scriverebbe un sequel di questi romanzi non si approprierebbe di idee che sono utilizzabili da chiunque, ma della declinazione specifica creativa di quelle idee dovuta alla creatività dell'autrice JK Rowling (è successo che si sono formati dei gruppi fanfiction che si sono esercitati a scrivere dei sequel, ad un certo punto l'editore di JK Rowling aveva reagito facendo causa ad alcuni di questi, ma in una fase successiva l'autrice ha fermato tutto ciò dicendo che non poteva fare causa ai suoi lettori). *Dal punto di vista del diritto d'autore, la causa non sarebbe stata del tutto inutile, perché i personaggi di questa saga sono caratterizzati da costituire delle creazioni intellettuali di per sé che non possono essere ripresi da terzi tali e quali.*



Perciò il piccolo monopolio, che è attribuito dal diritto d'autore, è un monopolio che un po' di fastidio può dare alla creatività dei terzi.

- Es. 2 → il diritto d'autore non protegge solo i romanzi come quelli della Rowling, ma anche le creazioni di carattere scientifico, ad esempio i manuali di costruzioni (rispetto a queste opere bisogna stare attenti), bisogna cercare di evitare di passare dalla tutela della forma espressiva, e cioè l'insieme delle parole, immagini, schemi, formule e tutto il resto che è stato ideato dall'autore di questo manuale per spiegare come si costruisce un edificio, alle regole di costruzione dell'edificio, perché le parole possono essere appropriate, ma l'idea

che viene illustrata con quelle parole deve rimanere di pubblico dominio. Chiunque deve essere libero di scrivere un manuale di costruzioni alternativo a questo. Quando un testo è didattico, utilitaristico che spiega una materia scientifica questa distinzione tra forma e contenuto è un po' più difficile, poiché non ci sono dei grandi stacchi creativi nello spiegare queste materie, normalmente la creatività è molto limitata.

- Es. 3 → **Erich Auerbach "Mimesis, il realismo nella letteratura occidentale"**
→ *"Semplicemente il più bel libro che sia mai stato scritto sulla letteratura occidentale - e quindi, essendo il concetto di "letteratura" sommamente occidentale, il più bel libro in assoluto che sia mai stato scritto sulla letteratura. Non è neanche tanto difficile: procede per brevi citazioni da opere letterarie e cordialissimi commenti: Insegna a leggere, o scusate so è poco. Leggermente noioso nelle parti medievali (ma perché quasi tutta la letteratura medievale è ormai, per noi, irrimediabilmente noiosa)".* Questo esempio ci spiega che nell'amministrare il sistema del diritto d'autore, per configurare il sistema di tutela delle opere dell'ingegno, bisogna ricordarsi di lasciare delle finestre aperte, che sono le possibilità di fare certi riusi dell'opera altrui che sono positive, desiderabili, uno di questi è il riuso di parti di opere altrui per finalità di critica o di discussione, se la citazione di passi di opere letterarie per finalità di critica non fosse libera (come invece è), un libro come quello non sarebbe mai potuto esistere, oppure se fosse stato scritto sarebbe stato considerato illecito in quanto viola i diritti del diritto d'autore.



Dunque non è vero che il diritto d'autore ha sempre effetti monopolistici escludenti irrilevanti, ci sono, ma bisogna che la legge sia in grado di limitare per un certo senso il diritto d'autore in modo da incentivare la produzione di altre opere, anziché disincentivare. **La libertà di citazione**

- Es. 4 → **Daniele Luttazzi, "Va' dove ti porta il clito"** → "Nel 1994 di Va' dove ti porta il cuore, quel «bestseller per zitello», Daniele Luttazzi scriveva la parodia, Va' dove ti porta il clito e per quella parodia Susanna Tamaro, autrice del libro, lo citò in giudizio per plagio. Il giudice assolse però il comico, argomentando che siccome trattasi di parodia, era ovvio che i due testi si somigliassero, allora la Tamaro ricorse in appello e non le andò bene neanche quello. Luttazzi, invece, decise di farne spettacolo teatrale, che a 15 anni di distanza non ha ancora perso il suo appeal dissacratorio e pieno di boutade". Questo è un esempio di come la giurisprudenza difenda la libertà di espressione e la libertà creativa (con

cui si possono fare le parodie), e queste costituiscono un limite alla tutela d'autore, ed è un limite che si traduce nella regola secondo la quale la parodia, che per forza di cosa implica una riproduzione estesa dell'opera, deve considerarsi una creazione sottratta al potere di opposizione dell'autore dell'opera parodiata, e questo perché in caso contrario non esisterebbe parodia.

In alcuni ordinamenti, come il nostro, per tanto tempo si è ritenuto che la parodia fosse proprio del tutto estranea alla tutela dell'opera originale, cioè si è sempre detto che non servisse una norma sulla legge del diritto d'autore che dica che si può fare la parodia di un'opera altrui perché la parodia non ha niente a che vedere con l'opera parodiata, è proprio un'altra cosa. Invece in altri sistemi europei si è puntata di più l'attenzione su questo aspetto della riproduzione mediante la parodia, poiché è una riproduzione, parziale, e non legittima, a meno che la legge preveda espressamente che si possa fare la parodia di un'opera altrui. ***Dunque si è detto che se si considera la parodia legittima è una scelta del legislatore.*** Nei sistemi più democratici, liberali la parodia è autorizzata perché serve ad una finalità creativa, non è un modo per offrire al pubblico un sostituto dell'opera originale, è un modo per offrire al pubblico un altro prodotto culturale, alternativo e siccome è espressione creativa per legge è legittima.

Questi esempi servono per spiegare che anche il diritto d'autore può creare dei monopoli.

Ecco un altro esempio di come il diritto d'autore possa risultare problematico per i suoi costi monopolistici.

- Es. 5 → opera di **Emilio Isgrò** → ha utilizzato come mezzo espressivo, nelle sue opere, non la parola ma la cancellata delle parole, ovvero cancella tutto quello che non serve per esprimere quello che lui intende esprimere, è una forma espressiva. La medesima tecnica espressiva di Isgrò venne riprodotta in una copertina di un disco di una band famosa, e Isgrò gli fece causa. Se ne discusse molto in Italia e la giurisprudenza ha ritenuto che effettivamente ci fosse una violazione dei diritti d'autore, soluzione molto opinabile ma che può fare capire come il diritto d'autore possa far passare facilmente la forma espressiva in linguaggio espressivo, quando quest'ultimo sia innovativo. L'autore qui non ha rivendicato protezione per un'opera specifica, ha rivendicato protezione per l'idea di creare attraverso le cancellature → è forma o idea da proteggere ? Ma se diciamo che è forma espressiva è protetta dal diritto d'autore

e solo Isgrò può utilizzare questa forma espressiva per esprimere ciò che vuole per 70 anni oltre la sua morte.

- Es. 6 → **i tagli di Fontana** → anche in questo caso si discute sulla forma espressiva, la forma espressiva è una tela squarciata, così minimalista che se noi diciamo che questa forma è protetta significa che nessun altro può più esprimersi tagliando le tele. È lo stesso esempio per i quadri di Rothko, con colori giustapposti, la forma espressiva è così scarna che ci si dovrebbe chiedere se nel caso in cui qualcuno dovesse fare un altro quadro associando dei colori diversi dai suoi, siamo di fronte alla violazione dei diritti d'autore oppure no. O se interpretiamo la tutela in termini molto restrittivi, è violazione solo l'abbinamento cromatico che utilizza l'autore oppure intendiamo violazione l'idea di associare tutti i colori in questo modo? Così facendo però attribuiamo all'autore un protezione troppo ampia. Per non parlare della fontana di Marcel Duchamp, la forma espressiva è l'orinatoio al quale si è data dignità di creazione artistica. Qui si sta proteggendo un'idea, cioè l'idea di considerare un orinatoio come una fontana. Di fronte a queste opere artistiche diventa complicato distinguere la forma espressiva dal contenuto rappresentato.

Il diritto d'autore è stato esteso nel tempo per comprendere anche le opere dell'industrial design.

Es. la bicicletta pieghevole che si piega secondo uno schema che è stato oggetto di brevetto. Possiamo tutelare questa creazione di design anche col diritto d'autore? Non è una scultura, un quadro, è un oggetto utilitaristico.

Il problema della distinzione tra forma e contenuto, e il problema di contenere gli effetti monopolistici in questi casi si fa sempre più complicato. Una volta il diritto d'autore si applicava solo alle **opere artistiche, cinematografiche**, ma nel tempo è stato esteso a creazioni nuove, come la **fotografia**, perché non è solo riproduzione della realtà, e poi anche alle creazioni in cui prevale la matrice utilitaristica (software, banche dati) rispetto alla tutela delle creazioni che mirano unicamente a suscitare reazioni intellettuali. Dunque il diritto d'autore attuale è un istituto più difficile da trattare rispetto al passato, ed è un istituto che invoca una attenta applicazione delle regole esistenti al fine di evitare di creare inopportuni costi monopolistici e la protezione di aspetti anche funzionali che invece devono rimanere di pubblico dominio.

Marchi d'impresa

Uno degli esempi più evidenti è il segno della Coca-Cola, questo segno è un **marchio denominativo**, ma che ha anche una **valenza figurativa**, perché questa

parola è scritta in una certa grafia, ed è anche un marchio che ha valenza figurativa perché **associa parola e colore in una certa combinazione**.



È un marchio complesso fatto di elementi figurativi e denominativo e di colore.

Quali sono le ragioni che giustificano la protezione dei marchi?

I marchi d'impresa **non sono protetti** perché si vuole proteggere la creatività dell'autore del marchio, se il marchio è creativo per la sua forma potrà essere oggetto di diritto d'autore, e allora sarà quest'ultimo a proteggere la creatività del marchio, dunque il marchio è protetto per un'altra ragione.



Marchio protetto → al titolare del marchio di impresa sono dati diritti esclusivi di utilizzazione di quel segno distintivo in commercio.

Ragionando in prospettive dei vari soggetti, le motivazioni sono:

- **Prospettiva del consumatore** → il consumatore riconosce i prodotti perché hanno il marchio e il marchio può aiutare il consumatore a riconoscere i prodotti che hanno una certa qualità, magari aiuta ad acquistare di nuovo una bevanda che ha provato e gli è piaciuta.
- **Prospettiva del titolare del marchio** → al titolare del marchio interessa capitalizzare la reputazione dei propri prodotti, attraverso il messaggio che manda il suo marchio, vuole quindi consentire al consumatore di riconoscerli per fargli ripetere la scelta d'acquisto. È proprio questa la **funzione essenziale del marchio**, consentire ai consumatori di distinguere i prodotti o servizi in ragione della loro provenienza imprenditoriale.

La funzione essenziale del marchio serve al consumatore di ripetere le scelte d'acquisto soddisfacenti e alle imprese titolari dei marchi di guadagnare quote di mercato, serve a tutta la collettività per avere un mercato che funziona, cioè avere degli imprenditori più efficienti che vengono premiati ad esempio producendo meglio al prezzo più basso. Affinché il mercato funzioni bisogna evitare che ci siano marchi che inducono il consumatore a confondersi.

Il marchio **serve al consumatore a riconoscere i prodotti che cerca** ed è quindi uno strumento che semplifica l'acquisto e che serve naturalmente ad evitare acquisti

sbagliati.

Es. la Ferrari che produce sia auto importanti, sia profumi. Il marchio è un messaggero ed è in grado di veicolare certi messaggi qualitativi oppure pubblicitari.

L'idea è che il marchio possa godere di un certo apprezzamento del pubblico e quindi possa essere riconosciuto anche in relazione ai prodotti che non hanno niente a che fare con quelli rispetto ai quali il marchio ha guadagnato la sua reputazione. Il marchio Ferrari è famoso per le automobili, però questo suo accreditamento agli occhi dei consumatori è tale che questo marchio possa servire anche a vendere i profumi, il consumatore è attratto dal fatto che ci sia un profumo col marchio Ferrari che evoca le automobili sportive, oggi questo valore pubblicitario del marchio è protetto dalla legge, perché comunque si pensa che debbano essere protetti gli investimenti.

Istituti del diritto industriale

Caratteristica fondamentale che hanno in comune tutti gli istituti del diritto industriale, cioè gli istituti che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale. È un uso promiscuo di diritto industriale e diritto di proprietà intellettuale.



Il diritto industriale comprende i diritti sui beni immateriali.

Su questi beni immateriali la legge riconosce dei diritti esclusivi, cioè il titolare può escludere gli altri dalla libera utilizzabilità della cosa, il titolare, è colui che decide se gli altri possono utilizzare il suo bene immateriale oppure no, oppure se farsi pagare una quota. Questi diritti di proprietà intellettuale hanno in comune il **principio di territorialità**, cioè la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale è una disciplina territoriale, legata al territorio degli Stati. Significa che se pensiamo al diritto di proprietà sulle cose materiali, non abbiamo tanti problemi nel determinare quale disciplina statale sia competente a determinare chi è il proprietario della cosa, si guarda generalmente la legge dello stato in cui il bene si trova.

I beni immateriali non si trovano in alcun luogo, proprio per la loro caratteristica di immaterialità.

A quale Stato appartiene la legge che può disciplinare a chi appartiene un bene immateriale, se e in quali condizioni questo

bene può essere utilizzato da soggetti diversi dal titolare? Qual è la legge che protegge i beni immateriali?

C'è un principio, che esiste da secoli, secondo cui ogni stato è competente a proteggerli all'interno del suo territorio. Quindi l'Italia proteggerà la mia opera dell'ingegno relativamente al territorio italiano, quindi sarà la legge italiana a disciplinare quali sono i requisiti perché il mio romanzo possa essere protetto, quanto dura la protezione, quanto si estende il diritto mio sulla mia opera... tutto relativamente al territorio italiano.

Invece quello che accade, ad esempio in Francia è al di fuori della competenza italiana, se una utilizzazione che avviene in Francia rientra nel mio diritto esclusivo dovrò rivedere la legge francese, ma ancora prima anche verificare se il mio bene immateriale è protetto anche in Francia oppure no. **Quindi il principio significa che ogni stato è competente a disciplinare la protezione dei beni immateriali solo relativamente al suo territorio.**

In tempi molto lontani già si è posto il **problema delle ristampe**: io Italiano realizzo un'opera in Italia, ne acquisto il diritto d'autore in Italia e poi spero che mi proteggano anche gli altri Stati, perché se non mi proteggono, i terzi possono realizzare delle copie della mia opera all'estero e venderle lecitamente all'estero, con il rischio che questi beni vengano anche importati in Italia e che mi trovi in difficoltà a controllare la loro commercializzazione in Italia.

Es. nella prima metà dell'ottocento c'è stata una controversia importante che aveva visto contrapporsi Manzoni e un editore di Firenze. Manzoni aveva acquistato il diritto d'autore con i meccanismi che operavano allora in una parte di Italia ma non nel Gran Ducato di Toscana, e l'editore a Firenze aveva stampato una edizione dei Promessi Sposi senza il consenso dell'autore.

Questa situazione aveva fatto sentire l'esigenza di rendere, da un lato più prevedibile ai cittadini di uno Stato come sarebbero stati trattati all'estero, e dall'altro di garantire ai cittadini di uno Stato una minima protezione anche all'estero. C'è stata quindi una stagione di grandi Convenzioni Internazionali volte a raggiungere questi due obiettivi, di rendere all'autore prevedibile il trattamento che gli sarebbe stato servito dallo Stato straniero e rendergli una minima protezione anche all'estero.

Il problema si poneva non solo per il diritto d'autore ma anche per i brevetti e per i marchi.

- Nel **1883** c'è stata la prima grande **Convenzione Internazionale di unione di Parigi**, che tutt'ora è applicabile e che forma la base della proprietà intellettuale.

Questa Convenzione **riguarda la proprietà industriale**, per proprietà industriale e intellettuale nel sistema della Convenzione di Parigi, si intendono **le invenzioni, i modelli di utilità** (che possiamo sinteticamente definire come piccole invenzioni), **il design industriale, i marchi, le indicazioni geografiche e la disciplina della concorrenza**.

- **Pochi anni dopo** c'è stata un'altra Convenzione, che aveva l'obiettivo di coprire ciò che non troviamo in quella del '83: **il diritto d'autore**.
- Nel **1886** è stata stipulata **Convenzione di unione di Berna** che ha per oggetto la protezione delle opere letterarie e artistiche (**oggetto il diritto d'autore quindi**).

A queste due grandi convenzioni ha aderito via via un numero di Stati progressivamente crescente, sono **nate** come **Convenzioni Intra europee**, e come conseguenza dell'adesione di un numero crescente di Stati, vi aderiscono quasi tutti gli Stati del mondo oggi, perciò è diventato anche progressivamente più difficile mettersi d'accordo su come aggiornare queste Convenzioni. Il mondo si evolve, la modalità di utilizzazione delle invenzioni e delle opere protette da diritto d'autore si evolve e quindi anche la disciplina, anche internazionale, deve essere adeguata. Allora c'è stata una fase in cui queste Convenzioni venivano periodicamente aggiornate e modificate, nell'intento dei contraenti originali della convenzione di Berna ad esempio ogni 20 anni gli Stati contraenti dovevano ritrovarsi per vedere se c'erano da fare degli aggiornamenti, questo accadde nel 1908 a Berlino, 1928 a Roma e altre volte, a Stoccolma e infine a Parigi. Quindi sono state fatte **altre Convenzioni** che puntavano ad aggiornare la disciplina, nasce il **Trattato Trips**, acronimo. Nei Trips abbiamo **previsioni che riguardano tutto il campo della proprietà intellettuale**, abbiamo **sia quello della convenzione di Parigi sia il diritto d'autore** ed infine poco tempo dopo i Trips, nel **1996**, c'è stato un Trattato interamente dedicato al diritto d'autore: **il Trattato dell'Ompi**, acronimo che sta per **Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale**.



Tutte queste Convenzioni hanno in comune il fatto di obbligare tutti gli Stati contraenti a garantire parità di trattamento ai loro cittadini e ai cittadini degli Stati membri della Convenzione. Questa parità di trattamento si declina diversamente a seconda di come funzionano i meccanismi di acquisizione della protezione dei diritti.

Es. la Convenzione di unione di Berna prevede che il diritto d'autore debba essere acquistato senza che debba essere commessa nessuna formalità, quindi l'autore non deve fare niente altro che creare l'opera, l'autore acquisterà il diritto d'autore in tutti gli Stati membri alla Convenzione, perché tutti gli Stati sono obbligato a trattare allo stesso modo tutti i cittadini. Invece in materia di brevetti per acquistare il diritto esclusivo di brevetto non basta inventare qualcosa, è necessario presentare una domanda con alcuni allegati e poi verrà eventualmente concessa la protezione.

Nel vedere il principio di territorialità abbiamo già parlato di alcune delle **fonti del diritto industriale**, naturalmente il diritto industriale non è racchiuso tutto in quelle Convenzioni, ci sono altre fonti. Oltre a queste fonti, che derivano dal diritto internazionale (le Convenzioni), dall'alto verso il basso c'è un **corpo di norme**, un reticolo di norme **via via più fitto** che **derivano dal diritto dell'Unione Europea**, che ha tra i suoi obiettivi l'avvicinamento delle legislazioni nazionali e cerca di fare in modo che i diritti degli Stati membri siano tra di loro omogenei, e lo fa con due strumenti:

1. **Regolamento** → strumento più forte, perché è direttamente applicabile a tutti gli Stati membri come se fosse una legge dello Stato. Il regolamento europeo sostituisce le discipline previgenti degli Stati membri. In materia di proprietà intellettuale abbiamo un regolamento in materia di marchi, disciplina il **marchio comunitario**, cioè un tipo di marchio che vale per tutta l'Unione Europea.
2. **Direttive** → strumento usato molto più frequentemente, e che vincola gli Stati ad un obiettivo: la direttiva appone un obiettivo da raggiungere e gli Stati sono liberi di raggiungerlo come credono. La direttiva non si sostituisce dal diritto interno degli Stati.

Anche se le direttive non sono parificate al diritto interno degli Stati, sono importanti perché ci sono dei meccanismi che servono a garantire l'adeguamento del diritto nazionale alle direttive dell'Unione Europea. Se la disciplina dello Stato contrasta o comunque non è compatibile con la direttiva europea, quella dello Stato è inapplicabile e illecita. In caso di dubbio bisogna interpretare la norma nazionale in modo tale da renderla conforme al diritto dell'Unione Europea. Ci sono state tantissime direttive in materia di diritto d'autore, si è cominciato con la direttiva software alla fine degli anni '80, poi ce n'è stata una sulle banche dati... l'ultima risale al 2019, ed è stata attuata l'anno scorso in questo periodo. **L'attuazione della direttiva è l'operazione con cui lo Stato aggiorna il proprio diritto interno per renderlo conforme alla direttiva.**

In Italia abbiamo due leggi importanti, una riguarda il diritto d'autore e i diritti connessi, cioè quei diritti che sono vicini al diritto d'autore, che hanno l'obiettivo di tutelare gli investimenti in attività che hanno un rilievo culturale, anche se non danno come esito qualcosa che necessita la tutela del diritto d'autore.

Es. il diritto sulle fotografie, la foto potrà essere protetta o dal diritto d'autore o da un diritto connesso che comunque ne garantisce una qualche protezione. È una legge che risale al 1941, legge 633, via via aggiornata o novellata per adeguarla all'evoluzione tecnologica, agli obblighi imposti dalle Convenzioni Internazionali, al diritto dell'Unione Europea (direttive).

Tutto il resto si trova nel **codice della proprietà industriale**, il **d.lgs 30 del 2005** che comprende, quindi, le invenzioni, i marchi, i modelli utilità, il design industriale; anche questo codice, benché sia più recente, viene aggiornato.

Diritto d'autore

Quando nasce?

Nasce, per come lo conosciamo adesso, **all'inizio dell'età moderna, nell'800**, prima non c'era niente di simile. Nasce in quel periodo, segnato dalla diffusione crescente di un'invenzione importante, un'invenzione che ha un ruolo determinante, **la stampa** è la protagonista di questa piccola rivoluzione del mondo del diritto, perché prima della stampa, per realizzare copie delle opere letterarie era necessario un grande dispendio di tempo e quindi anche l'autore non aveva nemmeno interesse a vietare ad altri di fare copie del suo libro, tanto erano copie che non avevano di per sé un grande rilievo economico. Quindi anche se l'autore avesse avuto un diritto esclusivo di decidere di vietare o autorizzare e quale costo gli altri a copiare la sua opera, comunque non avrebbe potuto mantenersi facendosi pagare per le copie dell'opera. Con la stampa la situazione cambia decisamente, l'autore comincia ad avere interesse nel farsi pagare per riprodurre un'opera e quindi vi sono richieste più frequenti, da parte degli autori e da parte di coloro che avevano i mezzi di stampa di avere delle esclusive sulla stampa di una determinata opera, quindi gli stampatori o gli autori chiedevano al sovrano il riconoscimento di un diritto esclusivo di stampare qualcosa. Questo **diritto di ristampare e riprodurre** un'opera **ha come oggetto** non un qualcosa di materiale, ma **lo spirito incorporato in ogni esemplare o copia dell'opera**. È il diritto esclusivo di ristampare, ad esempio, la Divina Commedia è un **diritto esclusivo di trasferire l'idea avuta dall'autore in un nuovo "corpo", che contiene appunto quell'idea**, in questo senso il diritto d'autore è un diritto su un bene immateriale: è un diritto sull'idea che è trasfusa in

tutti gli esemplari. Nell'antichità non era riconosciuto questo diritto, non perché non esistesse questo spirito incorporato in ogni esemplare dell'opera, ma perché sostanzialmente non poteva uscire dagli esemplari in cui era incorporato se non a costo di mettersi a mano e ricopiare l'opera, con l'avvento della stampa, l'idea dell'autore invece può rapidamente essere incorporata in tantissimi "contenitori corporali".

Cos'è?

È un diritto esclusivo, cioè un diritto di escludere chiunque altro dall'utilizzo della cosa immateriale rappresentata o costituita dall'opera dell'ingegno. Con questo diritto, l'autore può fare ciò che vuole, lo può esercitare escludendo gli altri, vietando agli altri di utilizzare la propria opera, oppure lo può esercitare includendo e autorizzando gli altri ad utilizzare la propria opera, se essi pagano qualcosa. Questa operazione si realizza tipicamente con delle **licenze, cioè dei contratti con cui l'autore concede ad altri la facoltà di utilizzare la propria opera eventualmente dietro un pagamento.**

L'autore può anche cedere il suo diritto esclusivo con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento (regalare, cedere tramite testamento, vendere ...). Grazie al riconoscimento da parte della legge di un diritto esclusivo dato all'autore, egli acquista la possibilità di avere una remunerazione proporzionale al successo della sua opera e se è tale da consentirgli, l'autore sarà anche in grado di vivere di questo, cosa che prima non era possibile, infatti l'autore per mantenersi doveva ricorrere al finanziamento dei potenti, spesso infatti si trattava di artisti di corte, una condizione non propriamente amica della libertà di espressione.



L'oggetto del diritto d'autore → lo ricaviamo dalle prime norme della legge 633 del '41, in particolare **l'articolo uno** ci dice che ***sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, e alla cinematografia.***

Ma ancora più importante è che abbiamo due indicazioni di carattere generale: cioè opere dell'ingegno di carattere creativo.



All'articolo due c'è un altro elenco che la legge espressamente dichiara esemplificativo, quindi sono esempi di opere protette, ma non sono le uniche e lo stesso si ritiene, anche se l'articolo uno non lo dice espressamente, per l'elenco dell'articolo 1.

| *Cos'è un'opera dell'ingegno?*

Vi sono diverse opinioni, ma possiamo dare per buono che **l'opera dell'ingegno è qualsiasi creazione idonea a comunicare informazioni di qualunque genere**, dai fatti di cronaca, alle sembianze di una persona se si pensa ad un ritratto, ai sentimenti con la prosa o poesia... Importante è il rapporto tra creazione e informazioni, le informazioni sono sempre escluse dalla tutela, ciò che è tutelato è la creazione che comunica le informazioni, ma mai l'informazione di per sé. **Si tutela come si dice qualcosa non la cosa in sé**, perché le informazioni sono tutelate da altri diritti e istituti del sistema della proprietà intellettuale. Nel momento in cui si inventa qualcosa e poi lo si descrive attraverso un testo, l'opera dell'ingegno consiste nel modo in cui si sceglie di comunicare l'informazione. A volte si parla di **forma espressiva** per identificare il modo scelto dall'autore per comunicare le informazioni, modo di esprimere. Alcuni dicono che il diritto d'autore protegge la forma espressiva e non le idee, la parola idea è polisensa quindi è da intendere questa affermazione: ***se intendiamo come idea l'idea inventiva potenzialmente allora siamo d'accordo che questa idea non è protetta dal diritto d'autore. Si potrebbe dire che ciò che protegge il diritto d'autore è l'idea di esprimere un'informazione in un certo modo.***

L'opera dell'ingegno deve presentare un requisito per essere tutelabile dal diritto d'autore: **deve essere di carattere creativo.**

| *Cosa significa carattere creativo?*

Alcuni dicono che bisogna vedere se l'opera dell'ingegno è espressione della personalità dell'autore, cosa che nella maggior parte dei casi è impossibile da capire, quindi bisogna cambiare punto di vista, invece che partire dall'autore e dalla sua personalità, che nessuno riesce ad individuare, bisogna partire dall'opera e dai dati oggettivi. Allora l'opinione preferibile è quella secondo cui la creatività si compone di discrezionalità e non banalità: **l'opera è creativa quando è discrezionale e non banale.**

- **Discrezionalità** → concetto introdotto da un autore italiano importante, poi recepita dalla giurisprudenza. L'opera è discrezionale quando la modalità espressiva scelta dall'autore costituisce solo uno dei possibili modi per esprimere e comunicare l'informazione, non deve essere l'unico modo possibile, e deve essere una delle possibilità per esprimere un concetto all'interno di un numero sufficientemente ampio di varianti. **L'autore deve poter scegliere un modo su più modi per esprimere qualcosa**, è importante perché se non fosse richiesta la discrezionalità anche le forme espressive vincolate sarebbero oggetto di diritto d'autore (tipo le formule di matematica, non ci sono varianti alla formula matematica...) e chi volesse usarla dovrebbe chiedere ogni volta il permesso, si monopolizzerebbe il contenuto espresso, si porterebbe il diritto d'autore a proteggere anche i contenuti espressi, cosa che non si deve fare. L'oggetto di un'espressione vincolata può essere protetto dalla proprietà intellettuale ma non dal diritto d'autore, ad esempio dai brevetti se descrivo la mia invenzione in modo non discrezionale la mia invenzione potrà essere protetta ma dal diritto del brevetto, mai dal diritto d'autore.
- **Non banalità** → per esempio esistono molti modi per esprimere una dichiarazione d'amore, uno dei tanti "ti amo", però è intuitivo che le due parole non possono meritare la protezione del diritto d'autore. Bisogna richiedere che il modo prescelto dall'autore per esprimere un concetto, oltre a non essere vincolato, non sia tra i più banali.



Se manca l'uno o l'altro di questi due elementi non abbiamo protezione dal diritto d'autore.

Questi elenchi dell'articolo 1 e 2 sono utili, anche se esemplificativi, perché ci offrono degli esempi di creazioni che generalmente sono opere dell'ingegno. Quando abbiamo una creazione che non rientra nell'uno o nell'altro elenco dobbiamo chiederci se sia un'opera dell'ingegno.

L'elenco dell'articolo due, comprende 10 tipologie di opere, in questo si vede molto la stratificazione storica poiché comincia con:

- Opere letterarie
- Opere musicali
- Balletti
- Sculture, pitture, altre opere figurative...

- Architettura

Poi iniziano le opere introdotte dalla tecnologia:

- Opere cinematografiche, i film
- Opere fotografiche
- Programmi per elaboratori → cosa sono dal punto di vista del diritto d'autore? Perché è un'opera dell'ingegno? Perché anche il programma è un modo per comunicare un'informazione.

Sono due le componenti tutelate :

- **Il codice sorgente** → quello scritto dal programmatore in linguaggio comprensibile al programmatore
- **Il codice oggetto** → la traduzione del codice sorgente del linguaggio binario comprensibile dalla macchina

Entrambe sono opere dell'ingegno e se sono creative (quindi discrezionali e non banali), sono entrambe protette dal diritto d'autore.

Le banche dati

L'invenzione è stata introdotta nella legge del diritto d'autore negli anni novanta.



È una raccolta di dati, informazioni, entità di qualsiasi cosa, pertanto noi intendiamo qualsiasi entità percepibile. Può essere una banca dati un elenco telefonico, una lista clienti di un imprenditore, una raccolta di decisioni giudiziarie, una bibliografia...

Sono protette dal diritto d'autore quando costituiscono opere dell'ingegno di tipo creativo, quindi la raccolta di informazioni, di dati diventa proteggibile nel momento in cui esprime qualcosa e lo fa in modo creativo, cioè l'autore deve avere compiuto scelte discrezionali e non banali.

Es. una raccolta museale tematica di opere di un determinato autore che serve a mostrare un'evoluzione delle modalità espressive dell'arte dell'autore. Il museo allestisce un percorso di visita, che comincia con alcune opere giovanili, per sottolineare lo stile iniziale dell'autore e poi, via via, l'osservatore ha modo di apprezzare opere particolarmente significative delle singole evoluzioni, abbiamo quindi una raccolta di dati (che possono essere

anche quadri) che ha una funzione di comunicare qualcosa di ulteriore rispetto al dato nudo e crudo, non ha la semplice funzione di permettere di vedere i singoli dati, quadri, che compongono la raccolta ma ha invece la funzione di comunicare qualcosa di diverso.

Questo non significa che la banca dati sia protetta soltanto nel caso in cui esprima qualcosa che sia creativa, la banca di dati può essere protetta comunque, ma non dal diritto d'autore. Se non è un'opera dell'ingegno di carattere creativo potrebbe eventualmente essere protetta da un diritto connesso. Questo **diritto connesso** non si fonda su alcuni dei requisiti di cui abbiamo parlato, ma sull'investimento rilevante, se la banca dati ha richiesto un investimento rilevante allora sarà protetta a questo diritto connesso. Poi può darsi che ci sia la banca dati creativa protetta da diritto d'autore ma che abbia anche richiesto un investimento rilevante e quindi è protetta anche da un diritto connesso. Normalmente la tutela offerta da uno degli istituti del diritto industriale non esclude che sullo stesso bene possano insistere tutele previste da altri istituti.

Alla fine dell'elenco troviamo le opere del **disegno industriale**: le opere costituite dalla forma di un prodotto industriale.

Questo è un tipico esempio di categoria di opera che non ha una funzione puramente estetica o comunicativa, ma ha anche una funzione pratica, si parla di opere utili, questo non perché siano davvero più utili delle altre, tutte le opere hanno un'utilità, ma con l'espressione "utile" si vuole evidenziare il fatto che l'utilità del software, delle banche dati e del disegno industriale è particolare, perché sono destinate a soddisfare bisogni non di natura intellettuale ma più pratica, si parla quindi di **utilità pratica**.

Il riferimento che troviamo nell'articolo due è particolarmente importante, forse più dei riferimenti alle altre categorie, perché nel parlare di queste opere, l'articolo due ci dice anche che per queste opere è previsto un **requisito aggiuntivo** di tutela, *la forma del prodotto industriale ha la protezione del diritto d'autore solo se , oltre al carattere creativo, presenta anche il valore artistico*.

Perché la forma di un prodotto industriale può essere per esempio il design di un'auto, di un mobile, oggetto d'arredamento, può essere la linea della vespa lo scooter, la bici pieghevole... in questi casi vi è un **problema** se si concede con leggerezza la tutela del diritto d'autore, perché in questo caso la tutela del diritto d'autore assume una carica monopolistica di limitazione della concorrenza particolarmente forte. Cioè è difficile scindere nella pratica quali sono gli aspetti della forma del prodotto industriale che possano essere protetti dal diritto d'autore perché sono forme espressive e quali sono invece delle soluzioni tecniche.

Es. se si concedesse la tutela del diritto d'autore alla bicicletta pieghevole (che per enfatizzare le sue dimensioni ridotte viene rappresentata nelle librerie), si impedirebbe ai concorrenti della Brompton di fare delle biciclette pieghevoli altrettanto funzionali, o quantomeno si limiterebbe notevolmente la capacità dei concorrenti, il rischio sarebbe quello di tutelare anche le funzioni tecniche del prodotto, cosa che abbiamo detto si colloca al di fuori del diritto d'autore, poiché quello è il campo del brevetto, se le soluzioni tecniche del prodotto sono sufficientemente originali saranno brevettate.

In questo quadro, il legislatore italiano, sotto il diritto dell'Unione Europea, ha deciso che se bisogna introdurre le opere del design industriale non è solo necessaria la creatività, è necessaria anche il valore artistico. Questo requisito è comparso per la prima volta quando è stato introdotto relativamente al disegno industriale, era quindi inedito per la legge sul diritto d'autore, non se ne era mai parlato.

*Come deve essere interpretato il requisito del **valore artistico**?*

Col tempo, da una ventina d'anni, l'interpretazione si è assestata e la giurisprudenza prevalente tende a ritenere che per verificare se sussiste il valore artistico si ricorre a degli indizi, cioè a dei fatti che fanno "la spia" dell'esistenza del valore artistico:

- ▼ Quello più frequentemente utilizzato è quello che deriva dal fatto che **il design considerato sia percepito dagli esperti d'arte (la critica) come oggetto artistico.**

Come si fa a sapere se un oggetto è percepito come oggetto artistico?

Molto spesso si considera una prova di questo fatto **la circostanza in cui l'oggetto sia esposto in uno o più musei.** Anche questo fatto va soppesato con una certa cautela perché nei musei non ci sono sempre cose che hanno significato artistico, si trovano anche quelle cose che magari rappresentano un'epoca storica e che quindi meritano di essere ricordate come testimonianza di quell'epoca.

*La **novità**, un'opera deve essere anche nuova per essere protetta dal diritto d'autore?*

Es. in un momento di particolare ispirazione decido di scrivere un sonetto: "tanto gentile e tanto onesta pare .." e tanto bene mi viene da cominciare come quello

della "vita nuova" (ovviamente è un caso limite), io però non ho mai letto la vita nuova, non conosco l'opera originale. *Lo proteggiamo il sonetto? La novità deve essere considerata un requisito imprescindibile oppure no?*

Molto spesso opere diverse svolgono funzioni uguali, ad esempio i software, quindi la novità nelle funzioni non è richiesta, il diritto d'autore effettivamente si disinteressa del contenuto e della funzionalità. Se due software svolgono le stesse funzioni ma il codice scritto è diverso, sono due diversi, saranno entrambi protetti.

Ma invece, se è uguale il contenuto e la forma è proteggibile?

In teoria no perché si potevano dire le stesse cose con parole diverse. Ma l'autore non sapeva che esistessero già quelle parole, quindi da un punto di vista soggettivo l'autore fa delle scelte discrezionali, nella sua ignoranza. La legge in questo caso non aiuta, ma nell'istituto dei brevetti la novità dell'invenzione è un requisito richiesto.

I diritti di proprietà intellettuale, tra cui il diritto d'autore hanno una copertura costituzionale, cioè ci sono delle norme nella costituzione che legittimano la protezione del diritto d'autore, in particolare ci interessa **l'articolo 9 della costituzione**.



Art. 9 Costituzione → la repubblica promuove lo sviluppo culturale e la ricerca scientifica e tecnica → principale fondamento della protezione del diritto d'autore.

Da questo punto di vista che interesse ha la collettività ad avere due scontri uguali?

Nessuno, il secondo non apporta nessun progresso culturale.

Dunque, alla luce di questa norma costituzionale ci è subito chiaro che non c'è ragione per proteggere due opere uguali. Questo concetto è diverso dal concetto di novità perché la giurisprudenza non vuole che l'autore apporti delle novità, ma che apporti un contributo all'evoluzione culturale. Nonostante nella legge dei brevetti sia espressamente richiesta la novità, l'articolo 9 mette sullo stesso piano la cultura e la tecnica, dunque abbiamo una ragione in più per ritenere che anche nel campo del diritto d'autore valga la stessa regola che la legge esprime in materia di invenzioni.

*Che ragione c'è per trattare cultura e tecnica diversamente ?
Perché l'invenzione dovrebbe essere protetta solo se nuova e
l'opera dell'ingegno no?*

Abbiamo ricavato dal sistema che il requisito della novità è un requisito aggiuntivo rispetto a quelli espressamente dichiarati dalla legge.

Le ipotesi di incontri fortuiti, cioè i casi in cui due autori creano opere uguali senza saperlo, non sono poi così rare, socialmente nel campo delle opere musicali. Normalmente le somiglianze non sono tali da inficiare la novità dell'opera.

Es. negli anni novanta, ci fu una controversia tra Albano e Michael Jackson, Albano scrisse una canzone con Romina, qualche anno dopo Jackson e pubblicò la canzone "Will you be there", le due melodie si assomigliano tanto e allora Albano andò dal giudice e chiamò in giudizio Michael Jackson per violazione del suo diritto d'autore. Jackson disse che non sapeva neanche chi fosse Albano, invece Albano disse che non importava se non lo conoscesse o meno, la cosa importante era che la sua canzone era precedente all'altra e quindi "Will you be there" difettava di novità, quindi non era protetta dal diritto d'autore e quindi non c'era alcun interesse di Jackson meritevole di tutela. Secondo Albano solo la prima doveva essere tutelata, e in effetti il tribunale di primo grado diede ragione ad Albano, poi in appello la decisione venne riformata per un motivo interessante, il giudice d'appello affermò che la novità è un requisito, però rileva anche che nemmeno l'opera di Albano era nuova poiché a sua volta, a monte dell'opera di Albano c'erano delle melodie tradizionali della musica gospel e quindi secondo la corte d'appello la domanda di Albano doveva essere respinta, perché nessuna delle due poteva essere protetta, quanto meno relativamente all'aspetto melodico (aspetto su cui confliggono le opere). Poi la controversia si fermò lì, non vi è stata la decisione della corte di cassazione → esempio di incontro fortuito.

Sull'oggetto della tutela del diritto d'autore resta da dire ancora una cosa, noi abbiamo visto i requisiti.

*La creazione dell'autore, perché sia proteggibile, deve avere una certa **dimensione**?*

Quando si pensa, ad esempio, all'opera letteraria ci può venire in mente un romanzo, un articolo di giornale, ma basta anche il capitolo di un romanzo; invece che un

capitolo si prende una pagina; invece di una pagina considero una frase... **Dove si ferma il diritto d'autore?**

Pensiamo ai requisiti di tutela di cui abbiamo parlato, cioè **espressività, creatività e novità. Una volta che abbiamo una creazione, un frammento anche piccolo, se possiede questi requisiti deve sussistere la protezione del diritto d'autore, ciò significa che non c'è un requisito di dimensionalità.**

Un romanzo nel suo complesso è di certo un'opera dell'ingegno dotata di carattere creativo, ma al suo interno ci sono tante opere creative ugualmente protette dal diritto d'autore, sono liberamente utilizzabili, perché non coperte, solo quelle porzioni che sono tanto piccole e insignificanti da non integrare l'uno o l'altro dei requisiti necessari. Dal miglioramento via via sempre più significativo dell'intelligenza artificiale si discute che essa possa addirittura prendere decisioni giudiziarie. Non si sa se sia ancora possibile, ma comunque se ne parla.

Due problemi:

- **Tutelabilità del diritto d'autore**
- **Affollamento delle opere dell'ingegno**, nel senso che con l'AI si potrebbe verificare la possibilità di esaurire le modalità con cui esprimersi.

Alcuni dicono che in questo quadro non bisognerebbe più richiedere il requisito di novità, in modo che l'uomo autore comunque possa avere il diritto d'autore anche se è stato preceduto da questa invadente intelligenza artificiale. In realtà la soluzione non è questa, piuttosto, se è vero che l'intelligenza artificiale riuscirà un giorno ad esaurire tutte le possibilità, allora anche le creazioni dell'intelligenza artificiale non saranno più creative. Il titolare del diritto d'autore di un software può essere chiamato proprietario, a questo punto ci interessa una norma del codice civile che dice che i frutti appartengono al proprietario della cosa che li ha prodotti (norma pensata per i frutti naturali).

Se il sistema di AI è una cosa che ha un proprietario, allora il risultato dell'intelligenza artificiale è un frutto del sistema dell'intelligenza artificiale, e quindi appartiene al suo proprietario.

| Come si acquista il diritto d'autore? A chi spetta?



Bisogna partire dall'articolo 6 della legge sul diritto d'autore, 633 del 1941
→ il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera.

Titolo originario significa che l'autore è colui che acquista per primo il diritto al momento della costituzione → termine giuridico opposto al titolare derivativo, che è quello in capo a cui il diritto si trasferisce.

Quindi, questa norma ci dice che all'inizio il diritto d'autore spetta a colui che crea l'opera.

Bisogna chiedersi se l'autore deve fare qualcosa a parte creare l'opera per garantirsi la protezione, un tempo occorreva che l'autore andasse dal sovrano a chiedere dei privilegi (fino all'età moderna) e il Sovrano poteva concederli o no. La grande differenza tra i sistemi dei privilegi e il sistema del diritto d'autore che è nato successivamente è che l'autore ha un diritto ad essere protetto, non è che lo Stato può decidere di concedere o no la protezione come si faceva prima. Però anche nell'epoca del diritto d'autore (**800 e parte del 900**), c'è stato un tempo in cui non bastava che l'autore creasse la cosa, doveva pagare delle tasse, effettuare dei depositi presso degli uffici, era quindi frequente che gli Stati richiedessero il **compimento di formalità come condizione per la concessione del diritto d'autore**. Le formalità richieste erano un po' diverse da Stato a Stato e quindi l'autore per garantirsi la protezione in un certo numero di Stati doveva cercare di capire quali fossero le rispettive formalità richieste, con tutti i costi conseguenti. Da allora, in particolare **nel 1908**, alla Conferenza di Berlino convocata per la revisione della Conferenza di Berna, i delegati degli Stati membri si sono accordati per **abolire tutte formalità costitutive**. A questo punto, negli anni successivi, gli Stati hanno modificato le loro discipline interne e hanno abolito le formalità non solo per gli stranieri, ma per tutti, anche per i cittadini interni.

Dunque, l'autore deve fare il minimo necessario per accertare l'opera, cioè crearla. L'opera espressa oralmente è comunque protetta, certamente ci sono delle problematiche pratiche ma comunque è protetta dal diritto d'autore.

Ci sono poi dei pubblici registri delle opere dell'ingegno, alcuni sono tenuti dalla **SIAE**, alcuni dal pubblico ministero... al deposito in questi registri sono dedicate delle agevolazioni agli autori. Tuttavia rimane comunque un requisito non necessario per acquistare la protezione del diritto d'autore.

Se è vero che sono vietate le formalità costitutive, che senso ha questo segno "©" che si vede quasi sempre ?

È una questione storica, alcuni Stati hanno aderito alla Convenzione di Berna solo in tempi recenti, gli Stati Uniti ad esempio hanno aderito alla fine degli anni '80, uno dei motivi è perché avevano un sistema di formalità molto radicato, per acquistare la protezione era necessario il deposito di un esemplare presso il copyright code. Nel 1952 si era fatta la Convenzione Universale sul diritto d'autore, allo scopo di fare aderire più stati possibili alla convenzione di Berna e principalmente gli Stati Uniti, questa convenzione universale prevede tra le altre cose che tutti gli Stati membri devono considerare soddisfatte le formalità con la semplice apposizione del **segno ©**.

Fino a che gli Stati Uniti d'America non hanno aderito questo segno serviva a garantire la protezione negli Stati Uniti.

Ormai la questione si ritiene storica poiché quasi tutti gli Stati del mondo hanno aderito alla convenzione. Nel campo dei **brevetti**, invece, è **l'opposto**, la protezione si acquista all'esito di un procedimento amministrativo che viene introdotto con il deposito. Non hanno previsto un divieto di formalità costitutive anche per i brevetti perché semplicemente in questo campo c'è un interesse a combattere la segregazione delle conoscenze.

L'uomo ha una naturale tendenza a tenersi per sé il proprio sapere, in materia di diritto d'autore c'è una tendenza opposta, l'autore vuole farsi apprezzare per la propria opera. Questa tendenza negativa la si può combattere soltanto **imponendo il deposito della descrizione dell'invenzione**, proprio perché la conoscenza non vada persa.

Può accadere che l'autore sia un lavoratore dipendente, che collabori con qualcun altro e quindi più autori collaborino per realizzare un'opera, o che ci siano tanti singoli autori, ognuno dei quali scrive un suo contributo e poi un soggetto che dirige l'operazione creativa nel suo complesso (rivista, giornali). In tutti questi casi, leggermente più complicati di quelli che abbiamo già visto, dobbiamo chiederci a chi spettano i diritti d'autore.

L'autore è un lavoratore dipendente

Abbiamo due norme nella legge sul diritto d'autore (articolo 12bis e 12ter) che sono relative a dei particolari generi di opere.



Art.12 bis → relativo ai software e alle banche dati

Art. 12 ter → relativo alle opere del disegno industriale, del design

La legge sul diritto d'autore è del 1941 ed è stata più volte novellata, perciò quando c'è bisogno di introdurre una nuova norma in una legge preesistente si può introdurre la nuova in fondo a tutte le altre, però una legge ha un suo impianto sistematico,

Es. la legge sul diritto d'autore parla prima dell'oggetto della tutela poi del contenuto (estensione del diritto d'autore), poi parla delle eccezioni, quindi le nuove norme vanno introdotte per forza di cose nel posto adatto → lo si fa aggiungendo "Bis" o "Ter".

Questi due articoli ci dicono, per le opere che considerano, che quando queste opere sono create nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato e il lavoratore è adibito a mansioni creative, i diritti sulle opere dell'ingegno prodotte dal lavoratore spettano al datore.

C'è questa regola perché solitamente, quando un imprenditore assume qualcuno allo scopo di fare loro creare opere dell'ingegno è perché vuole utilizzare i risultati di questa attività creativa. E allora la legge per semplificare le cose prevede espressamente questa regola.



Nel campo del software, delle banche dati e delle opere del disegno industriale i risultati creativi del lavoratore dipendente spettano al datore di lavoro, purché l'attività creativa faccia parte delle mansioni del lavoratore.

Es. se un operaio metalmeccanico scrive un libro, un articolo, un'opera, il diritto d'autore non appartiene al suo datore di lavoro.

| Cosa si fa per le opere che appartengono ad altre categorie ?

Si adotta la stessa soluzione, perché queste norme sono espressione del normale assetto degli interessi in campo in qualsiasi caso in cui datore di lavoro assume dipendenti per far loro realizzare opere dell'ingegno. Quindi si ritiene che, proprio perché queste norme esprimono un principio generale, allora le possiamo applicare anche al di fuori dei casi espressamente considerati, con un'operazione che in diritto

si chiama "**applicazione alla logica**", che è lo strumento giuridico di interpretazione con cui una norma viene applicata anche al di fuori dei casi espressamente considerati. L'applicazione alla logica è possibile nei casi in cui la norma che consideriamo non costituisce un'eccezione.

Dato che non c'è differenza tra i casi in cui un datore assume uno sviluppatore di software o un giornalista, allora possiamo applicare la norma anche a giornalisti, musicisti ecc...

Qui la soluzione è chiara quando un autore è un lavoratore dipendente.

L'autore è in un rapporto di commissione

La soluzione non è del tutto chiara e controvertibile, l'opinione dominante è la finalità per cui un soggetto commissiona la creazione di un'opera dell'ingegno ad un altro, bisogna quindi guardare quali sono le finalità del contratto.

Es. un imprenditore commissiona a un gruppo di pubblicitari la realizzazione di un sito, qui gli autori non sono dipendenti dell'imprenditore.

L'opinione dominante ritiene che nel caso in cui l'opera dell'ingegno sia creata su commissione, senza un rapporto di lavoro subordinato, allora **si trasferiscono al committente soltanto le facoltà che sono necessarie per realizzare gli interessi o l'obiettivo perseguito dal contratto di commissione**. Quindi se l'oggetto del contratto di commissione è la realizzazione di un sito, si trasferiranno al committente soltanto le facoltà che sono necessarie per mettere online il sito. Nel caso del parere di un professionista si trasferiranno soltanto le facoltà il cui esercizio è necessario per produrre il parere.

Il titolo originario di acquisto del diritto d'autore è soltanto la creazione, quindi il titolare originario del diritto d'autore è soltanto l'autore, gli altri soggetti possono acquistare il diritto soltanto in via derivativa (in seguito a un trasferimento). In questi casi appena visti **il "titolare" è il datore di lavoro → in realtà è comunque un acquisto a titolo derivativo, anche se automatico**, poiché nello stesso istante in cui sorge all'autore si trasferisce al datore. È pur sempre un trasferimento del diritto, perché da un punto di vista cronologico e storico avviene direttamente, il dipendente non rimane titolare neppure per un istante però c'è comunque un trasferimento. I due momenti logici giuridici dal punto di vista cronologico coincidono: la nascita e il trasferimento.

L'autore è più di uno → più autori collaborano

La collaborazione creativa può avere due caratteristiche, cioè ci sono due grandi gruppi nei casi di collaborazioni:

- Casi di **collaborazione in senso verticale** → un'ipotesi in cui c'è una molteplicità di contributi creativi su livelli diversi.

È il caso delle opere come i giornali, le riviste, in cui si hanno tanti autori che creano ognuno il proprio contributo e sopra un soggetto che coordina e dirige l'attività creativa dei singoli autori. Se consideriamo anche l'attività di chi coordina e dirige un'attività creativa abbiamo un **doppio livello di creatività** e la legge ne tiene conto valorizzando sia la posizione dei singoli autori che quella del direttore dell'opera.



In particolare, abbiamo una disciplina specifica dettata dagli **articoli 38 e seguenti** che ci dice :

1. L'autore dell'opera collettiva è il direttore
2. I singoli rimangono autori dei loro rispettivi contributi e hanno diritto ad utilizzarli separatamente, purché ciò non sia pregiudizievole per lo sfruttamento dei diritti sull'opera comune
3. I diritti sull'opera comune appartengono, qualora vi sia, all'editore

L'editore, ai fini dell'applicazione di questa regola, è colui che si assume il rischio imprenditoriale dell'iniziativa, colui che finanzia la creazione dell'opera e si assume il rischio. Se non vi è l'editore, la gestione dei diritti sull'opera collettiva complessivamente considerata spetta al direttore, può accadere che le regole che abbiamo visto finora vadano applicate congiuntamente.

Finora abbiamo visto tipi separati di collaborazione creativa, ma può darsi che vi sia un'opera composta di musica e parole, a cui quindi applichiamo l'**articolo 34** dove però ci sono più soggetti che insieme hanno scritto la musica, uno ha scritto le parole, e un gruppo di autori ha scritto la musica, qui si applica la regola dell'articolo 34 relativamente ai rapporti fra chi ha scritto le parole e il blocco di autori che ha scritto la musica, ma relativamente a questi ultimi applichiamo la regola dell'articolo 10. Se immaginiamo un'ipotesi di un'opera musicale collettiva, tanti autori diretti da un soggetto realizzano insieme un album musicale, si applicano anche le regole dell'opera collettiva. Poi potrebbero aggiungersi casi di elaborazione.

Inoltre ci sono ulteriori casi particolari

Es. l'opera cinematografica.

Come la consideriamo? Abbiamo tanti soggetti e ognuno fa la sua parte, attori, sceneggiatori, direttori, coloro che scrivono le musiche, poi c'è il regista (può sembrare che vi sia un doppio livello di creatività).

Se invece guardiamo l'opera cinematografica dal punto di vista dei singoli contributi che la compongono abbiamo un'opera composta di contributi generalmente distinguibili, alcuni dei quali possono senz'altro essere utilizzabili separatamente, e sono cioè anche scindibili.

Per quanto riguarda gli autori che collaborano alla creazione di un'opera cinematografica, abbiamo

- **L'autore del soggetto** (soggetto = trama), l'idea di base che sempre è esposta in forma di opera letteraria, può essere un soggetto originale, scritto apposta per il film, oppure può essere un riadattamento di un'opera preesistente, nel caso in cui il film è tratto da un'opera precedente. L'autore del soggetto, espresso in forma di opera letteraria, realizza un'opera dell'ingegno di carattere creativo protetta dal diritto d'autore.
- La **sceneggiatura**, che è la descrizione di ciò che accade diviso scena per scena, talvolta l'autore della sceneggiatura è il medesimo soggetto, talvolta può essere un altro, per fare una sceneggiatura occorrono competenze diverse.
- La **musica**
- La **regia con il direttore artistico**.

Quindi, in questa opera complessa costituita dal film abbiamo alcuni caratteri delle opere collettive e alcuni delle composte. La legge tiene conto di queste complessità e prevede una disciplina apposita che troviamo negli articoli 44 e seguenti dove vediamo che anzitutto tutti sono coautori di vario grado dell'opera cinematografica complessivamente considerata, vediamo una similitudine con la disciplina delle opere composte, cioè non c'è un soggetto che è autore del film più degli altri, però la duplicità di livello creativo è valorizzata per quel che riguarda l'appartenenza di alcuni diritti sull'opera comune, in particolare:



Il diritto di **sfruttamento cinematografico nel film appartiene al produttore cinematografico** (colui che finanzia la realizzazione del film), questo aspetto ci ricorda la disciplina dell'opera collettiva, poiché il diritto di sfruttamento apparteneva all'editore.

Un altro esempio della somiglianza tra l'opera cinematografica e l'opera collettiva lo vediamo nel fatto che la legge prevede espressamente nell'**articolo 49** che gli autori singoli possono utilizzare separatamente i propri contributi senza dover chiedere il permesso.

Gli **attori** non si trovano in questo elenco perché, di per sé, finché si limitano a fare gli attori **non sono considerati autori**, la loro prestazione ha comunque una tutela ma di un diritto connesso al diritto d'autore.

- **Collaborazione in senso orizzontale** → Una prima ipotesi è quella in cui più autori realizzano un'opera "a quattro mani", può accadere che i contributi di due o più autori siano talmente compenetrati l'uno con l'altro che non è possibile distinguere cosa ha fatto uno e cosa ha fatto l'altro.



Art. 10 → se l'opera è creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più autori il diritto appartiene in comunione a tutti i coautori.

Inscindibile vuol dire che i contributi dei singoli non sono utilizzabili separatamente.

- Es. un film è un'opera le cui parti possono essere utilizzate separatamente, gli autori, le musiche...

L'articolo ci dice anche in quale disciplina in particolare si applica per regolare la comunione tra i diversi autori: **innanzitutto si applica la disciplina della comunione prevista dal codice civile**. Il codice civile prevede, nel libro dedicato ai diritti di proprietà sulle cose materiali, un corpo di norme relative a disciplinare le situazioni in cui il diritto di proprietà appartiene a più persone, ma molto spesso non abbiamo bisogno di applicare queste regole poiché l'articolo 10 detta una disciplina specifica abbastanza articolata. In particolare queste regole espresse sono:

- **Il diritto morale può essere esercitato da ognuno degli autori nell'interesse di tutti**, ogni autore può difendere il diritto morale sull'opera comune.
- **Per pubblicare l'opera, modificarla o utilizzarla in qualsiasi forma diversa da quella della prima pubblicazione è necessario l'accordo di tutti** → Es. abbiamo scritto un libro e vogliamo trarne un film, dobbiamo essere tutti d'accordo. Abbiamo realizzato un sito, va aggiornato, bisogna mettersi d'accordo tutti.

Qui potrebbe esserci il problema che uno tra questi autori firmi per non autorizzare, allora l'articolo 10 ci dà la soluzione, in particolare nel caso di ingiustificato rifiuto di uno dei coautori, il giudice può autorizzare. Quindi la legge protegge i coautori dall'eventuale ostruzionismo pretenzioso di uno di essi.

Le quote di partecipazione alla comunione si presumono uguali, determinare il valore delle quote dei singoli è importante in un'ottica di distribuzione degli eventuali utili ricavati dallo sfruttamento dell'opera. Si presume che tutti abbiano diritto alla stessa quota, la legge consente comunque agli autori di accordarsi diversamente per iscritto, altrimenti si presume che tutti abbiano le stesse quote, questo quanto alle opere che si compongono dei contributi indistinguibili ed inscindibili.

Molto spesso **i contributi sono distinguibili**, è possibile spesso determinare cosa è stato fatto da uno e cosa dall'altro, quindi applichiamo, in alcuni casi, delle regole espressamente previste dalla legge che ci tolgono il compito di verificare quale sia la disciplina applicabile (così avviene per esempio per le opere composte da musica e parole). Alle opere che sono dovute a contributi distinguibili, che chiamiamo **opere composte** sono dedicati gli **articoli 34 e seguenti della 633 del '41**, la previsione fondamentale da ricordare presente in questi articoli, è che il valore del contributo di chi ha scritto la musica e quello del contributo di chi ha scritto le parole si presume uguale, in questo non c'è differenza quindi rispetto all'articolo 10. Però, l'esercizio dei diritti sull'opera comune compete all'autore della musica, quindi l'autore delle parole ha diritto a partecipare ugualmente ai ricavi che possono derivare dallo sfruttamento dell'opera comune ma l'esercizio compete all'autore della musica.

Es. sarà l'autore della musica a negoziare i contratti di licenza con le imprese culturali che si propongono di utilizzare l'opera ecc..

Pochi anni fa c'è stato un *caso deciso dal tribunale di Milano relativo al repertorio del duo Mogol e Battisti*. All'inizio, Battisti in qualità di autore della

parte musicale, aveva l'esercizio dei diritti sulle opere comuni, e Mogol aveva il diritto a partecipare ai ricavi. A causa di una catena, i diritti di Battisti sono finiti alla società Acqua azzurra presieduta dalla moglie vedova di Battisti e quindi spettava alla società, e quindi alla moglie, autorizzare le utilizzazioni delle opere che componevano il repertorio comune del duo Mogol e Battisti, soltanto che la moglie rifiutava sempre il consenso. Le avevano proposto di utilizzare una certa canzone per un filmato pubblicitario della Fiat, un'altra per la Barilla, poi altri volevano fare delle cover... e la moglie rifiutava sempre il consenso. Mogol ha cominciato a protestare perché i ricavi erano diminuiti, e via via si erano sparse le voci che erano diminuite anche le richieste di sfruttamento delle opere... i due non sono riusciti a mettersi d'accordo e quindi la controversia è finita davanti al giudice del tribunale di Milano, che alla fine ha condannato la società amministrata dalla moglie a risarcire un ammontare cospicuo di danni (diversi milioni di euro) a Mogol. Questo perché il soggetto titolare dei diritti sulla musica, è vero che ha la competenza attribuita dalla legge a gestire le opere comuni.

Quindi è vero che **deve decidere il titolare dei diritti sulla musica se autorizzare o no l'utilizzo, però la legge gli impone un onere di amministrare bene le opere comuni, nell'interesse di tutti**. Quindi se si rifiuta di prestare il consenso ad utilizzazioni che potrebbero essere remunerative deve avere una buona giustificazione, se invece l'autore della musica rifiuta senza prestare alcun buon motivo risponderà dei danni.

In particolare, la moglie di Battisti si giustificava dicendo che voleva tutelare il diritto morale d'autore, ma il giudice ha ritenuto che non ci fossero ragioni di diritto morale d'autore che sconsigliavano di concedere il rifiuto, dunque il rifiuto non era giustificato e la società deve risarcire i danni. → opere composte da contributi distinguibili, in questo caso opere composte da musica e parole.

Negli altri casi di opere composte da contributi distinguibili si ritiene giusto applicare la disciplina dell'**art.10**, quantomeno quando i contributi non sono utilizzabili separatamente.

Un altro caso in cui abbiamo più autori nella scena è il **caso dell'elaborazione**, io realizzo un'opera e un altro autore interviene apportando delle modifiche alla mia opera originaria. A sua volta però è un'attività creativa che merita di essere protetta.



L'articolo 4 della 633 → senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo (carattere che sussiste quando c'è discrezionalità e non banalità).

Esempi di elaborazione sono tanti, le traduzioni, molto spesso per rendere in una lingua diversa un'opera è necessario fare delle scelte, lo stesso quando si trasferisce un'opera letteraria in un'altra (traggo un film da un romanzo).

L'elaboratore è protetto dalla legge ma deve rispettare i diritti dell'autore dell'opera originaria, cioè l'opera elaborata può essere utilizzata soltanto col consenso dell'autore dell'opera originaria. Tuttora si discute se l'opera elaborata appartenga in comunione all'autore originario e all'elaboratore oppure se solo all'elaboratore, con la particolarità che l'elaboratore debba chiedere il permesso all'autore dell'opera originaria (prevale la seconda ipotesi). La differenza tra un'ipotesi e l'altra è che, se si sostiene la prima ipotesi, e quindi si applica l'articolo 10, c'è però un problema, perché spesso il contributo dell'elaboratore è marginale. Quindi il grosso del lavoro è stato fatto al momento della realizzazione dell'opera originaria.

Es. chi aggiorna un software si limita ad introdurre modifiche che per quanto saranno innovative sono sostanzialmente marginali.

E se applicassimo l'articolo 10 potremmo andare incontro anche a un altro problema, le quote di partecipazione alla comunione si presumerebbe siano uguali, salvo che dichiarino diversamente per iscritto, e questo non va tanto bene, poiché attribuiamo all'elaboratore una quota di partecipazione al ricavato dello sfruttamento dell'opera elaborata non giustificata dall'entità del suo intervento, allora la lettura preferibile è quella secondo cui i diritti sull'opera elaborata sono dell'elaboratore, quindi l'opera elaborata la gestisce lui, però deve munirsi del consenso dell'autore dell'opera originaria, e non si applica l'articolo 10.

Norme che regolano le utilizzazioni

Bipartizione, il diritto di autore è caratterizzato da:

- **Diritto patrimoniale**
- **Diritto morale d'autore**

si parla anche di dualismo per descrivere questa struttura bipartita (in Italia).



Diritti patrimoniali d'autore → disciplinati negli articoli 12 e seguenti della 633 del 41.

All'inizio c'è una regola generale, in particolare l'articolo 12 ci dice che l'autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera.

Si vede subito una previsione di carattere ampio che riserva all'autore qualsiasi utilizzazione economica. Poi vi è una serie di articoli (13-18) che riguardano invece *specifiche modalità di utilizzazione dell'opera*, riservano all'autore alcune specifiche attività:

Es. **l'art.13** → la riproduzione dell'opera.

Come mai abbiamo all'inizio la norma generale che riserva all'autore qualsiasi utilizzazione e poi c'è questo elenco dettagliato di singole forme di utilizzazione?

La ragione per cui coesistono questi due tipi di norme (regola generale e regole) in parte è storica perché, prima sono avvenute le singole regolette relative a particolari forme di utilizzazione e poi soltanto in tempi relativamente recenti (in Italia nel 900) è arrivata la regola generale.

Il diritto d'autore è stato anticipato nella storia dal sistema dei privilegi, poi via via i privilegi si sono arricchiti di nuove facoltà fino a che non si è arrivati alla clausola generale. Nel momento in cui ci si trova di fronte a una fattispecie che rientra in una di quelle regolate dagli art. 13 e seguenti, siamo tranquilli che l'utilizzazione è riservata all'autore.

L'**art.12**, a sua volta mantiene una funzione nonostante ci sia l'elenco specifico degli art 13 e seguenti perché può darsi che vi siano modalità di utilizzazione nuove consentite dalla tecnologia ma non considerate dalla legislazione. La regola dell'art.12 consente al sistema di adattarsi all'evoluzione tecnologica ancora prima che il legislatore intervenga ad aggiornare l'elenco

Cos'è l'utilizzazione economica?

Generalmente si ritiene che è **economica l'utilizzazione realizzata nel contesto di un'attività imprenditoriale e in modo funzionale all'attività imprenditoriale.**

Abbiamo già trovato il concetto di economicità nella nozione di impresa, è proprio quella la nozione che dobbiamo andare a guardare per riempire il concetto di utilizzazione economica.

La disciplina italiana ha queste due tecniche:

- **Normativa della clausola generale**
- **Tecnica di tipo più casistica** → volta a disciplinare situazioni più → protagonista della storia

Nel mondo del **diritto europeo** (direttiva) è utilizzata ancora la **tecnica casistica**, non c'è la clausola generale, non si parla di utilizzazione economica, le direttive impongono di riservare agli autori determinate forme di utilizzazione.



Problema!

Ci si è chiesti, tenendo in conto che il livello di armonizzazione delle direttive dell'Unione Europea è ormai elevato, *gli Stati possono ancora tutelare il diritto d'autore in modo più ampio di quanto non richiedano le direttive?*

Si è aperto un dibattito.

La prima forma di utilizzazione espressamente tipizzata dalla legge è la riproduzione (articolo 13), il **diritto esclusivo di riprodurre** ha per oggetto la moltiplicazione in copie temporanea o permanente in qualunque modo o forma, questo è il più antico privilegio.

Si parla di moltiplicazione temporanea o permanente perché la legge vuole espressamente ricomprendere nell'ambito del diritto d'autore anche le copie realizzate ad esempio dai computer e che siano temporanee. Non è tutto, perché c'è un'eccezione al diritto esclusivo per alcune tipologie di riproduzioni temporanee, quindi ad alcune situazioni può esserci anche senza il consenso dell'autore. In qualunque modo o forma, significa che il concetto di riproduzione comprende tanto la copia fatta a mano quanto la scansione o la fotocopia... una qualsiasi attività che realizzi un nuovo esemplare dell'opera. Non è richiesto dal concetto di riproduzione che la copia è anche destinata ad essere rivenduta.

Il problema posto per le **sincronizzazioni** è abbinare una musica ad immagini in movimento. La sincronizzazione è riservata all'autore oppure no, o meglio, senz'altro nel momento in cui si fa vedere a qualcuno il filmato che comprende quelle attività. Alcuni sostenevano che la sincronizzazione non comportava una riproduzione rilevante per il diritto d'autore, e invece poi si è affermata l'idea secondo cui ***anche la semplice realizzazione di una copia di un'opera musicale nella fase in cui la si abbina a delle immagini in movimento realizza una riproduzione rilevante per il diritto d'autore*** e quindi di conseguenza decidiamo che anche l'attività di sincronizzare è riservata all'autore perché comporta una riproduzione.

La modalità di utilizzazione successiva è la **trascrizione o fissazione** dell'opera orale, cioè la trasformazione di un'opera orale in opera scritta. Sappiamo che l'opera è protetta anche se espressa solo oralmente (vediamo nel diritto di trascrizione già una prima manifestazione). ***Solo l'autore è abilitato ad autorizzare la trascrizione dell'opera orale in opera scritta.***



Particolarmente interessanti sono le regole nell'**art.15, 15bis e 16**.

Forme di fruizione dell'opera che si realizzano con la trasmissione di energia, sono in particolare le varie modalità di comunicazione al pubblico. La comunicazione di un'opera dell'ingegno al pubblico può avere due grandi gruppi. Comunicazioni a un pubblico presente possono consistere (secondo l'articolo 15) nell'esecuzione, nella rappresentazione o nella recitazione.

- **Differenze** → ***l'esecuzione*** riguarda le opere musicali e consiste in particolare nell'atto di suonare una musica, attraverso l'uso di uno strumento oppure riproducendo una musica già registrata. ***La rappresentazione*** riguarda le opere che appartengono in senso lato al teatro, consiste nell'atto di mettere in scena un'opera, quindi è caratterizzata dall'azione scenica.

La **recitazione** consiste invece nella semplice dizione dell'opera letteraria, si differenzia dalla rappresentazione perché la recitazione non comprende la scena, si tratta del semplice parlare in pubblico. La legge non dice se questo elenco di modalità di comunicazione ad un pubblico presente è tassativo esemplificativo, cioè se è esaustivo.

È opinione solitamente condivisa che è un elenco esemplificativo.

Purché si tratti di atti che rendono fruibile un'opera ad un pubblico presente, qualsiasi attività che rende fruibile un'opera ad un pubblico presente costituisce una comunicazione al pubblico presente che è riservata all'autore. Però ci vuole un pubblico, è chiaro che se mi metto a suonare la chitarra da solo non realizzo esecuzioni rilevanti per la legge.



Secondo comma dell'art. 15 → non è considerata pubblica (esecuzione, rappresentazione, recitazione) se si esauriscono all'interno della cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola, o dell'istituto di ricovero, purché manchi lo scopo di lucro.

Quindi se realizzo un'esecuzione musicale a scuola e faccio pagare qualcosa ai miei compagni non beneficio dell'esclusione, quando c'è un pubblico che esula dalla particolare fattispecie identificata dall'articolo 15 comma secondo, non si può prescindere dal consenso dell'autore. Ragione per cui se si organizza una festa, anche privata con un numero considerevole di persone, bisogna munirsi dei permessi di chi gestisce gli interessi degli autori (tipo la SIAE). Può accadere che il pubblico sia collocato in un luogo diverso da quello in cui si origina l'attività che rende fruibile l'opera, come nelle comunicazioni a un pubblico distante, quando è realizzato un atto che rende fruibile un'opera ad un pubblico distante.

Es. la radio, la TV, internet.

- **Differenza** → per internet si usa spesso non la categoria della comunicazione al pubblico ma quella della messa a disposizione al pubblico, come la televisione e la radio, quando accendo la radio o la TV posso scegliere il luogo da cui desidero fruire della trasmissione ma invece non posso scegliere il momento, invece quando vado su internet scelgo anche il momento. Chi comunica al pubblico, chi rende fruibile un'opera via radio, via TV, permette all'utente di scegliere il luogo ma non il momento, in internet è possibile perché rende fruibile l'opera e permette di scegliere tanto il luogo quanto il momento. Si parla anche di comunicazione al **pubblico semplice** (TV, radio) e **interattiva** (internet).

Si parla anche di messa a disposizione del pubblico, molto spesso nel caso di opere messe a disposizione su internet è semplice verificare se sussiste una messa a disposizione del pubblico. Ci sono casi in cui la situazione è più dubbia.

Es. se invece di caricare una foto sul mio sito metto un link che punta verso il sito di un altro che ha la fotografia.

YouTube, nel momento in cui permette agli utenti di caricare dei video realizza la comunicazione al pubblico o no?

Linking e sono alcuni dei problemi maggiori che ha posto l'interpretazione

Problema del linking

Il problema è stato affrontato in alcuni casi giudiziari finiti di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Il diritto italiano si deve uniformare alle direttive dell'Unione Europea, quindi, deve essere nel caso modificato o nel dubbio interpretato in modo tale da renderlo conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

Come si fa ad essere sicuri di cosa dice la disciplina dell'Unione Europea?

Se si consentisse al giudice nazionale di interpretare la normativa europea senza un organo di controllo che si collochi a livello superiore di quello degli Stati, ci sarebbe il rischio di avere interpretazioni diversificate tra uno stato e l'altro. Allora, è stata istituita una corte formata da un insieme di giudici che ha la funzione di garantire l'omogeneità dell'applicazione del diritto europeo.

La Corte ha varie funzioni, tra cui quella di esprimersi sull'interpretazione del diritto dell'Unione Europea quando glielo chiede un giudice nazionale. Però quando il giudice nazionale si trova a dover applicare una norma interna, di cui deve verificare la compatibilità col diritto dell'Unione Europea e ha un dubbio sull'interpretazione corretta, chiede di risolvere il dubbio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Si dice che il giudice dello Stato rimette la questione alla Corte di Giustizia, con un meccanismo che si chiama **rinvio pregiudiziale**, questo è il meccanismo che spesso porta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea a pronunciarsi sulla disciplina del diritto d'autore.

C'è stata una serie di rinvii pregiudiziali in materia di linking:

Es. **Sentenza Svensson** → il *Caso Svensson* che ha condotto la sentenza della corte di giustizia del 13/02/2014. Svensson è un giornalista svedese che aveva un sito insieme a un gruppo di altri giornalisti, su cui pubblicavano i loro articoli, pubblicamente accessibili, quindi chiunque li poteva vedere. Poi un altro sito iniziò a pubblicare dei link al sito di Svensson e dei colleghi, quindi Svensson e gli altri fecero causa al sito che pubblicava i link. Sulla base del diritto d'autore

(che è un diritto esclusivo proprietario) se si realizza un'attività che rientra nel diritto, anche se non reca qualche danno, l'autore la può vietare. L'interesse risiede in questo caso nel fatto che il link fornisce un accesso diretto al contenuto, mentre invece il visitatore che arrivava al sito di Svensson, senza il link, si vedeva prima l'home Page e la pubblicità relativa al sito... quindi il link, fornendo l'accesso diretto, privava i visitatori di tutte le altre pagine del sito. Il giudice svedese era chiamato a decidere se ci fosse una messa a disposizione al pubblico realizzata da parte del soggetto che aveva postato il link oppure no, perciò aveva bisogno di un **atto di comunicazione** e di un **pubblico**, un pubblico nuovo, che non deve essere già stato preso in considerazione del titolare dei diritti. Allora in questo caso, c'è l'atto di comunicazione secondo la Corte, perché il linking fornisce un accesso diretto alla risorsa, poi resta da vedere il fattore pubblico. La corte dice che il pubblico sussiste perché il link raggiunge un pubblico, ma c'è da vedere se questo è nuovo o meno. Perciò ci si chiede qual è il pubblico considerato dagli autori nel momento in cui mettono in rete i propri articoli. Svensson e gli altri hanno pubblicato una serie di articoli che non richiedono abbonamenti o password, dunque il pubblico a cui hanno accettato di rendere visibili le loro opere è potenzialmente composto da tutti coloro che accedono al loro sito. Quindi, se intendiamo che il pubblico di Svensson è tutto internet allora il link che si trova sull'altro sito non raggiunge un pubblico nuovo, perché si rivolge sempre al mondo di internet. Si aggiunge, inoltre, un passaggio, la Corte precisa che la soluzione non sarebbe stata la stessa se il sito fosse stato protetto da password, caso in cui il link raggiunge un pubblico più ampio di quello considerato dall'autore

Es. **Sentenza GS Media** → del 8/09/2016, in questo caso le opere oggetto da contendere erano fotografie. Vi erano ritratti fotografici di un'attrice e modella destinati ad essere pubblicati sulla rivista playboy, la pubblicazione non era ancora avvenuta, quindi c'era tutto l'interesse da parte della società editrice di tenere riservate le fotografie. Ci fu una fuga di dati e queste foto vennero pubblicate su un sito Australiano, con pochi visitatori e mal posizionato, però una testata giornalistica (GS Media) aveva, nel mentre, ricevuto una mail con un link che puntava alle fotografie su quel sito australiano. Dunque, il giornale decise di fare un articolo pubblicando in esso un link che puntava alle foto sul sito australiano che era liberamente accessibile. L'editore di playboy fece causa, e il giudice olandese chiese alla Corte di Giustizia se in questo caso ci fosse una messa a disposizione al pubblico. La corte applicò gli stessi principi applicati per la sentenza Svensson, ma con un piccolo correttivo, anche in questo caso prese in considerazione la comunicazione col pubblico, ma per quanto riguarda il

concetto di pubblico nuovo qui è un pochino diverso, perché quando c'è un pubblico nuovo, l'atto di comunicazione diventa illecito. Se è presente sia l'atto di comunicazione che un pubblico nuovo, siamo di fronte ad una attività di comunicazione al pubblico e quindi un'attività riservata all'autore. Perciò in questo caso il pubblico raggiunto dal link era un pubblico nuovo, perché è vero che il sito australiano è visibile da chiunque, ma il pubblico di questo sito non era stato considerato dal titolare dei diritti, in realtà nessun pubblico era stato considerato dal titolare dei diritti perché le fotografie erano inedite e sarebbero state pubblicate soltanto in seguito. Quindi il link pubblicato da GS Media amplia il pubblico considerato dalla rivista *playboy*, titolare dei diritti d'autore. La sentenza GS Media si preoccupa anche di tutelare l'eventuale buona fede del soggetto che predispone un link, in questo caso era giusto che GS Media risarcisse i danni al titolare dei diritti, ma in alcuni casi bisogna tutelare la buona fede di chi pubblica un link che punta ad un sito accessibile a tutti.

La corte di giustizia dice che per avere comunicazione al pubblico, in un caso come quello della GS Media, occorre che vi sia anche la consapevolezza da parte di chi realizza il link del fatto che il sito bersaglio del link contenga o pubblici opere senza autorizzazione dell'autore, quindi che ci sia la consapevolezza dell'illiceità della presenza sul sito bersaglio del link delle opere. Se questa consapevolezza non c'è allora non è realizzata una comunicazione al pubblico. Certo è che se ci fermassimo qui ci sarebbe un problema, in quanto l'autore dovrebbe dimostrare che chi ha pubblicato il link sapeva dell'illiceità della presenza sul sito bersaglio del link delle opere, questa è una prova difficile, perciò la corte ha aggiunto un ultimo passaggio, quindi afferma che la consapevolezza dell'illiceità si presume quando il link è fatto a scopo di lucro.

Piattaforme di condivisione di contenuti online

Un altro problema relativo alla comunicazione al pubblico è quello sulle **piattaforme di condivisione di contenuti online**. La piattaforma di condivisione di contenuti, tipicamente, non carica direttamente i contenuti ma si limita a dare ai suoi utenti la possibilità di mettere a disposizione del pubblico dei contenuti, quindi si limita a fornire un servizio ai suoi utenti.

Nel caso in cui gli utenti caricano contenuti protetti da diritto d'autore senza l'autorizzazione da parte del titolare dei diritti?

In questo caso si realizza una comunicazione illecita al pubblico, e quindi il titolare dei diritti potrà chiedere all'utente di rimuovere il contenuto illecito. Questa è una

soluzione poco soddisfacente per il titolare dei diritti, poiché gli utenti sono tanti ed è difficile andare a trovarli, quindi se il titolare dei diritti vuole tutelare i propri interessi si trova di fronte a dei costi che non sono proporzionati al beneficio che può ottenere.

Ci sono anche problemi pratici relativi all'individuazione del soggetto che ha messo a disposizione il contenuto, in quanto bisognerebbe chiedere alla piattaforma i dati relativi alle connessioni.

Il titolare dei diritti può agire anche nei confronti della piattaforma in modo da avere come controparte un unico soggetto e risolvere il problema con una sola azione nei confronti di un unico soggetto?

L'interpretazione dominante valorizza il fatto che il gestore della piattaforma ha un ruolo attivo nella selezione dei contenuti. In parte, la legge ha risolto la questione nel 2021, introducendo nella legge sul diritto d'autore il nuovo articolo **102sexies**, che prevede espressamente che la piattaforma realizzi un atto di comunicazione al pubblico dei contenuti caricati dagli utenti. Quindi, quando un utente carica un contenuto, al suo fianco c'è anche la piattaforma che realizza una messa a disposizione al pubblico.

Es. **Sentenza Renckhoff** → del 7/08/2018. Degli alunni di una scuola avevano caricato i loro lavori sul sito della scuola e con questi anche una fotografia, i cui diritti appartenevano a un certo Renckhoff, che si lamentò del fatto che la foto era stata caricata senza il suo consenso. È chiaro che per caricare una foto su un sito l'uploader la deve riprodurre poiché la deve memorizzare quantomeno sul server, però in alcuni casi la riproduzione è liberalizzata, infatti ci sono delle regole che si chiamano utilizzazioni libere che intervengono a liberalizzare alcune attività che astrattamente rientrerebbero nell'esclusività dell'autore. I casi in cui la riproduzione è liberalizzata sono più frequenti dei casi in cui è liberalizzata la comunicazione al pubblico, talvolta è possibile riprodurre l'opera altrui ma non è possibile comunicarla al pubblico. In questo caso venne applicato il diritto tedesco, ma si può immaginare che la riproduzione fosse liberalizzata, e allora diventò fondamentale verificare se col caricamento della foto, gli scolari avevano realizzato comunicazione al pubblico, è chiaro che chi carica una foto su un sito realizza una comunicazione, ma resta la questione del pubblico. La ricostruzione del fatto, poi esposta dalla corte, ci segnala che la foto era liberamente accessibile a tutti sul sito del fotografo e quindi se applicassimo il principio visto

in precedenza, diremmo che il pubblico non è nuovo perché l'opera è già accessibile a tutti online e siccome è stata resa accessibile online dall'autore è chiaro che quest'ultimo ha considerato come potenziale pubblico tutto il pubblico della rete. Allora si potrebbe dire che gli scolari non avevano raggiunto un pubblico nuovo, ma la corte di giustizia giunse alla soluzione apposta, cioè è vero che l'autore aveva considerato come pubblico tutta la massa dei potenziali utenti di internet, però è anche vero che caricare un'opera protetta su un sito è una cosa diversa dalla semplice predisposizione di un link, e in particolare è un'attività (il caricamento in internet) più pericolosa del linking.

Che differenza c'è tra predisporre un link e caricare sul proprio sito un'opera protetta ?

Chi clicca sul link viene indirizzato sul sito del titolare dei diritti quindi il titolare trae il beneficio dal link anche in termini di visualizzazioni. Se l'autore decide che non vuole più mettere a disposizione di tutti la foto la cancella dal suo sito oppure richiede ai suoi utenti di pagare qualcosa, perciò se l'attività del terzo è meramente un'attività di linking non è un problema perché il link non permette più di vedere la foto, ma se il terzo fa un caricamento parallelo rispetto a quello dell'autore su un altro sito, la fotografia persisterebbe sul sito del terzo.

La Corte perciò afferma che è vero che il pubblico, oggi, è il medesimo perché la fotografia è ancora accessibile sul sito dell'autore, ma da un giorno all'altro il pubblico potrebbe diventare nuovo, e allora i diritti d'autore ci sono perché hanno una **funzione precauzionale**, cioè prevengono un illecito anche prima che questo avvenga ed è alla luce della natura anche precauzionale di questo diritto che dobbiamo interpretare il concetto di pubblico nuovo nell'ambito della comunicazione al pubblico, e quindi bisogna ritenere che il pubblico raggiunto dalla fotografia raggiunge un pubblico nuovo, anche se sarebbe in realtà solo potenzialmente nuovo, bisogna ritenerlo come nuovo.

Vi è anche un altro accorgimento della Corte, l'attività di linking ha una funzione importante nella logica della rete di internet e quindi va incentivato, invece ricaricare parallelamente all'autore un'opera protetta non merita il medesimo incentivo del linking.



Art. 17 della 633 del 41 → riguarda **il diritto di distribuzione** che ha per oggetto la messa in commercio degli esemplari di un'opera (la vendita delle copie in sostanza).

Dunque l'autore ha anche il diritto di controllare la messa in circolazione delle copie della sua opera.

Comma secondo art. 17 → aggiunge che questo diritto non si esaurisce nella comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento sia effettuato dal titolare dei diritti o con il suo consenso.

Norma poco chiara.

Mettendola in positivo, si legge che il diritto di distribuzione si esaurisce con la prima vendita realizzata dal titolare o con il suo consenso.

Il diritto di distribuzione in linea di principio consentirebbe all'autore di controllare qualsiasi vendita di esemplari della sua opera, quindi anche le vendite successive.

Es. l'autore vende una copia del suo libro, se ci fermassimo al primo comma chi ha acquistato il libro non potrebbe rivenderlo senza chiedere il consenso all'autore perché è un atto di distribuzione.



Ora esistono delle regole che permettono anche la rivendita di una copia poiché si pensa che l'autore ha già avuto modo di trarre profitto su quel esemplare specifico, quindi non avrebbe molto senso trarne altro per tutte le vendite dello stesso esemplare, si tratta del **principio dell'esaurimento**, per cui l'acquirente può rivendere tranquillamente la copia, in questo senso si dice che il diritto di distribuzione "si esaurisce".



Principio dell'esaurimento → *Su ogni esemplare il diritto di distribuzione può essere esercitato una volta sola.*

L'esaurimento dunque riguarda gli esemplari dell'opera, la singola copia e la fattispecie che realizza l'esaurimento è la messa in commercio della singola copia.

Questo, di cui ci siamo occupati finora, è **l'esaurimento interno** poiché nel diritto d'autore vige il principio di territorialità.

Chi ha acquistato un esemplare in Italia può tranquillamente rivenderlo in Francia ad esempio?

Ci si è posto questo problema proprio per il **principio di territorialità**, è vero che esiste il principio secondo cui quando l'autore vende una copia perde il principio di distribuzione ma se il diritto d'autore è territoriale, l'autore ha in Italia un diritto d'autore e in Francia ne ha un altro, quindi se ci fermassimo a quanto detto finora dovremmo concludere che si è esaurito solo il diritto di distribuzione italiano, mentre in Francia l'autore dovrebbe ancora avere il diritto di controllare le distribuzioni del medesimo esemplare.

Vi sono esempi molto più complicati che riguardano la questione,

Es. le importazioni parallele → una società compra in uno Stato una grande quantità di esemplari di un'opera dell'ingegno per rivenderli in un altro Stato, qui l'autore ha un interesse a poter vietare queste importazioni non controllate da lui, poiché l'autore può rivendere ad un prezzo in Italia e ad un altro in Francia, in quanto le condizioni di mercato sono diverse tra Stato a Stato. Il soggetto che, invece, fa l'importatore ha un interesse simmetrico e opposto nel poter comprare ad un prezzo inferiore e andare a venderli nello Stato in cui l'autore li rivende a un prezzo più alto. La questione è finita davanti alla corte di giustizia, che ha affermato che è vero che il diritto d'autore è regolato dal principio di territorialità e quindi che il diritto d'autore di uno Stato è diverso da quello di un altro, però all'interno dell'Unione Europea c'è anche il **principio** (uno dei pilastri fondamentali dell'Unione Europea) **della libera circolazione delle merci**, quindi, l'interesse dall'autore a praticare prezzi diversificati a seconda dello Stato è un interesse contrario al principio europeo, perciò non merita di essere tutelato. In particolare, questo principio non è del tutto inderogabile, anzi anche il diritto d'autore è di per sé un limite alla libera circolazione delle merci, proprio perché comporta un monopolio dell'autore sulle utilizzazioni dell'opera dell'ingegno.



Art. 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea → rivolto ai legislatori e non al singolo cittadino. Sono ammesse le restrizioni alla libertà di circolazione delle merci se sono giustificate da ragioni di tutela di proprietà intellettuale.

Secondo la Corte di Giustizia le ragioni di tutela della proprietà intellettuale non sono sufficientemente rilevanti nel caso in cui l'autore abbia già autorizzato la messa a

circolazione in commercio di un esemplare di un'opera. **In seguito all'affermarsi di questa lettura della Corte di Giustizia, lo Stato italiano ha aggiunto questo comma secondo dell'articolo 17.** Questo invece era l'**esaurimento comunitario/europeo**.

Accanto a questi due tipi di esaurimenti, esiste anche un terzo livello di esaurimento "internazionale"? Un soggetto può acquistare degli esemplari in america e rivenderli in Europa?

Si tende a dire, o per lo meno la Corte di Giustizia tende a dire di no. Secondo l'opinione prevalente, accolta anche dalla corte, l'autore conserva il diritto di controllare le importazioni da Stati esterni all'Unione Europea a Stati dell'Unione Europea, quindi si dice anche che **la vendita di un esemplare al di fuori dell'Unione Europea non comporta l'esaurimento del diritto di distribuzione su quel esemplare**, almeno dal punto di vista del nostro diritto d'autore. Possiamo capire quanto sia fondamentale determinare se un'attività è di comunicazione al pubblico o di distribuzione.

Es. il problema si pone in particolare nel campo dei software e degli ebook → fino a un po' di anni fa, chi voleva acquistare la disponibilità di un software comprava un dischetto, che costituiva un esemplare dell'opera dell'ingegno software, quindi la vendita del dischetto comportava l'esaurimento del diritto di distribuzione su di esso, quindi chi aveva acquistato uno o più dischetti li poteva rivendere. Oggi nessuno vende più i dischetti, ma si dice che si vendono **licenze d'uso**, cioè nel momento in cui l'utente paga riceve delle credenziali che gli consentono di scaricare una copia del software da internet.

La vendita della licenza realizza una distribuzione di un esemplare del software oppure no? C'è soltanto una messa a disposizione del pubblico?

Il punto è fondamentale, perché se abbiamo soltanto la messa a disposizione del pubblico, non opera il principio di esaurimento, se invece abbiamo anche un atto di distribuzione, opera il principio e chi acquista la licenza la potrà rivendere. C'è stato un lungo dibattito al termine del quale si ritiene che, quanto meno quando la licenza è perpetua, c'è un atto di distribuzione di una copia che viene scaricata, quindi opera il principio di esaurimento. Lo stesso problema si è posto anche per gli *ebook* e qui la soluzione è opposta, cioè la Corte di Giustizia ritiene che il principio

dell'esaurimento non operi, quindi il rapporto tra il fornitore dell'ebook e l'utente si risolve in una mera messa a disposizione del pubblico con eventualmente una collaterale facoltà dell'utente di farsi una sua copia dell'ebook, ma non vi è anche un atto di distribuzione. Le ragioni sono molte, una delle quali è che, se si pensa al software, non c'è tanta differenza tra acquistare un dischetto e acquistare il diritto di scaricare una copia del software, anzi è la stessa cosa. Invece se si pensa al libro c'è una differenza rilevante tra l'acquisto di un esemplare cartaceo e l'acquisto del diritto di scaricare una copia dell'ebook, il cartaceo si deteriora e l'usato ha un valore inferiore, invece nel caso dell'ebook non si realizza alcun deterioramento e quindi il mercato degli ebook usati si sovrapporrebbe direttamente con il mercato degli ebook direttamente venduti dall'autore



Art. 18 → relativo al **diritto di elaborazione**, chi realizza un'elaborazione di un'opera preesistente deve rispettare i diritti del titolare del diritto d'autore sull'opera preesistente. L'autore ha il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modifica, ciò significa che l'autore ha diritto esclusivo di autorizzare o vietare di introdurre agli altri modifiche.

Questo diritto esclusivo di elaborazione si estende anche fino a consentire all'autore di proibire le modifiche che vengono modificate anche solo in ambito privato ?

Si ritiene che la risposta debba essere negativa, chiunque in privato può apportare le modifiche che desidera, il motivo è che ognuno deve essere libero di creare e la libertà creativa deve essere tutelata fino a che il suo esercizio non mette in pericolo gli interessi del titolare del diritto d'autore, e il titolare del diritto d'autore non ha alcun interesse nel controllare che il privato non modifichi la sua opera se poi se la terrà per sé.



Art. 19 → i diritti indicati dagli articoli precedenti sono tra loro indipendenti, l'esercizio di uno non comporta anche l'esercizio di un altro, cioè l'autore può esercitare separatamente i suoi diritti, può autorizzare a un terzo la riproduzione, ma non la comunicazione al pubblico o neanche comunicare al pubblico la forma modificata.

Tutte queste facoltà di utilizzazione esclusiva dell'autore sono tra loro indipendenti.



Cessione dei diritti d'autore → i diritti d'autore visti finora, cioè i diritti patrimoniali dell'autore, sono disponibili, l'autore li può cedere in blocco, oppure uno sì ma non l'altro.

Esiste una regola secondo cui la trasmissione dei diritti d'autore deve essere provata per iscritto, quindi è necessario che da uno scritto risulti quanto meno che i diritti sono stati trasferiti.

Non bisogna confondere la cessione dei diritti d'autore con la cessione degli esemplari dell'opera dell'ingegno poiché la vendita, la cessione, la donazione non comporta alcuna cessione di diritti d'autore.

I diritti morali d'autore



Diritti morali d'autore → tutti i diritti sono morali, la parola "moralì" sta a significare il fatto che sono ***diritti che riguardano e che tutelano gli aspetti della personalità dell'autore***, si contrappongono quindi ai diritti patrimoniali.

Tuttavia, già grazie ai diritti patrimoniali l'autore può tutelare anche i propri interessi della personalità.

Es. l'autore ha diritto esclusivo di utilizzazione economica e quindi potrà opporsi a qualsiasi utilizzazione anche a quelli che eventualmente lo possono offendere.

Se qualcuno pubblica un'opera con modificazioni tali da offendere l'onore dell'autore e lo fa senza aver acquistato i diritti patrimoniali o senza consenso, l'autore si potrà opporre a questa utilizzazione esercitando già solo i diritti patrimoniali. Però i diritti

patrimoniali sono comunque disponibili: l'autore può averli venduti, regalati o possono essere passati al datore di lavoro se il lavoratore è un dipendente, in questi casi all'autore non rimangono più i diritti patrimoniali, dunque la legge si preoccupa di garantire all'autore qualche diritto anche nel caso in cui non abbia più quelli patrimoniali, in particolare questi diritti garantiti comunque sono quelli morali.

I diritti morali d'autore:

- **Inalienabili** → non si possono vendere e disporre in alcun modo (a differenza di quelli patrimoniali)
- Hanno una **durata illimitata**

Il diritto d'autore patrimoniale non è infinito, infatti nasce con la creazione dell'opera e dura per tutta la vita dell'autore e 70 anni dopo la sua morte, l'idea è che durino per altre 3 generazioni.

Che sorte ha il diritto morale alla morte dell'autore?

Essendo un diritto inalienabile l'autore non può decidere a chi trasferirli alla sua morte perché non ne può disporre, allora la legge prevede espressamente che **dopo la morte dell'autore i diritti morali possono essere fatti valere da alcuni soggetti** espressi dalla legge:

- **Parenti**
- **Coniuge**
- **Figli**
- **Ascendenti**, in assenza di figli
- **Discendenti senza limiti di tempo**

L'autore non può decidere chi sarà l'autore dei suoi diritti morali, come tramite l'uso di un testamento, poiché questo sarebbe un atto di disposizione del diritto.

Es. un autore istituisce una fondazione a suo nome con la funzione di tutelare la sua produzione artistica, egli non potrà decidere che dopo la sua morte questa fondazione sarà legittimata a esercitare anche i diritti morali perché significherebbe trasferire questi diritti alla fondazione e abbiamo detto che questi diritti non sono trasferibili, quindi nel caso la fondazione richiedesse una cosa del genere la domanda verrebbe respinta.



Le fondazioni a nome di certi autori non possono richiedere i diritti morali dell'autore, poiché è come se l'autore li trasferisse ma i diritti morali sono inalienabili, non possono essere trasmessi.

In cosa consistono i diritti morali?

I diritti morali sono disciplinati negli **articoli 20 e seguenti**.



Art. 20 → l'autore ha il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, ha quindi **azione di rivendica**, cioè l'operazione con cui il proprietario di un bene chiede che gli sia consegnato, il proprietario può reperire questa azione poiché non ha il possesso materiale del bene

Es. sono proprietario di una cosa che è detenuta da un altro, questo non me lo vuole restituire, io posso reperire un'azione di rivendita.

In quest'ottica rivendicare la paternità dell'opera vuol dire riprendersi la paternità dell'opera che è stata sottratta da altri.

Possiamo dire che la paternità dell'opera è stata sottratta essenzialmente quando qualcun altro afferma di esserne l'autore, quindi **la paternità dell'opera è sottratta quando un soggetto diverso dall'autore si dichiara autore**.

Es. un'opera viene pubblicata indicando che l'autore è una persona diversa dall'autore reale.

C'è un punto da verificare, bisogna chiedersi: l'autore può anche opporsi a che gli vengano attribuite opere non sue?

È chiaro che l'autore può dire che quell'opera che è stata pubblicata a nome di un altro in realtà è la sua.

Ma può anche dire che quell'opera che gli è stata attribuita non l'ha fatta lui?

Tendenzialmente sì, però l'autore può tutelare questo suo interesse a non vedersi attribuite opere non sue non col diritto morale d'autore, ma esercitando il diritto al

nome riconosciutogli dal codice civile, cioè che il nome di questo soggetto è stato utilizzato abusivamente.

Questo diritto di paternità consente all'autore anche di pretendere che il suo nome venga indicato?

Riflettendo sul concetto di rivendica possiamo dire di sì, però non si sta negando la paternità del vero autore, semplicemente non la si indica. Dobbiamo quindi ritenere che il diritto di paternità **non consente in linea generale** all'autore di pretendere di essere indicato.

Es. **in via generale** → immaginiamo il caso di un'opera dovuta al contributo di più persone, l'opera composta da musica e parole o l'opera cinematografica, immaginiamo che l'opera venga pubblicata indicando soltanto alcuni autori, omettendo gli altri autori. In questo caso cosa diciamo? Gli autori non indicati potranno esercitare i loro diritti di paternità per vedersi indicati anche loro ? Potrà rivendicare la paternità dell'opera oppure no perché semplicemente non è stato indicato, un semplice comportamento omissivo che non consente la rivendicazione della paternità?

Questo è il caso in cui l'autore può pretendere di essere indicato in virtù del suo diritto di paternità, poiché ***indicare i nomi di soltanto alcuni fa pensare a chiunque che l'opera è stata realizzata soltanto da coloro che sono stati indicati***, quindi implicitamente c'è una negazione della paternità di coloro non indicati.

Accanto al diritto di paternità, troviamo il **diritto all'integrità dell'opera**, in particolare l



Art.20 → dispone che ***l'autore ha il diritto di opporsi a qualsiasi modificazione ed a ogni atto a danno dell'opera che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.***

Innanzitutto per modifiche intendiamo le elaborazioni, quindi qualsiasi cambiamento introdotto nell'opera. ***Atti a danno dell'opera***, concetto introdotto successivamente al '41, per adeguare la disciplina italiana a una revisione della convenzione di Berna, questo riferimento agli atti a danno dell'opera è stato introdotto perché c'erano alcuni casi di attività che generalmente venivano ritenuti potenzialmente pregiudizievoli per

gli interessi morali dell'autore, cioè vi era il dubbio che rientrassero nel concetto di modifica.

Es. la distruzione dell'esemplare unico di un'opera, chi lo sa se è una modifica o no? In realtà non viene modificato niente, semplicemente viene cancellata la possibilità per il pubblico di fruire dell'opera, allora si è aggiunto il riferimento agli atti a danno dell'opera.

Per capire meglio cosa si intende per atti a danno dell'opera possiamo metterci nella prospettiva del concetto di opera dell'ingegno. L'opera dell'ingegno è un modo per comunicare informazioni, è un modo con cui l'autore parla al suo pubblico e **quindi l'atto a danno dell'opera è un atto che rende più difficile all'opera lo svolgimento della sua funzione.**

Quindi la distruzione di un esemplare unico o la distruzione dell'esemplare originale, ma anche tante altre attività, possono rientrare in questi atti.

Es. immaginiamo che una scultura venga realizzata dall'autore per essere collocata nella piazza centrale di una città e venga spostata in un luogo vicino alla stazione metropolitana periferica con i rovi che si arrampicano sulla statua, esposta allo smog e si stia rovinando, questa è un'altra situazione in cui vi è un atto a danno dell'opera.

Dunque, modificazioni e atti a danno dell'opera sono due **presupposti alternativi**, è sufficiente l'uno o l'altro, **però** non basta che vi sia una modifica o un atto a danno dell'opera perché sia leso il diritto morale all'integrità dell'opera, le modifiche molto spesso non intaccano il diritto morale d'autore, tanto è vero che il concetto lo si ritrova nei diritti patrimoniali d'autore, quindi i due presupposti devono essere qualificati ulteriormente perché siano lesivi al diritto all'integrità dell'opera, **devono essere potenzialmente pregiudizievoli all'onore e alla reputazione dell'autore.**



Reputazione → si può dire che il concetto giuridico è analogo a quello sul dizionario, è *l'opinione che la collettività ha riguardo una persona, è la percezione che hanno gli altri hanno delle qualità di una persona.*

Onore → *percezione che una persona ha delle proprie qualità*

C'è un **limite al diritto all'integrità dell'opera**, nonostante sia un diritto inalienabile e illimitato, l'autore non può opporsi alle modifiche che ha conosciuto e accettato.

Es. caso tratto dalla giurisprudenza → era stato tratto un film da un'opera letteraria e il ruolo di protagonista era stato assegnato all'attore Alberto Sordi, egli

aveva uno stile di recitazione molto ben definito e caratteristico, chiunque sapeva che quel ruolo sarebbe stato interpretato in quel modo. L'autore del romanzo era stato informato della scelta del cast, quindi sapeva che Sordi sarebbe stato il protagonista, e aveva dichiarato di essere d'accordo, dopo l'uscita del film, ha pensato che fosse stata distrutta la psicologia del personaggio principale del suo romanzo e chiese di ritirare il film dalle sale. Il produttore però ha ribadito che avendo, l'autore, accettato che il ruolo fosse attribuito a Sordi, quantomeno implicitamente, aveva accettato anche le modifiche dei caratteri del personaggio che chiaramente ci sarebbero state con l'interpretazione dell'attore. Il giudice ritenne che il produttore avesse ragione in applicazione di quel principio secondo cui l'autore non può utilizzare il diritto all'integrità dell'opera per opporsi alle modifiche che ha conosciuto e accettato.

Da questa decisione ricaviamo che **l'accettazione delle modifiche può anche essere implicita.**

Altra precisazione che riguarda soltanto un tipo di opera, cioè le **opere dell'architettura**. In queste opere l'autore non si può opporre alle modifiche necessarie, questa regola ha la funzione di realizzare un bilanciamento tra l'interesse dell'autore e quello del proprietario, l'opera dell'architettura è un'opera che ha una grossa utilità pratica. Relativamente all'opera dell'architettura sussiste un valore ingente del fabbricato, dell'oggetto materiale, valore che presto supera quello del materiale, in virtù dei costi che sono richiesti dalla sua realizzazione, quindi la legge ha ritenuto che gli interessi confliggenti con quelli dell'autore andassero tenuti in particolare considerazione. Quindi il proprietario ha il diritto di modificare l'opera anche se la modifica può essere pregiudizievole per l'onore e la reputazione dell'autore, solo se la modifica è necessaria. Si apre quindi un mondo per capire quale modifica possa essere ritenuta necessaria, ma non teniamo conto della casistica. Finora il diritto all'integrità dell'opera è stato applicato prevalentemente nel mondo offline, però anche le decisioni emesse in anni relativamente recenti riguardavano praticamente tutte il modo materiale dell'offline.

Un caso abbastanza recente, riguardava un accostamento di un'opera di carattere divulgativo giuridico a dei van pubblicitari di contenuto erotico, in questo caso la decisione del tribunale di Bologna ha ritenuto che vi fosse una lesione del diritto all'integrità dell'opera in seguito a questo accostamento inadeguato.



Art. 142 → terzo diritto morale d'autore, diritto al ritiro dell'opera dal commercio, ***diritto di pentimento***.

Questo articolo dispone che l'autore ha il diritto di ritirare l'opera dal commercio qualora sussistano gravi ragioni morali.

Cosa sono le gravi ragioni morali?

Es. Un ripensamento politico → un autore in gioventù pubblica uno scritto in cui esprime le proprie idee anarchiche ma poi diventa un conservatore convinto, questo è il caso in cui l'autore ha un interesse qualificato e giustificato e che vi siano gravi ragioni morali che richiedono all'autore di non vedere più circolare quella sua opera, la legge consente quindi all'autore di pentirsi dell'opera e di ripudiarla.

L'esercizio da parte dell'autore di questo suo diritto è stato in gran parte frenato da due circostanze:

- L'autore che esercita questo diritto deve un indennizzo a chi ha acquistato il diritto di pubblicare l'opera, deve dargli un ristoro, quindi non proprio un risarcimento del danno.
- L'autore non potrà pretendere che vengano fatte sparire anche le copie già in circolazione.

L'effetto dell'esercizio di questo diritto riguarda solo le messe in circolazione dell'opera successive all'azione dell'autore, nel mondo della carta questo è un limite importante, mentre il quello digitale ci si può aspettare un'applicazione più estensiva di questa regola, quindi questo diritto morale è molto più utile.

Nel caso delle opere creative che vengono fatte da lavoratori dipendenti, il diritto d'autore nasce in capo all'autore. È vero che a titolo derivativo i diritti patrimoniali dell'opera vengono trasferiti al datore di lavoro, ma i diritti morali rimarranno comunque all'autore, per la loro inalienabilità.

Relativamente al concetto di disponibilità e indisponibilità, bisogna vedere come qualificare il patto ghostwriting, cioè il patto con cui l'autore si impegna ad essere un fantasma.

Es. io scrivo un'opera per te, tu la pubblichi col tuo nome come se l'avessi scritta tu e io non mi opporrò mai, mi impegno per non oppormi mai. Il professor Cogo ritiene che si può fare questo patto, però giunge alla conclusione con un'argomentazione complessa → il diritto di paternità ha la funzione di consentire

all'autore di partecipare alle decisioni relative alle modalità di pubblicazione dell'opera in modo più penetrante di quanto non gli consentirebbe di fare il diritto patrimoniale d'autore, però nel momento in cui l'autore è stato consultato e ha autorizzato la pubblicazione dell'opera senza il suo nome e soprattutto col nome di qualcun altro, il diritto di paternità ha esaurito questa sua funzione perché l'autore, tra l'altro, potrà chiedere un compenso supplementare per l'accettazione relativa alle modalità di pubblicazione col nome altrui.

Si tratta di una tesi molto raffinata, e per il momento l'interpretazione dominante presso i giudici è quella secondo cui il patto di ghostwriting è nullo perché il diritto di paternità è inalienabile e indisponibile e quindi si ritiene che impegnarsi a non rivendicare la non paternità, cioè impegnarsi a tollerare che l'opera sia attribuita ad altri, significa disporre del diritto di paternità. Questa è una tesi discutibile ovviamente.

Diritti connessi

Sono una galassia di diritti vicini al diritto d'autore, si chiamano così perché tutelano l'investimento in attività che hanno un valore culturale e per questa ragione sono vicine e connesse all'attività creativa. Questi diritti sono spesso modellati sull'esempio del diritto d'autore, quindi spesso sono dei diritti di tipo esclusivo, però a volte sono solo diritti a compenso, cioè non attribuiscono al titolare il potere di vietare ai terzi determinate utilizzazioni, ma soltanto quello di pretendere un compenso, inoltre, a differenza del diritto d'autore, talvolta sono sottoposti al compimento di formalità, cioè può succedere che una condizione per esercitare un diritto connesso è aver adempiuto ad alcune formalità, cosa assolutamente inconcepibile e vietata nel campo del diritto d'autore.

I diritti connessi hanno una durata che varia da un diritto connesso all'altro, più breve di quella del diritto d'autore, si va dai 20 per la tutela delle fotografie, ai 15 per la tutela delle banche dati, ai 50 per la tutela il produttore cinematografico.

Questi diritti sono e sono sempre stati tanti, noi ne vedremo un paio, uno riguarda le fotografie, opere dell'ingegno che possono essere protette dal diritto d'autore se esprimono qualcosa e se lo fanno in modo creativo. Questa non è l'unica forma di protezione per le fotografie, poiché c'è anche un diritto connesso.



Art. 87 e seguenti (sempre della legge 633) → questo diritto connesso tutela le fotografie che non possono beneficiare della tutela del diritto d'autore, quelle fotografie che sono chiamate fotografie semplici. Questa tutela non si estende fino a tutelare anche quelle foto che hanno mero scopo di documentazione, cioè **la fotografia che sostituisce la fotocopia non è protetta dal diritto connesso**. Questo diritto dura 20 anni, dal momento dello scatto della fotografia, e il diritto spetta al fotografo.

Caratteristica particolare di questo diritto connesso è che il suo esercizio è sottoposto al compimento di una formalità, cioè la legge richiede che le fotografie messe in circolazione dal fotografo rechino alcune indicazioni.



Art.90 → **deve essere indicato il nome del fotografo e l'anno dello scatto**, questo per consentire a chi voglia utilizzare una fotografia di sapere se è ancora protetta dal diritto connesso oppure no, ed eventualmente di consentirgli di andare a cercare il fotografo per chiedergli un'autorizzazione.

Se il fotografo non riporta queste indicazioni, secondo la legge, la riproduzione della fotografia non è considerata abusiva e il fotografo non può esercitare il proprio diritto. C'è un'eccezione però, la riproduzione della fotografia è comunque abusiva e quindi il fotografo può esercitare il suo diritto se la riproduzione è in mala fede, ad esempio se è consapevole dell'esistenza di esemplari che riportano quelle indicazioni. Il fotografo deve dimostrare che l'utilizzatore in quel momento sapesse che l'opera era ancora protetta. Talvolta però non è facile distinguere se una fotografia è protetta dal diritto connesso o se è protetta dal diritto d'autore perché valutare la creatività della fotografia è difficile, quindi di fronte a fotografie che non siano proprio palesemente banali, anche se manca il nome del fotografo e l'indicazione dell'anno conviene andare cauti perché se mancano le indicazioni e la fotografia non è protetta dal diritto d'autore ma soltanto dal diritto connesso allora si può utilizzare, ma se per caso è una fotografia creativa nell'utilizzarla e metterla a disposizione del pubblico si realizza un'attività lesiva al diritto d'autore, e si sa che il diritto d'autore non richiede il compimento di alcuna formalità.

A livello di contenuto, questo diritto è simile al diritto d'autore (diritto di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico).



Art. 87 e seguenti → attribuiscono espressamente al fotografo non creativo queste tre facoltà di utilizzazione esclusiva fondamentali.

1. **Primo livello** di tutela del diritto d'autore per le fotografie che sono opere dell'ingegno e che sono creative.
2. **Secondo livello**, del diritto connesso per le fotografie semplici
3. **Terzo livello**, disciplina delle fotografie di semplice documentazione che non prevede alcuna tutela.

L'ultimo diritto connesso che affronteremo riguarda le banche dati, perché serve per determinare dove finisce il diritto d'autore, anche qui bisogna coordinare il diritto connesso con quello d'autore. Le banche dati, cioè raccolte d'informazioni possono essere protette dal diritto d'autore e rientrano anche nell'elenco dell'art. 2 della legge sul diritto d'autore, esse sono protette quando sono opere dell'ingegno di carattere creativo. Quando la banca dati non è creativa e non trasmette alcuna informazione particolare che vada oltre alla semplice accessibilità dei dati raccolti può essere tutelata, la banca dati che non sia opera dell'ingegno può essere tutelata da questo diritto connesso.

Es. un elenco telefonico o un insieme di dati sanitari di un ospedale sono esempi di banche dati ma non creative, si limitano a rendere accessibili i dati contenuti. Vi sono infatti dei presupposti perché una banca dati possa essere protetta da questo diritto connesso:

- La banca dati deve aver richiesto un investimento rilevante, questo requisito serve a evitare di tutelare quelle banche dati che sono un semplice sottoprodotto di un'altra attività.
 - Es. dati sanitari di un ospedale, finché questi sono semplicemente costituiti da una somma di cartelle cliniche non c'è stato un investimento rilevante per la realizzazione della banca dati. Se invece l'ospedale fa delle operazioni per riuscire a rendere anonimi completamente i dati, allora affronta un investimento supplementare proprio per creare una banca dati con una certa caratteristica sussiste il requisito dell'investimento rilevante
- Il diritto sulla banca dei dati spetta a chi ha fatto l'investimento rilevante, dura per 15 anni dalla creazione, con una particolarità, questi 15 anni si riducono se la banca dati viene pubblicata. Quindi, i due periodi possono anche

sommarsi, se la banca dati viene creata e quindi comincia a decorrere per 15 anni e appena prima della scadenza della protezione viene pubblicata riparte un altro periodo di 15 anni. Se la pubblicazione viene prima della scadenza, decorrono i 15 anni da quel periodo in cui viene pubblicata.

- Dopo sette anni dalla creazione ci saranno 22 anni di protezione.

Il motivo del diritto non è solo incentivare l'investimento ma anche incentivare la pubblicazione.

Le regole che abbiamo visto finora puntano a proteggere l'autore però tengono conto anche degli interessi confliggenti, ne tengono conto nella misura in cui le regole di protezione dell'autore consentono al creativo di avere un'esclusiva che non si estende anche al contenuto. La legge ha scelto di lasciare libero il contenuto proprio per bilanciare l'interesse dell'autore con gli interessi degli altri a utilizzare liberamente la conoscenza. Le regole di protezione dell'autore tutelano anche indirettamente i soggetti diversi dall'autore, abbiamo visto che una delle ragioni per cui è protetto il diritto d'autore è che la costituzione prevede che la repubblica incentivi e promuova il progresso culturale, quindi la legge riconosce una tutela all'interesse dell'autore perché ritiene che ciò sia conforme a un interesse generale. La tutela degli interessi che confliggono con gli interessi dell'autore non è affidata soltanto alla conformazione del diritto esclusivo che emerge dalle norme che abbiamo visto, ci sono delle **regole puntuali che troviamo negli articoli 65 e seguenti** che individuano situazioni specifiche in cui il diritto d'autore viene limitato a tutela dei particolari interessi delle persone diverse dall'autore, queste regole si applicano tanto al diritto d'autore quanto ai diritti connessi.

Queste regole si possono chiamare sia **eccezioni**, poiché derogano ai principi generali in materia d'autore, che **utilizzazioni libere**, perché identificano delle fattispecie in cui l'utilizzazione di un'opera dell'ingegno è possibile anche senza il consenso dell'autore. La parola eccezioni ci suggerisce di mettere a fuoco **tratti comune** di queste regole:

1. Non tutte le regole dell'ordinamento giuridico si possono applicare analogicamente, e in particolare **le norme eccezionali non possono essere applicate per analogia**, se queste sono eccezioni tendenzialmente non possono essere applicate al di fuori dei casi espressamente considerati nelle norme medesime.
2. **Non consentono mai utilizzazioni che siano in concorrenza con quelle dell'autore**, quindi l'esistenza di un'eccezione, o utilizzazione libera, non

potrà mai essere fatta valere per realizzare utilizzazioni in concorrenza con quelle dell'autore.



Questo principio deriva **dall'articolo 9 della convenzione di Berna**, introduce un triplice test, cioè una verifica in tre passaggi, perché prevede che **le eccezioni al diritto d'autore sono legittime solo se rispettano tre condizioni**, una delle quali è appunto la caratteristica di non liberalizzare delle fattispecie che si pongono in concorrenza con le utilizzazioni dell'autore.

Ci sono alcune **regole specifiche per i software** che non fanno parte degli art. 65 e seguenti, ma degli **art. 64 Ter e Quater**. La struttura degli articoli 65 e seguenti non è molto ordinata a causa di regole aggiunte in seguito al 1941, alcune ancora l'anno scorso, non sempre nella collocazione ottimale.

- **Prima utilizzazione libera** la troviamo nell'articolo 65 → secondo questo articolo, ***gli articoli pubblicati su riviste o giornali possono essere ripubblicati in altre riviste o giornali se la riproduzione non è stata riservata.***

Per riviste e giornali intendiamo tutti i mezzi di comunicazione che hanno la funzione di informare e che non presentano la funzione di documentare in modo permanente.

Es. il giornale è fatto per essere letto e poi gettato, il libro invece non ha questa funzione.

Questa precisazione serve nel momento in cui ci chiediamo se questa regola è applicabile o meno anche al mondo di internet.

Come interpretiamo, relativamente in Internet, il concetto di rivista o di giornale?

In Internet possono rientrare nella nozione di rivista e giornali, anche i siti telematici di informazione e non quelli di documentazione. Possiamo considerare rivista o giornale telematico un sito le cui opere o articoli sono destinati a essere cancellati dopo un certo lasso di tempo. Quando, invece, gli articoli continuano ad essere fruibili senza limiti di tempo, il sito non è considerato rivista o giornale ai fini dell'applicazione di questa norma. In assenza di scopo di informazione, quindi anche di scopo di documentazione, la regola non sarà applicabile. Inoltre

la regola si applica a condizione che la non sia riservata, quindi nel caso in cui il titolare dei diritti d'autore ha il potere di evitare l'applicazione di questa eccezione apponendo una **dichiarazione di riserva**



L'articolo 65 non si applica se l'autore ha apposto questa dichiarazione di riserva. Ecco perché frequentemente gli articoli giornalistici sono accompagnati all'inizio o alla fine dalla dicitura "dichiarazione riservata".

A questo punto, ci si chiede, in che rapporti si colloca questa regola sulla dichiarazione di riserva con il divieto di formalità costitutiva?

L'articolo 65 sottrae all'autore una parte del suo diritto esclusivo, poiché rende liberamente riproducibili alcune opere, ma allo stesso tempo consente all'autore di riappropriarsi del suo diritto scrivendo la dichiarazione riservata. Quando l'autore titolare dei diritti non compie questa formalità non potrà esercitare il suo diritto esclusivo nei confronti di chi riproduce l'articolo in un'altra rivista o giornale.

Effettivamente, questa dichiarazione di riserva è una formalità, ma è consentita perché fonda le sue radici nella convenzione di Berna. Il divieto di formalità costitutive deriva dalla convenzione di Berna, però la stessa prevede che gli Stati possono introdurre un'eccezione fatta come quella dell'articolo 65 salvo che ci sia la dichiarazione di riserva, è questo il motivo per cui nonostante sia una formalità è legittima, è legittimata dalla stessa convenzione di Berna.

Sempre **l'articolo 65** prevede inoltre che è consentita anche **l'utilizzazione per fini di cronaca giornalistica** dei discorsi tenuti in pubblico, qui la funzione è quella di tutelare la libertà di informazione e il diritto di cronaca.



Art. 67 → consente le **utilizzazioni** di opere dell'ingegno **necessarie per fini di pubblica sicurezza o nelle procedure giudiziarie o amministrative**, se un soggetto deve fare valere un diritto in giudizio e per farlo valere deve mostrare al giudice un'opera dell'ingegno riprodotta lo può fare senza dover chiedere il permesso all'autore.



Art. 68 → riguarda la **copia privata**, innanzitutto dice che è libera la riproduzione realizzata dai privati per loro uso personale se è fatta con mezzi non tecnologici, si può trascrivere interamente un discorso che sentiamo senza chiedere alcunché.

Invece questa regola non si applica alla riproduzione che avviene con mezzi tecnologici.

Es. prendere appunti rientra in questa regola, ma già la registrazione rientra nel diritto d'autore e quindi lo studente dovrà chiedere il permesso.



L'articolo 68 riguarda anche la **fotocopia** → è possibile la fotocopia da parte del privato nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo. Questo limite del 15% non si applica però se l'opera fotocopata è fuori commercio, poiché per la legge l'interesse dell'autore è meno forte e rilevante. Per le biblioteche, in cui è possibile fare fotocopie, i limiti sono un po' diversi, non c'è il limite del 15%.

Occorre aggiungere che la legge ha affrontato un **meccanismo particolare per tutelare gli interessi anche dell'autore**, che si vede fotocopiate le opere in applicazione di questa eccezione, in particolare è previsto che i **titolari dei centri di riproduzione**, e anche le biblioteche che hanno fotocopiatrici, **devono pagare un tot all'anno**, una percentuale in ragione del numero di copie realizzate, questo compenso viene pagato alla SIAE, ente che gestisce i diritti d'autore.

SIAE



SIAE → gli enti di gestione collettiva del diritto d'autore

Nel campo del diritto d'autore c'è un problema di inefficienza del mercato, perché l'opera dell'ingegno è un'opera immateriale quindi non si trova in un luogo dove c'è anche un soggetto con cui parlare o a cui chiedere il permesso per utilizzare l'opera. Nel caso delle opere dell'ingegno possono esserci difficoltà a individuare quale sia il soggetto a cui chiedere l'autorizzazione per poter utilizzare l'opera, e

dato che il diritto d'autore vieta le formalità costitutive risulta difficile capire come e a chi chiedere l'autorizzazione.

A partire dalla fine dell'800 hanno cominciato a sorgere delle società che avevano la funzione di gestire i diritti degli autori loro soci, tanti autori si mettevano insieme in modo da costituire un'associazione per gestire i loro diritti d'autore. Queste attività, in un primo tempo, sono state realizzate da società comuni, poi c'è stato un periodo in cui i legislatori di vari Stati, tra cui l'Italia, hanno riservato questa attività di gestione dei diritti d'autore ad un unico soggetto, che in **Italia era la SIAE**, perché si era ritenuto che un unico grande soggetto potesse svolgere meglio il compito, rispetto a tanti soggetti frammentati, dato che può gestire un'organizzazione di filiali presenti in modo capillare sul territorio nazionale cosicché l'utente possa avere un punto di riferimento per acquistare le licenze di cui ha bisogno facilmente, d'altro canto se il soggetto che gestisce è unico per tutti gli autori c'è anche il vantaggio che per l'utilizzatore non soltanto è comodo ma non deve neanche verificare a quale delle società di gestione collettiva l'autore che interessa abbia aderito. Se c'è solo la SIAE, l'utilizzatore è sicuro che andando alla SIAE potrà acquistare le licenze di cui ha bisogno senza verificare se l'autore che gli interessa è in un'altra società.

Negli ultimi anni, invece, si è tornati indietro perché si è proceduto a liberalizzare l'attività di gestione collettiva dei diritti d'autore che oggi può essere fatta da soggetti diversi dalla SIAE, soggetti che devono comunque avere alcune caratteristiche indicate dalla legge, c'è stata quindi un'apertura e liberalizzazione.

Alcune prerogative sono rimaste alla SIAE, i compensi per copia privata devono comunque essere versati alla SIAE, invece la piattaforma che deve munirsi delle licenze per la messa a disposizione del pubblico dovrà aver cura di ottenere delle licenze anche dagli enti di gestione collettiva diversi dalla SIAE.



Articoli 71 sexies e seguenti → si tratta di norme novelle, introdotte in seguito.

Questi articoli riguardano la **copia privata di fonogrammi e videogrammi**, in particolare si dispone che chi è in possesso legittimamente di un esemplare materiale di un'opera dell'ingegno può farsene una copia. Questa copia deve essere per uso esclusivamente personale, quindi non può circolare sul mercato.

Es. se si acquista un CD fisico in un negozio si può fare una copia in applicazione di questa regola, la legge aggiunge che se il titolare dei diritti ha apposto delle misure tecnologiche di protezione che impediscono la copia l'utente in teoria può pretendere la disattivazione.

*C'è da chiedersi, qual è la disciplina relativamente al **mondo digitale**?*

Relativamente alle opere messe a disposizione del pubblico in internet, la copia privata è consentita solo a **due condizioni**:

- **Se non è vietata contrattualmente** → cioè se sul sito non c'è scritto che è vietato il download
- **Se non ci sono misure tecnologiche che impediscono il download**

Quindi c'è una disciplina di maggior rigore per il download rispetto a quella prevista per la copia di esemplari fisici.

Es. la piattaforma YouTube non consente di fare il download, questo è anche vietato dalle condizioni generali del sito. Recentemente c'è stata una modifica che consente a chi possiede l'abbonamento di fare il download.

Se invece il sito non vieta il download, e questo è materialmente possibile senza dover ricorrere software particolari che consentano il download, è possibile lo scaricamento e la conservazione della relativa copia.

Le due condizioni devono valere entrambe, basta che difetti l'una o l'altra e il download non è lecito.

Questa disciplina degli articoli 71 sexies e seguenti riguarda la copia privata soltanto di:

- **Fonogrammi** → fissazioni di suoni
- **Videogrammi** → sequenze di immagini in movimento accompagnate o meno dal sonoro.

Per le opere che appartengono ad altre categorie non abbiamo una disciplina della copia privata e non possiamo nemmeno applicare analogicamente le norme viste adesso, poiché si tratta di eccezioni.

Anche per questa copia privata di fonogrammi e videogrammi è previsto un pagamento di compensi alla SIAE. I compensi per la copia privata di fonogrammi e videogrammi vengono corrisposti col **sistema del prelievo**. La legge prevede

che il produttore di un supporto che può essere utilizzato per effettuare copie private deve pagare un compenso in ragione della capacità di memorizzazione del supporto. Quindi quando si acquista una chiavetta USB, un computer, un telefono, un CD ecc. non si paga solo il prezzo che corrisponde al costo di produzione più il profitto imprenditoriale del fabbricante o del venditore, ma si paga anche un ammontare ulteriore che corrisponde al compenso che il fabbricante o l'imperatore ha pagato alla SIAE .



Articolo 68 bis → riguarda le **riproduzioni temporanee**.

A certe condizioni questa riproduzione temporanea è libera, in particolare sono libere quelle riproduzioni destinate fin dall'origine ad essere cancellate automaticamente, che sono parte integrante di un procedimento tecnologico.

Es. qualsiasi elaboratore (computer, smartphone...) per elaborare i dati ha bisogno di fare delle copie su una **memoria RAM**, le copie nella memoria RAM sono un esempio di copia che è parte integrante di un procedimento tecnologico, oppure anche i decoder televisivi.

Poi, un altro requisito importante è che **queste copie temporanee devono anche essere prive di un rilievo economico proprio**, cioè può avere rilievo economico l'effetto del procedimento in cui è inserita l'attività di copia

Es. se io carico una pagina Internet, questa passa dalla memoria RAM e poi vedo qualcosa sullo schermo, il fatto che io veda la pagina avrà un valore economico ma la semplice riproduzione della memoria RAM è priva di questo rilievo economico.

L'esempio della memoria RAM è quello che integra tutta la disciplina del 68 bis.



Art. 69 bis → riguarda le **opere orfane**. In seguito al prolungamento della durata del diritto d'autore sono protette le opere degli autori stranieri, la produzione creativa è aumentata, quindi talvolta è difficile per l'utente non entrare in conflitto col diritto d'autore e per l'utente il rischio è elevato quando non si riesce a capire chi è l'autore. L'opera orfana è un'opera di cui non si riesce a individuare il titolare dei diritti.

In particolare questo articolo afferma che quando un'opera è orfana, e precisa che è orfana soltanto se i titolari dei diritti non sono stati individuati nonostante

una ricerca diligente, allora l'opera può essere utilizzata senza il consenso dell'autore, ma soltanto per utilizzazioni finalizzate alla comunicazione o messa a disposizione del pubblico.



Art. 70 → consente di riprodurre e comunicare al pubblico le opere altrui per scopo di critica o di discussione nei limiti giustificati da questa finalità.

"Critica e di discussione" sono il presupposto fondamentale.

In generale si può dire che questo scopo sussiste quando la riproduzione avviene in un contesto in cui si parla dell'opera riprodotta

Es. quando scriveremo la tesi dovremo descrivere un pensiero altrui, e talvolta riportare tra virgolette alcuni passaggi, e questo si può fare perché in alcuni casi la riproduzione avviene per esporre l'opera utilizzata, per parlarne, per dire se si è d'accordo o in disaccordo... oltre allo scopo di discussione e di critica è necessario anche indicare la fonte e il nome dell'autore, ma l'obbligo di indicare la fonte deriverebbe anche già dal diritto morale d'autore.



Art. 70 ter e quater → disciplina di recente introduzione, introdotta l'anno scorso che riguarda le estrazioni di testo e di dati, cioè il data mining.

I dati che vengono estrapolati e che servono per fare correlazioni, spesso, vengono estrapolati dalle opere protette potenzialmente dal diritto d'autore, e per estrarre testo e dati da un'opera protetta è necessario molto spesso effettuare delle riproduzioni dell'opera, inoltre, non si è certi che anche l'attività di estrazione dei dati non dia vita ad un'opera dell'ingegno, quindi che indipendentemente dalla riproduzione costituisca un'utilizzazione economica dell'opera riservata all'autore oppure no. In questo quadro il legislatore è intervenuto con gli **articoli 70 ter e 70 quater che puntano a liberalizzare l'attività di estrazione di testo e di dati dalle opere dell'ingegno in sé e le riproduzioni strumentali all'estrazione di testo e di dati.**



Si sta discutendo se quella prevista dall'art 70 quater sia una formalità costitutiva, cioè la dichiarazione di riserva, e quindi sia una disciplina illegittima oppure se vi sia il modo di salvarla.

- **Art. 70 quater** → si applica a tutti, però l'autore ha la possibilità di sottrarsi all'applicazione dell'eccezione con una dichiarazione di riserva.
- **Art. 70 ter** → si applica soltanto alle biblioteche, ai musei e agli archivi, è quindi un ambito di applicazione soggettivo circoscritto.

Un'altra eccezione di recente introduzione è relativa alle **opere fuori commercio**, queste opere di cui non sono reperibili esemplari nei canali commerciali abituali, possono essere utilizzate riprodotte, comunicate e messe a disposizione del pubblico a certe condizioni. Innanzitutto questa regola si applica solo a biblioteche, musei e archivi, inoltre, se relativamente all'opera che si vuole utilizzare esistono delle società di gestione collettiva dei diritti sufficientemente rappresentative, chi vuole utilizzare l'opera può farsi dare una licenza da questa società anche se l'autore non è tra coloro di cui la società gestisce i diritti.

- **Precisazione** → una società gestisce i diritti degli autori che hanno aderito alla società medesima, oggi l'autore può anche scegliere a quale società aderire come può scegliere di non aderire a nessuna società, allora in alcuni casi ci può essere un problema se l'opera è fuori commercio e spesso lo è, perché l'autore non si interessa di sfruttare i diritti sull'opera e magari l'autore non è iscritto a nessuna società. Dunque la legge dice che se esiste una società che rappresenta un buon numero di autori nel campo dell'opera considerata, allora l'utente può farsi dare una licenza anche se l'opera che vuole utilizzare non è tra quelle di cui la società ha la gestione dei diritti. Se invece nel campo dell'opera considerata non ci sono società sono comunque possibili delle utilizzazioni ma più circoscritte.



Art. 64 Ter → eccezioni che riguardano specificamente i software, questo articolo dispone che **le riproduzioni e le modificazioni di un software sono consentite se sono necessarie per l'uso del programma.**

C'era proprio bisogno di questa norma ?

In privato una persona può modificare liberamente un'opera dell'ingegno, tuttavia nel campo del software non è così, in questo campo il privato non può né riprodurre né modificare il software, perciò si parla di divieto di decompilazione. È possibile per chi abbia una copia del software, farsene una copia di riserva, questa è una regola inderogabile, inoltre, chi ha in licenza una copia di un software può osservarne il funzionamento, cioè può fare prove per capire in base a quali principi opera, anche questa è una regola inderogabile, cioè il titolare del diritto d'autore sul software non può nel contratto di licenza scrivere che l'utente non ha il diritto di fare esperimenti di prova al fine di ricostruire i principi in base al quale funziona il software.



Art. 64 quater → sono ammesse le riproduzioni e le modificazioni di una copia che uno ha in licenza se sono necessarie per consentire l'interoperabilità con altri programmi.

Abbiamo già visto una regola che consente le riproduzioni e modificazioni necessarie per l'uso, però si tratta di una regola che la legge non qualifica come inderogabile, se invece le modifiche e le riproduzioni sono necessarie a garantire l'interoperabilità allora non possono essere vietate dal titolare del diritto d'autore.

Sentenza SAS

Di questi temi si è parlato nella **sentenza SAS** del 2/05/2012, una causa che arriva dalla Gran Bretagna.

Un imprenditore della società SAS aveva sviluppato un software, base SAS, che permetteva di scrivere delle applicazioni in un suo linguaggio di programmazione, applicazioni che poi potevano essere lette da questa base SAS. Questa base era uno strumento per programmatori e uno strumento per leggere i software scritti con quel linguaggio.

Un'altra società aveva sviluppato un software in grado di leggere programmi scritti con la base SAS, tutto ciò tramite varie prove con la copia della base SAS in licenza sperimenta e provando e riprovando era riuscita a capire come funziona la base SAS e a riprodurre un software che svolge la stessa funzione (forse aveva copiato anche il manuale di istruzioni della SAS).

Il giudice che si era occupato di questo caso aveva tre dubbi:

1. ***È lecito fare un programma che legge i linguaggi di programmazione altrui?***

Ci sono tantissimi programmi che svolgono la stessa funzione. La risposta tecnico-giuridica la troviamo, dal punto di vista del diritto d'autore, nel fatto che il diritto d'autore protegge il modo di comunicare un'informazione, non l'informazione medesima. Quindi nel software ciò che è protetto è il modo di comunicare le informazioni alla macchina. La corte di giustizia aveva detto esattamente questo. Al contrario la SAS sosteneva che il suo concorrente aveva preso una copia in licenza, una licenza dimostrativa e basta, cioè aveva un oggetto limitato, infatti nella licenza c'era scritto che l'utente doveva limitarsi alla semplice fruizione del programma.

2. ***È lecito studiare e osservare approfonditamente per verificare come funziona un programma per copiarlo se c'è una licenza che prevede che l'utente può solo semplicemente fruire del programma?***

La corte dice di sì, è lecito, in quanto vi è un'eccezione che dice che chiunque abbia una licenza ha libertà di studiare e osservare i principi di funzionamento del programma, questa è una regola inderogabile, quindi il titolare, nella licenza, può scrivere quello che vuole ma questa eccezione si applicherà sempre.

3. ***SAS afferma che il concorrente ha copiato il manuale di istruzioni, possiamo quindi presumere che abbia copiato anche il software?***

La corte qua dice che manuale di istruzioni e software sono due cose diverse, se il concorrente ha copiato il manuale sarà responsabile di aver violato il diritto d'autore soltanto sull'opera letteraria costituita dal manuale di istruzioni, ma da questo non si può dedurre che è stato copiato il software poiché non hanno legami.

Brevetti per invenzione



Il brevetto è un istituto che ha la funzione di garantire all'inventore un monopolio sull'attuazione della sua invenzione temporalmente limitato.

Il brevetto per invenzione sta al progresso tecnologico come il diritto d'autore sta al progresso culturale.

L'ordinamento permette all'inventore di monopolizzare la sua invenzione per tutelare il suo interesse privato, ma anche perché lo ritiene conforme all'interesse generale della collettività al progresso tecnologico.

Questo istituto ha molte **analogie col diritto d'autore**:

- È anch'esso un **diritto esclusivo**
- Ha per oggetto una **cosa immateriale** → l'invenzione
- Ha un **contenuto duplice** → diritto patrimoniale e morale dell'inventore, il diritto morale dell'inventore è più circoscritto rispetto a quello dell'autore per cui non ci soffermeremo

L'esclusiva garantita dal diritto di brevetto è temporalmente limitata, è più breve di quella attribuita dal diritto d'autore, **dura soltanto 20 anni** dal momento del deposito della domanda di brevetto e non è rinnovabile in alcun modo.

Vi sono però anche delle **differenze** principali fra il diritto d'autore e quello di brevetto per invenzione. Si è parlato di "domanda", in quanto per ottenere il brevetto d'invenzione occorre depositare una domanda, mentre nel diritto d'autore c'è un divieto assoluto di qualsiasi formalità costitutiva.

Perché in questo campo dei brevetti si continua a richiedere il compimento di una formalità che consiste nel deposito di una domanda ?

Perché nel campo delle invenzioni c'è un'esigenza di combattere la tendenza dell'inventore a tenersi per sé la propria conoscenza e quindi gli si impone in cambio della protezione del brevetto, un onere di svelare la sua conoscenza attraverso il deposito di una domanda che deve avere determinate caratteristiche. Una differenza fondamentale riguarda **l'oggetto della protezione**, poiché in questo campo è l'invenzione, in quello del diritto d'autore è un modo di esprimersi.

Come si acquista il diritto di brevetto?

Si acquista all'esito di un procedimento amministrativo che viene introdotto col deposito di una domanda. Quindi, l'autore deposita la domanda e da quel momento decorreranno i termini della protezione, poi si avvia un procedimento, se l'esito è positivo viene rilasciato il brevetto. Il provvedimento di rilascio del brevetto ha **efficacia retroattiva**, quindi se il brevetto viene concesso

all'inventore, sarà protetto dal momento in cui ha depositato la domanda, e da quel momento decorreranno anche i termini della protezione.

Normalmente l'autore può cominciare a sfruttare la sua invenzione appena dopo la deposizione della domanda, confidando che gli verrà concesso il brevetto, e quindi sapendo che sarà protetto nei confronti dei concorrenti anche relativamente al periodo precedente alla concessione del brevetto.

Ci sono dei casi in cui è consentito un prolungamento della protezione, i **brevetti farmaceutici**, la situazione è particolare perché un farmaco non può essere immesso in commercio prima che sia compiuto un lungo iter di sperimentazioni molto articolato, e quindi se la protezione fosse di solo 20 anni e decorresse inderogabilmente dal deposito della domanda l'inventore del farmaco rischierebbe di vedersi sottratta una parte rilevante della durata dell'esclusiva, e allora ci sono delle regole che consentono qualche forma di prolungamento.



Il diritto di brevetto per invenzione, come il diritto d'autore, come tutti i diritti che fanno parte della proprietà intellettuale è retto dal **principio di territorialità**.

Quindi, la legge italiana protegge l'invenzione in Italia, quella tedesca in Germania ecc..

Per tutelare l'interesse dell'inventore di essere protetto in più di uno Stato sono state stipulate alcune convenzioni che puntavano a garantire agli inventori, cittadini di uno Stato qualsiasi membro della Convenzione, di poter depositare una domanda di brevetto anche negli altri Stati.

Es. la **Convenzione di Parigi** ha previsto il **principio dell'assimilazione**, il cittadino di qualsiasi Stato membro ha diritto di depositare negli altri Stati la domanda di brevetto.

Questa era già stata una conquista per gli inventori, ma chi avesse voluto ottenere la protezione in più Stati avrebbe dovuto recarsi presso gli uffici di tutti gli Stati in cui voleva essere protetto a depositare una domanda, allora ci sono state altre Convenzioni che hanno semplificato le modalità per depositare la domanda in più stati.

Convenzione di Washington

Convenzione del '70, a cui hanno aderito gran parte degli Stati del mondo, questa convenzione permette ai cittadini dei suoi Stati membri di **presentare materialmente la domanda presso l'ufficio della loro nazione** il quale poi provvederà a trasmettere la domanda a tutti gli Stati per cui è richiesta la protezione. L'esame delle domande però rimane separato perché si tratta comunque di tanti brevetti, uno per ogni Stato, il vantaggio della procedura consentita dalla Convenzione di Washington è soltanto che l'inventore risparmia sui costi perché può recarsi all'ufficio della sua nazione. Questa domanda, presentata ai sensi della Convenzione di Washington, dà avvio ad una pluralità di procedimenti amministrativi tanti quanti sono gli Stati per cui si ha richiesto il brevetto, procedimenti governati ognuno dalla legislazione dello Stato per cui ha richiesto il brevetto, e qualora questi procedimenti abbiano esito positivo l'inventore non avrà un unico brevetto internazionale ma tanti brevetti quante sono le nazioni, perciò si parla di **fascio di brevetti**.

Convenzione di Monaco di Baviera

Risale al **1973** ed è una convenzione sul **brevetto europeo**, che ha una particolarità, innanzitutto anche qui ci sarebbero tanti brevetti quanti sono gli Stati per cui è stato richiesto il brevetto, ma in questo sistema l'inventore ha diritto ad ottenere un brevetto in base alle regole della Convenzione di Monaco, cioè la domanda verrà valutata in base alle regole della Convenzione di Monaco e non in base alle legislazioni nazionali, le regole della Convenzione sono abbastanza simili a quelle italiane, ma non sono identiche.

Quindi, **abbiamo due sistemi di brevettazione internazionale:**

- **Quello della Convenzione di Washington** che vale per la gran parte degli Stati del mondo in cui ogni domanda viene esaminata sulla base delle legislazioni nazionali
- **Quello della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo** secondo cui le domande di brevetto sono esaminate sulla base della disciplina unitaria prevista dalla Convenzione.

In entrambi i casi non viene rilasciato un titolo brevettuale unitario che vale per tutto il mondo, ma un fascio di brevetti e la tutela del brevetto rimane affidata alle discipline nazionali.

Es. per vedere se un soggetto terzo è contraffattore di un brevetto oppure no bisogna applicare la disciplina nazionale dello Stato in cui l'inventore assume che ci sia la contraffazione.

Accanto a questi due sistemi è stato introdotto un **terzo sistema** non ancora operativo, che dovrebbe cominciare a funzionare all'inizio 2023, il **brevetto europeo con effetti unitari**. Ci sono state una serie di convenzioni europee che hanno poi condotto all'emanazione di diversi regolamenti tra il 2012 e il 2014, che hanno previsto la possibilità di ottenere un unico brevetto valido per tutti gli Stati Europei che aderiscono a questo progetto. Questa è una grande innovazione rispetto al sistema introdotto dalla convenzione di Monaco, poiché in base alle regole relative al brevetto unitario uno può ottenere un unico brevetto, un unico titolo che è valido per tutta Europa.

La conseguenza dell'unicità del titolo è che **anche il giudizio sulla validità del titolo sarà accentrato**, è quindi prevista l'istituzione di tribunali che hanno il compito di emettere decisioni relative alle controversie sul brevetto europeo con effetto unitario.

Un profilo da tenere in considerazione è quello dei **costi**. Nel sistema della brevettazione internazionale (Washington), l'inventore che vuole brevettare paga un tot per ogni stato per cui deposita la domanda, più sono gli Stati per cui si richiede la protezione più costa la domanda di brevetto, principio simile vale per il brevetto europeo della convenzione di Monaco. Invece l'ultimo sistema consentirà un risparmio di costi significativo, poiché la domanda deve essere esaminata una volta sola. Accanto a tutti questi sistemi abbiamo quello più semplice, quello della **brevettazione nazionale**, in Italia ci si rivolge **all'ufficio italiano brevetti e marchi**, questo ufficio svolge un procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti di brevettabilità, si tratta di una verifica molto blanda, bisogna verificare che il trovato per cui si richiede la brevettazione sia un'invenzione, che sia lecita e che non difetti in modo evidente gli altri requisiti di brevettabilità.

Oggetto del brevetto: l'invenzione

| Cosa è l'invenzione?

Il concetto comune di invenzione è molto ampio, in questo concetto comune possono rientrare anche alcune opere dell'ingegno.

Il concetto di invenzione che ci interessa è la **soluzione di un problema tecnico**, concetto di problema tecnico che serve a lasciar fuori dal concetto di invenzioni tutte le soluzioni di problemi non tecnici: un problema di matematica, giuridico, di semantica, espressivo...

La legge precisa che **alcuni tipi di creazioni sono esclusi dall'ambito della brevettabilità** perché non sono considerati invenzioni:



Art. 45 codice della proprietà industriale → non rientrano nel concetto di invenzioni:

- **Scoperte** → la individuazione di un principio che governa la natura, ad esempio la teoria della relatività è una scoperta, ma non è un'invenzione, poiché esisteva anche prima che venisse scoperta,
- **Teorie** → una ricostruzione astratta relativa ai principi che regolano un qualsiasi campo delle attività umane o di qualsiasi natura, ad esempio è una teoria una ricostruzione giuridica sul significato/interpretazione di una norma,
- **Metodi matematici**
- **Metodi per le attività mentali**
- **Metodi per le attività commerciali**
- **Metodi di gioco**
- **Software** → si è scelto di dare prevalenza alla funzione espressiva del software e quindi assegnarlo al diritto d'autore, mentre in America è consentita con una certa larghezza la brevettabilità di un software
- **Presentazioni di informazioni** → che è un po' il cuore del diritto d'autore

Tutte le ipotesi citate ora, **non sono brevettabili di per sé**, dice la legge, ciò significa che invece **sono brevettabili le invenzioni che partono da uno di questi trovati per risolvere un problema tecnico ulteriore**.

Es. se il software non si limita a far svolgere delle operazioni alla macchina ma nel far ciò risolve problema tecnico ulteriore.

Es. un problema tecnico è quello di consentire ad un paziente di effettuare un elettrocardiogramma a casa, senza andare all'ospedale, occorre che il paziente posizioni gli elettrodi nella giusta posizione e occorre un sistema in grado di leggere la corretta posizione degli elettrodi. L'idea è che si sviluppi

un'applicazione per smartphone che dialoga via bluetooth con un apparecchio in modo che l'applicazione, quando il paziente si inquadra con la fotocamera, gli dica dove spostare gli elettrodi. Qui abbiamo un software che dice al telefono cosa indicare al paziente e che elabora i dati che arrivano dagli elettrodi, questo complesso risolve un problema tecnico, e quindi non abbiamo ospitanti la soluzione di comunicare informazioni alla macchina, qui il software ci consente di risolvere un problema tecnico ulteriore. Quindi, questa invenzione immaginaria sarà brevettabile, così come è brevettabile un'invenzione che trae origine da una scoperta.

Ci sono altri **trovati che rientrerebbero nel concetto di invenzioni, ma che ne sono esclusi** espressamente dalla legge:

- **I metodi terapeutici** → i farmaci sono brevettabili ma non è brevettabile una tecnica di cura, questo perché i metodi curativi devono poter essere utilizzati dai medici senza timore di violare il diritto di brevetto.
- **Le varietà vegetali** → sono escluse perché c'è una forma di tutela apposita diversa dal brevetto, e quindi per evitare sovrapposizioni di tutela.

La soluzione del problema tecnico, l'invenzione, può consistere in due tipologie diverse:

- **Prodotto** → ad esempio il velcro.
- **Procedimento** → ad esempio, in un'acciaieria se si vogliono produrre dei laminati sottili è necessario raffreddarli, altrimenti l'acciaio si surriscalda e si rompe, storicamente si raffreddavano con l'uso dell'olio, però è un uso costoso ed inquinante, allora un'invenzione può consistere nello scoprire che facendo certe operazioni è possibile raffreddare certi laminati con l'acqua. Però è difficile raffreddarli con l'acqua, quindi un gruppo di inventori studia la ricerca e scopre un procedimento particolare che consente di utilizzare l'acqua anziché l'olio.

Il problema tecnico che sta alla base dell'invenzione di prodotto è il problema tecnico risolto dal prodotto. Il velcro risolve il problema di tenere insieme due pezzi di stoffa.

Es. uno dei primi brevetti depositati è stato quello per le graffette che consentono di tenere insieme i fogli, la graffetta è un oggetto molto semplice, anche da riprodurre ciononostante è un'invenzione geniale brevettata con riferimento al problema di tenere insieme i fogli, il problema tecnico rilevante

nell'invenzione di prodotto è quello risolto dal prodotto finito, non ha importanza se c'è o non c'è un problema nella realizzazione del prodotto.

Se invece il problema tecnico sta nella realizzazione dell'oggetto allora abbiamo invenzione di procedimento. Possiamo anche avere entrambe le invenzioni, poniamo che per riprodurre su scala industriale il velcro era necessario risolvere dei problemi, vi sarà un'invenzione sia di prodotto che di procedimento. Questa **differenza è importante perché si riflette sulla tutela.**

- **Il brevetto di prodotto** copre il prodotto comunque ottenuto, cioè il titolare di brevetto di prodotto può opporsi a che altri fabbricano e commercializzano il medesimo prodotto anche se lo dovessero realizzare con un procedimento diverso, poiché l'invenzione non sta nel come realizzo il prodotto ma sta nell'idea di risolvere un problema tecnico specifico con quel prodotto.
- **Nel campo del brevetto di procedimento**, invece, l'esclusiva si estende anche alla commercializzazione del prodotto ottenuto col procedimento brevettabile, quindi l'acciaieria che ha brevettato il sistema per raffreddare ad acqua i laminati può benissimo opporsi al fatto che un'altra acciaieria venda lastre di acciaio ricavate col medesimo procedimento. Tuttavia è chiaro che vi è un problema di accertamento nella pratica, è difficile sapere come i concorrenti lavorano all'interno degli stabilimenti, allora la legge viene in soccorso.



La legge dice che si presume che il prodotto sia ottenuto con il procedimento brevettato in due casi :

1. Quando il prodotto è nuovo, cioè non si trovava sul mercato prima dell'invenzione di procedimento.
2. Quando il titolare del diritto di brevetto di procedimento riesce solo a dimostrare che è verosimile che il suo concorrente ha adottato lo stesso procedimento, ma non fornisce una prova concreta del fatto.

Molti ritengono che esista poi un **terzo** genere di invenzioni: **le invenzioni di nuovo uso.**

Il libro contesta questa categoria dicendo che il nuovo uso di una sostanza già nota sarà un prodotto o un procedimento, quindi non ha senso individuare una terza categoria.

Es. se io prendo un composto chimico, già noto e brevettato, per risolvere un problema tecnico ma questo ne risolve un altro, avrò comunque un'invenzione di prodotto o di procedimento. Questo accade principalmente nel campo dei farmaci, poiché nella meccanica è difficile che un oggetto venga usato per altri scopi, mentre un principio attivo può essere adatto per nuovi usi.

La nozione di **"nuovo uso"** è però comunque utile per mettere a fuoco il concetto che, se si cambia il problema tecnico risolto, non abbiamo più l'invenzione precedente ma abbiamo una nuova invenzione, anche se il prodotto resta lo stesso.

Requisiti che devono sussistere perché un'invenzione sia brevettabile

- **Novità** → sono brevettabili le invenzioni nuove. La novità è disciplinata nell'**art. 46** secondo cui sono nuove le invenzioni che non rientrano nello **stato della tecnica**. Lo stato della tecnica è **l'insieme di tutte le conoscenze che sono state rese accessibili al pubblico in un punto qualsiasi del mondo**, il momento rilevante per la valutazione dello stato della tecnica è quello del deposito della domanda di brevetto. Rientrano nello stato della tecnica tutte le conoscenze accessibili:
 - Conoscenze brevettate da altri
 - Invenzioni su cui altri al momento hanno diritti di brevetto
 - Invenzioni che sono state brevettate ma su cui brevetto è scaduto
 - Le conoscenze che non sono mai state brevettate o perché al tempo non c'era il brevetto, o perché il titolare non voleva avvalersi della protezione del brevetto

Es. se scopro che in Messico qualcuno ha un brevetto circoscritto al territorio messicano, che quindi non vale in Italia, non posso ottenere un brevetto valido in Italia. Il fatto che la conoscenza sia utilizzata soltanto all'estero non è rilevante ai fini del giudizio di novità → **l'esistenza di una determinata conoscenza è distruttiva per la novità**.

Quindi l'inventore che vuole depositare la sua domanda di brevetto dovrà stare bene attento a parlare della sua invenzione, se ad esempio l'inventore va a un convegno di tecnici della sua materia e racconta per filo e per segno quanto è stato bravo a risolvere un problema tecnico distrugge la novità della sua invenzione.

C'è un'eccezione, la divulgazione delle informazioni relative all'invenzione non distrugge la novità se:

1. **È fatta da quelle persone che non sono in grado di capire l'invenzione**
2. **È incompleta**, cioè se nello spiegare l'invenzione vengono omessi dei passaggi imprescindibili per la realizzazione dell'invenzione, quindi non si realizza una divulgazione distruttiva della novità

L'inventore si può salvare solo quando la divulgazione sia una conseguenza di un abuso evidente e la domanda di brevetto venga depositata entro 6 mesi dalla divulgazione.

Uno dei modi che l'inventore ha per tutelare la novità della sua invenzione è quello di stipulare degli **accordi di riservatezza**, cioè può capitare che l'inventore debba per forza di cose spiegare ad altri in cosa consiste la sua invenzione, ad esempio perché vuole raccogliere fondi per avviare l'iniziativa imprenditoriale.

La cosa preferibile da fare, sarebbe prima depositare la domanda e poi parlare con gli investitori, se non si riesce l'inventore può tutelarsi quantomeno facendo firmare alla controparte un contratto in cui questa si impegna a non divulgare in nessun modo tutte le informazioni che ha ricevuto, in questo caso qualora il terzo dovesse divulgare l'invenzione, l'inventore potrà almeno dimostrare che la divulgazione è stata una conseguenza di un abuso evidente. Quindi in questo caso potrà salvare la novità, purché depositi entro 6 mesi la domanda.

Un altro problema posto dal requisito della novità → l'inventore magari ha interesse a depositare subito la domanda nel suo Stato e a prendersi qualche tempo di riflessione per valutare se l'invenzione merita di essere protetta anche altrove con tutti i costi conseguenti. La domanda di brevetto dopo un certo lasso di tempo dal deposito viene pubblicata, poiché una delle funzioni dell'istituto di brevetto è quella di rendere pubblica la conoscenza.

*Quindi, **in teoria**, se dopo aver depositato una domanda di brevetto in Italia ad esempio, un anno dopo la depositassi in Germania, assumendo che in Germania si applichino le stesse regole dell'Italia. Che problema avrà l'invenzione ?*

Il problema è che l'invenzione non sarà più nuova, perché il parametro di valutazione della novità è l'universo mondo, quindi nel momento in cui la mia domanda viene pubblicata in Italia questo mi distruggerà la novità in tutto il mondo. Magari il brevetto all'estero mi sarà rilasciato lo stesso ma sarà un brevetto nullo per difetto del requisito di novità.

La legge vuole tutelare l'interesse dell'inventore a prendersi un po' di tempo per decidere se estendere la protezione anche all'estero o no. In particolare, già dalla **Convenzione dell'Unione di Parigi** si prevede che chi ha depositato una domanda di brevetto in uno degli Stati che aderiscono alla Convenzione ha un **diritto di proprietà**, ciò significa che **nei 12 mesi successivi al deposito della prima domanda, l'inventore può presentare domanda di brevetto in uno o più Stati tenendo come data rilevante per la valutazione della novità quella della prima domanda.**

Quando l'invenzione è nuova rispetto allo Stato della tecnica?

L'invenzione non rientra nello stato della tecnica quando manca un antecedente identico, basta che la differenza tra l'invenzione che stiamo considerando e lo stato della tecnica sia piccola perché la novità sussista.



Art. 48 del codice della proprietà industriale → disciplina il secondo requisito è quello **dell'attività inventiva**.

- **Attività inventiva** → l'invenzione deve implicare un'attività inventiva, non è richiesta una particolare ricerca, questo requisito vuole richiedere che vi sia un **salto inventivo**, tra ciò che è noto e l'invenzione, oppure si parla anche di **altezza inventiva**. L'invenzione è dotata di attività inventiva quando un tecnico esperto del settore non la riceverebbe in modo evidente o ovvio dallo stato della tecnica. Se confrontando lo stato della tecnica con l'invenzione emerge che quest'ultima può essere dedotta ovviamente dallo stato della tecnica, allora manca l'attività inventiva, cioè si richiede qualcosa in più della novità. Se avessimo un mondo dei brevetti in cui è richiesta solo la novità, sarebbe sufficiente cambiare una virgola, quindi pochissimo rispetto allo stato della tecnica per avere un'invenzione brevettabile. È importante perché **da questo requisito dipende la reale effettività della durata ventennale della protezione**, se non ci fosse il requisito dell'attività inventiva, una volta

scaduto il brevetto, l'inventore potrebbe fare qualche modifica e ribrevettarla, e invece non è così. Nella pratica, per verificare la sussistenza dell'attività inventiva, bisogna considerare il giudizio dell'esperto medio del settore, il giudice che deve decidere, molto spesso non sa nulla sulla materia interessata dal brevetto quindi nomina un esperto specifico, un consulente che dirà, in base allo stato della tecnica, se l'invenzione è deducibile in modo ovvio oppure no, quando questo giudizio è difficile da dare, si ricorre a degli indizi.

Es. ci sono tanti imprenditori che hanno chiesto delle licenze per attuare l'invenzione di cui stiamo discutendo, ma è difficile che tanti imprenditori chiedano delle licenze per un'invenzione che è ovvia.

Questo è il motivo per cui esiste la **circostanza delle licenze**. I requisiti di brevettabilità spesso vengono valutati in un momento successivo all'esame della domanda di brevetto, cioè l'ufficio di marchi e brevetti, nel valutare le domande, non fa nulla di diverso dal mettere un timbro e controllare la sussistenza dei requisiti in maniera molto blanda, dunque si può andare in giudizio per far dichiarare nullo un brevetto.

La novità e l'attività inventiva sono quindi requisiti del brevetto, ma ve ne sono anche altri.

- **Industrialità** → è industriale l'invenzione che può essere riprodotta in modo identico

Una tecnica del nuoto è brevettabile ?

Es. c'è stato un tempo in cui nelle olimpiadi si nuotava solo a rana, poi è stato introdotto il dorso, che sicuramente è stata un'invenzione e a suo tempo sarà stata nuova, inoltre si ritiene che abbia risolto un problema tecnico in modo non ovvio.

Perché sia brevettabile, però, ci manca il **requisito di industrialità**.



Art. 49 del codice della proprietà industriale → disciplina l'industrialità, l'invenzione deve essere suscettibile di applicazione industriale.

Cosa si intende per applicazione industriale?

Se pensiamo ad una tecnica del nuoto, è chiaro che siamo fuori dal campo dell'industria, in America c'è stato un tentativo di ottenere un brevetto per un determinato modo di impugnare la mazza da golf, ma giustamente questo brevetto è stato considerato nullo per l'assenza di questo nuovo requisito. Tuttavia, se consideriamo un altro esempio la questione è meno ovvia:

Es. il motore elettrico ha un problema, al di sopra di un certo numero di giri, i componenti del motore si danneggiano e dunque l'inventore inizia a utilizzare il procedimento del bandaggio. Quando ci si chiede se il bandaggio del motore elettrico sia brevettabile e industriale, la risposta non è ovvia.



Bisogna quindi introdurre la **nozione di industrialità**. Secondo l'opinione dominante **è industriale l'invenzione che può essere riprodotta in modo identico**, quindi non bisogna vedere solo se può essere attuata all'interno di un'industria, ma anche se l'invenzione è standardizzabile, quindi ripetibile in modo identico.

Capire se un'invenzione è industriale e proteggibile dipende da come è pensata. Se l'inventore si limita a pensare che è possibile tenere insieme i componenti del motore fasciandolo con del materiale e questa operazione può essere svolta soltanto grazie a particolari abilità di un tecnico, allora non si tratta di un'invenzione ripetibile in modo identico. Se invece si pensa a un modo per standardizzare il procedimento di bandaggio (in questo caso) allora possiamo avere un'invenzione dotata del requisito di industrialità. Questo requisito esclude tutte le invenzioni che appartengono strettamente al campo dell'artigianato, cioè soluzioni artigianali di problemi tecnici.



Art. 50 del codice della proprietà industriale → l'invenzione non deve essere contraria all'ordine pubblico e al buon costume. Il requisito della liceità non richiede che il soggetto che richiede il brevetto possa anche lecitamente produrre l'invenzione.

- **Liceità** → ultimo requisito di brevettabilità.

Es. l'invenzione di un'arma → per produrre un'arma ci vogliono molte autorizzazioni, ma posso benissimo ottenere un valido brevetto per un'arma

da fuoco, il requisito della liceità non consente di ottenere brevetti validi relativamente a invenzioni per le quali non sia possibile immaginare nemmeno un uso lecito.

Es. l'invenzione del procedimento per la clonazione umana è un'invenzione che non è brevettabile per difetto della liceità.



Art. 51 → la domanda di brevetto può condurre ad un brevetto valido solo se è accompagnata dalla sufficiente descrizione.

Altro elemento del brevetto, si discute se sia davvero un requisito analogo agli altri che abbiamo visto oppure no.

Abbiamo già avuto modo di accennare alla sufficiente descrizione quando abbiamo fatto un confronto tra il diritto d'autore e il brevetto. Nel campo dei brevetti l'ordinamento vuole che la conoscenza inventiva sia condivisa, cioè messa a disposizione della collettività, mentre l'autore se la può tenere per sé. Quindi lo "Stato" ti dà un monopolio sulla tua invenzione e tu in cambio paghi le tasse e dichiari al pubblico in cosa consiste la tua invenzione, in modo che questa non vada perduta, vi è **un patto tra legislazione e inventore**. Da questa funzione della sufficiente descrizione possiamo ricavare quali sono le caratteristiche che deve avere una descrizione.

Cosa deve essere sufficiente? Quando una descrizione è considerata sufficiente?

Deve essere completa, poiché se manca qualche elemento nella descrizione, chi la legge non sarà in grado di riprodurla, ma il parametro di valutazione (cioè per chi deve essere sufficiente) è il **tecnico medio del settore**, attraverso questo requisito si realizza una grande conquista di civiltà e democrazia. Nell'antichità la conoscenza era in mano ad alcune classi sociali e queste, attraverso la conoscenza, riuscivano a controllare la società.

Altra funzione di questo istituto è **verificare la sussistenza di altri requisiti di brevettabilità**. Se non ci fosse la descrizione sarebbe complicato determinare bene in cosa consiste l'invenzione di cui l'inventore ha chiesto il brevetto. Il bilanciamento fra gli interessi della collettività e quelli dell'inventore si realizza anche grazie a norme ulteriori.



Art. 69 → la legge impone all'inventore un onere di attuazione dell'invenzione.

Se l'inventore vuole conservare completamente intatto il suo diritto esclusivo che ha acquistato col brevetto deve attuare l'invenzione.

Per onere, in questo senso tecnico giuridico, si intende un comportamento richiesto per godere di un beneficio, non è un obbligo, quindi l'inventore non viene punito se non attua l'invenzione, semplicemente gode di un diritto esclusivo più limitato.



Art. 70 → prevede che se il titolare del brevetto non attua l'invenzione o se la attua in modo insufficiente a soddisfare i bisogni del paese, **dopo tre anni dalla concessione del brevetto o 4 anni dal deposito della domanda**, i terzi possono ottenere una **licenza** per attuare loro l'invenzione.

La licenza si ottiene rivolgendosi al titolare del brevetto, nel caso in cui il titolare del brevetto si rifiuta o chiede un prezzo esorbitante, quindi non concede al terzo una licenza a condizioni eque, per legge il terzo **si può rivolgere all'ufficio marchi e brevetti** e chiedere che questo ufficio di imperio gli conceda la licenza per attuare l'invenzione. Questa è la prima conseguenza della mancata attuazione dell'invenzione. Tuttavia non è solo questa la conseguenza della mancata attuazione dell'invenzione, poiché se trascorrono altri **due anni dalla concessione della licenza obbligatoria** per mancata attuazione, e in questi due anni l'inventore è ancora rimasto inerte, allora l'ordinamento gli toglie il brevetto, quindi il brevetto decade se l'invenzione non viene attuata neppure entro il termine di due anni dalla concessione di una licenza per mancata attuazione.

Brevetti dipendenti

Il caso dei brevetti dipendenti è un'altra ipotesi di **licenze obbligatorie**.

L'ordinamento consente la licenza non soltanto in seguito a una mancata attuazione, ma anche in un'altra fattispecie, in particolare, anche se l'invenzione è stata attuata dal titolare del brevetto, chi ha realizzato un'invenzione dipendente e l'ha brevettata, se questa apporta un'importante progresso tecnico rispetto all'invenzione da cui dipende, ha diritto di ottenere una licenza per attuare anche la prima invenzione.



Invenzioni dipendenti → invenzione che si basa su un'altra invenzione, sono sostanzialmente tutte le invenzioni si basano su invenzioni preesistenti.

Es. la stampante a colori utilizza l'invenzione costituita dalla stampante semplice e si differenzia perché realizza un salto inventivo ulteriore, però l'invenzione costituita dalla stampante a colori non può essere attuata senza attuare anche l'invenzione che la precede.

Se l'inventore della prima invenzione, non rilascia al secondo inventore la licenza a condizioni eque, egli non potrebbe attuare la seconda invenzione, allora la legge prevede la possibilità per il secondo inventore di ottenere una licenza obbligatoria, perciò si chiede prima all'inventore e nel caso di una risposta negativa ci si rivolge all'ufficio marchi e brevetti.

La seconda invenzione deve essere un'invenzione brevettata.

Es. pensiamo al caso delle fotografie, prima la foto era soltanto in bianco e nero. Il problema del colore è stato risolto grazie a dei fotografi italiani, sconosciuti, che sono andati in Giappone dove c'erano dei miniaturisti che dipingevano molto minuziosamente quindi i fotografi gli facevano colorare le fotografie. Questa è un'invenzione dipendente dall'invenzione della fotografia in bianco e nero, ma non è un'invenzione brevettabile poiché pecca di industrialità. Poi è stata inventata la pellicola a colori, se l'invenzione della fotografia in bianco e nero fosse stata ancora brevettata l'inventore della pellicola a colori avrebbe senz'altro avuto diritto ad ottenere una licenza obbligatoria sull'uso della prima tecnologia.

La seconda invenzione deve apportare un importante progresso.

La possibilità di ottenere una licenza per utilizzare un'invenzione altrui collegata alla propria, non opera solo a favore del secondo inventore, ***anche il primo inventore ha un corrispondente diritto di ottenere una licenza per l'uso della seconda invenzione che ha perfezionato la sua.***

Anche il diritto esclusivo di brevetto è regolato dal **principio dell'esaurimento** e funziona in un modo analogo a quello dell'autore. Quando un prodotto coperto da

brevetto è stato messo in commercio con consenso del titolare, il titolare non può più opporsi ai successivi atti di commercio relativi al medesimo esemplare. Anche il diritto esclusivo conferito dal brevetto prevede **eccezioni**, la principale è relativa alle **utilizzazioni private**, il privato può andare a consultare le descrizioni brevettuali e attuare in casa propria le invenzioni, purché non a scopo commerciale. Questa è una regola generale, nel diritto d'autore è diverso perché l'eccezione di copia privata riguarda soltanto la fotocopia e la copia privata di fonogrammi e videogrammi che ha regolamentazione complessa. Nel mondo della tecnica, invece, il privato può liberamente attuare l'invenzione altrui. La differenza è dovuta dal fatto che le opere dell'ingegno sono riproducibili anche in ambito privato da tanti anni, sostanzialmente da quando è stata inventata la fotocopia, e da quel momento ***il mondo del diritto d'autore si è reso conto che il privato aveva a disposizione la possibilità di moltiplicare gli esemplari tale da pregiudicare in modo rilevante il potenziale profitto dell'autore***. Se il privato realizza in casa le copie delle opere dell'ingegno, farà a meno di acquistarle sul mercato controllato dall'autore grazie al suo monopolio, quindi è emerso un interesse dell'autore a controllare anche queste attività e correlativamente l'ordinamento ha iniziato a tutelare questo interesse dell'autore. Nel campo dei brevetti l'attuazione dei privati è ancora libera perché la possibilità, di un privato, di realizzare invenzioni è sostanzialmente improbabile, perciò non c'è l'interesse, da parte dell'inventore, di tutelare quest'interesse.

Il brevetto dura 20 anni, salvo il caso particolare dei certificati complementari, ma può finire prima?

Sì, ad esempio nel **caso dell'onere di attuazione**. Poi, un brevetto può venire meno prima del termine anche in seguito a una **rinuncia** da parte del titolare, oppure per un **mancato pagamento delle tasse del mantenimento in vita del titolo o brevetto**, per mantenere il brevetto tutti gli anni bisogna pagare una tassa, che aumenta di anno in anno, quindi più ci si avvicina alla scadenza più diventa costosa. Se il titolare non dovesse pagare questa tassa nei termini, compreso anche il termine di tolleranza, il brevetto decadrebbe.

Talvolta i brevetti decadono anche perché c'è una voce, diceria ricorrente nel mondo delle imprese medio grandi, secondo cui i brevetti non sono poi così importanti, e quello che conta davvero è realizzare il prodotto, però lo è anche avere una forma di tutela. I brevetti non sono importanti se si è ad esempio Apple, che ha una quota di mercato garantita dal marchio e dal fatto che l'impresa è molto conosciuta, e quindi anche se il concorrente realizzasse qualcosa di simile, il danno sarebbe meno grave rispetto a quello di un'impresa più piccola.

Lasciar scadere un brevetto è un atto particolarmente grave. C'è una differenza tra non chiedere il brevetto, quindi tenere per sé la conoscenza, e chiedere il brevetto per poi perderlo, la seconda ipotesi è molto più grave della prima.

1. Dopo che un brevetto scade **non lo si può ottenere nuovamente** → mancherebbe il requisito della novità.
2. Ciò che rende la situazione ancora più grave è che tutti avranno a disposizione la descrizione che consente di attuare l'invenzione → art.51, motivo per cui se si decide di brevettare un'invenzione bisogna essere decisi.

Come alternativa alla protezione del brevetto, l'ordinamento prevede un altro istituto, quindi c'è ancora spazio per il segreto nel nostro sistema giuridico, anche se la cultura di oggi è quella della conoscenza aperta e delle descrizioni brevettuali. È uno spazio più limitato di quello riservato alla conoscenza condivisa, ma anche il segreto ha una sua tutela.



Art. 98-99 del codice della proprietà industriale → disciplina la **tutela del segreto**. L'oggetto della tutela del segreto sono le informazioni brevettabili o non brevettabili, devono avere tre caratteristiche:

1. **Segrete**
2. Dotate di **valore economico**, in quanto segrete
3. Sottoposte a misure **idonee a tutelarne la segretezza**

Es. **Coca-Cola**, la ricetta della coca cola è tenuta segreta e non è brevettata, esiste da tempo immemorabile ma nessuno sa con esattezza quali siano il suo contenuto esatto, le sue quantità e il procedimento, però è protetta perché è costituita da una serie di informazioni segrete, è dotata di un valore economico, ed è sottoposta a misure idonee a tutelarne la segretezza.

Innanzitutto le informazioni devono essere segrete. ***L'informazione è considerata segreta se non è facilmente accessibile nella loro esatta conformazione.***

Il requisito della segretezza somiglia un po' alla novità, poiché anche quando abbiamo parlato della novità brevettuale abbiamo detto che è nuovo ciò che non è compreso nello stato della tecnica, che è l'insieme delle conoscenze accessibili, **soltanto che nel campo della novità brevettuale l'invenzione è nuova solo se non è accessibile**, basta anche una difficile accessibilità a distruggere la novità. **In questo campo invece le informazioni sono segrete se non sono facilmente**

accessibili, quindi un'informazione difficilmente accessibile può essere considerata segreta. Si parla di pseudo novità, perché assomiglia alla novità ma la relativa valutazione è meno rigorosa. Quindi il sistema del brevetto esclude radicalmente che vi possano essere due brevetti sulla stessa invenzione, invece il sistema del segreto è compatibile con l'esistenza di più segreti sulle medesime informazioni basta che l'accessibilità non sia agevole.

Inoltre deve esserci **valore economico** della conoscenza segreta, cioè ci deve essere un nesso fra la segretezza delle informazioni e il loro valore economico, il fatto che l'informazione sia tenuta segreta deve contribuire ad incrementarne il valore.

Es. se pensiamo al **software**, esso ha un valore economico che dipende dalla segretezza, quindi in questo caso sono **cumulabili le due tutele**, diritto d'autore e diritto sul segreto, quindi nella disciplina del diritto d'autore, per quanto riguarda il software, ci sono delle regole che tutelano la sua segretezza, anche per questo la riproduzione privata è vietata.

Il terzo punto, sostiene che la segretezza deve essere sottoposta a **misure idonee a preservare la segretezza**, si va dalle misure più elementari, come ad esempio tenere la conoscenza nei propri computer aziendali e richiedere delle password, a misure più efficaci, ad esempio la stipulazione di accordi di riservatezza. Gli **accordi di riservatezza** sono uno dei modi principali per il mantenimento del segreto, un imprenditore accorto avrà cura di far firmare degli impegni alla riservatezza a tutti i suoi dipendenti, ai collaboratori esterni, ai suoi distributori e a chiunque possa entrare in contatto con conoscenze segrete.



Tutela del segreto industriale → è considerato tra i diritti esclusivi della proprietà intellettuale, poi se sia veramente un diritto di proprietà come lo è il diritto d'autore o il diritto di brevetto per invenzione è discusso poiché ha un contenuto meno pervasivo e una tutela meno forte rispetto agli altri diritti della proprietà intellettuale.

In particolare, **è vietato l'uso e la divulgazione delle informazioni segrete, soltanto se acquisite abusivamente**, l'onere di dimostrare che le informazioni siano state acquisite abusivamente spetta, in linea di principio, a colui che fa valere il segreto.

┃ *Come si dimostra?*

Molto spesso ci si avvale di presunzioni e si usano indizi presunti

Es. il mio concorrente non ha effettuato investimenti in ricerca eppure produce il medesimo prodotto che io realizzo utilizzando delle conoscenze segrete, ed è un prodotto molto complicato da realizzare. In questo caso si può presumere che il concorrente abbia acquisito abusivamente le informazioni.

Es. questo concorrente è stato in passato anche un mio distributore e quindi ha avuto accesso a determinate informazioni segrete.

Es. una delle ipotesi di concorrenza sleale è quella dello storno dei dipendenti, cioè un imprenditore sottrae ad un concorrente dei dipendenti, e dopo poco immette sul mercato il medesimo prodotto che commercializza il primo imprenditore, non abbiamo una prova diretta ma possiamo ricavare dai fatti testimoniati dallo storno dei dipendenti che l'imprenditore che ha effettuato lo storno è arrivato alla conoscenza per mezzo dello storno dei dipendenti.

Vi è un altro **limite alla tutela del segreto**, il diritto sul segreto non si estende fino a vietare le operazioni di reverse engineering. I terzi potranno utilizzare la conoscenza di cui un soggetto detiene il diritto di segreto se vi giungono indipendentemente, con operazioni volte a ricostruire il contenuto di questa conoscenza segreta senza avervi avuto accesso direttamente.

Es. una persona che sa riconoscere la formula di un profumo solo annusandola.

Il diritto sul segreto non consente di opporsi a queste operazioni di reverse engineering e non consente nemmeno di opporsi all'uso della conoscenza da parte di chi vi sia giunto con operazioni di ricerca autonoma o parallela, cioè due ricerche distinte ma parallele di due imprenditori, entrambi arrivano alla medesima conoscenza segreta, ed entrambi la potranno utilizzare.

Il diritto sul segreto ha una **durata potenzialmente illimitata**, fino a che sussistono i presupposti, una volta che la conoscenza non dovesse più essere segreta o venisse divulgata, la segretezza cesserà di esistere.

Il marchio

Un altro istituto della proprietà intellettuale è quello dei **marchi**.



Marchio → segno distintivo, non è l'unico ma è l'unico di cui parliamo diffusamente.

Ditta → nel linguaggio comune è un sinonimo quasi di società, dal punto di vista tecnico è sbagliato, poiché la ditta è il **nome con cui l'imprenditore svolge la sua attività e con cui si presenta ai clienti, ai fornitori e ai concorrenti**.

Insegna → nome dell'esercizio, quel segno collocato sopra la vetrina è un'insegna in senso giuridico.

La **ditta** identifica l'impresa, e potremmo dire che svolge la medesima funzione che nome e cognome svolgono per la persona fisica. La ditta **deve essere registrata**, quando si va al registro delle imprese per iscrivere l'impresa, verrà chiesto di indicare una ditta, quindi rimarrà registrata come denominazione dell'impresa.

Un altro segno distintivo è **l'insegna**, in questo caso la nozione del linguaggio comune corrisponde a quella tecnica giuridica. L'insegna è il **nome dell'esercizio**, costituito ad esempio da un bar, negozio, ecc... , è **quel segno collocato sopra la vetrina è un'insegna in senso giuridico**.

Un altro segno distintivo, il più importante è il **marchio**. Si discute su cosa sia il marchio, i giuristi non sono del tutto concordi, ma con una certa approssimazione possiamo dire che il marchio è **il segno che identifica la provenienza di un prodotto o di un servizio da un'impresa**.

La legge offre una disciplina relativamente a questi segni distintivi, per quanto riguarda la tutela della ditta e dell'insegna la troviamo nelle regole relative alla **concorrenza sleale**. Una delle fattispecie di concorrenza sleale è la **concorrenza sleale confusoria**, che consiste nell'utilizzo di segni distintivi altrui idoneo a provocare confusione, l'uso di una ditta o insegna altrui può integrare la fattispecie rilevante come concorrenza sleale confusoria.

Per quanto riguarda il marchio abbiamo una disciplina più articolata, la **classificazione di marchi**. Il marchio può riguardare un prodotto, nel caso si parla di **marchio di prodotto** (il tipo di marchio più diffuso), oppure può servire a indicare la provenienza imprenditoriale di un servizio.

Es. di marchio di prodotto → Asus, Acer...

Il **marchio di servizio** è il marchio che serve a designare la provenienza imprenditoriale di un servizio

Es. una catena di un bar appone un segno sulle divise dei dipendenti, è un marchio di servizio quindi non è apposto su un prodotto.

Il marchio può essere **generale**, quindi utilizzato per una pluralità di prodotti

Es. una grandissima quantità di marchi automobilistici → il marchio Alfa Romeo è apposto sulla Giulia, sulla Stelvio ecc...

Il marchio può essere **speciale**, è quello che è invece apposto o riferito a un prodotto specifico

Es. "Giulia" o "Stelvio"

Quali oggetti possono costituire un marchio ?

Un marchio può essere costituito da nomi (marchi denominativi), simboli, suoni, colori, ma la **caratteristica essenziale** che deve avere un oggetto per poter diventare marchio è quella della **rappresentabilità**, cioè l'oggetto deve essere rappresentabile. La legge italiana richiede la rappresentabilità grafica, pertanto sembrano esclusi dal novero degli oggetti che possono costituire un marchio, i profumi.

Nella disciplina del marchio europeo, invece si richiede la semplice rappresentabilità, quindi, forse, in questo sistema del marchio europeo c'è una apertura anche a qualche entità che si può rappresentare in modo non grafico.

Come si coordina l'esigenza di rappresentabilità grafica, tuttora richiesta dall'Italia, con la possibilità di registrare anche i suoni come marchi?

Per i suoni si utilizza la modalità di rappresentazione costituita dallo spartito, la legge attribuisce al titolare del diritto sul marchio un diritto esclusivo, **il diritto esclusivo di utilizzazione del marchio nell'attività di impresa**.

Come si acquista il diritto sul marchio ?

Vi è una grande **bipartizione**. Con la **registrazione**, che può avvenire secondo **tre differenti sistemi**:

- Un **sistema di registrazione internazionale** → in tal caso la domanda deve essere depositata presso l'ufficio dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale che si trova a Ginevra, in Svizzera, o si può fare anche in via

telematica o attraverso degli sportelli delle camere di commercio. Questo sistema dà origine non a un unico marchio ma a un fascio di marchi, chi si avvale di questa procedura di registrazione internazionale **acquisterà un diritto di marchio per ogni Stato relativamente al quale ha chiesto la registrazione**. Questa procedura ha un costo che dipende dal numero di Stati per il quale il soggetto vuole essere protetto.

- Il secondo **sistema** è quello **del marchio europeo** → in questo caso l'ufficio competente si trova ad Alicante, in Spagna, anche qui è possibile il deposito telematico o attraverso le camere di commercio nazionali. Questo è un marchio unico per tutta l'Europa, il che comporta dei benefici considerevoli in termini di costi, perché costa meno registrare un marchio europeo rispetto al costo da sostenere per registrare un marchio internazionale per tutti gli Stati d'Europa. Tuttavia ha anche alcune possibili controindicazioni, il marchio è unico per tutta l'Europa, quindi nell'ipotesi in cui ci sia un motivo di nullità in uno qualsiasi degli Stati europei sarà nullo integralmente tutto il marchio, poiché è unico, quindi o è interamente valido o interamente nullo. Invece la procedura di registrazione internazionale dà luogo ad un fascio di marchi, quindi se poniamo che in uno soltanto degli Stati vi è una ragione di nullità sarà nullo soltanto il marchio relativo a quello stato, mentre invece rimarrà in piedi tutta l'altra parte del fascio.
- **Sistema nazionale italiano** → presso l'ufficio italiano brevetti e marchi. L'ordinamento italiano consente l'acquisto della protezione del marchio anche senza registrarlo, cioè solo **con l'uso**, il marchio che si acquista con l'uso ed è detto **marchio di fatto**. L'uso deve avere una **caratteristica** importante, **deve essere qualificato e deve comportare una notorietà non puramente locale**. La giurisprudenza considera non puramente locale una notorietà estesa su tutta la nazione e anche una notorietà estesa a più di una regione italiana. All'opposto è senz'altro puramente locale la notorietà estesa solo a una provincia.

Perché uno dovrebbe registrare un marchio con tutti i costi connessi alla registrazione quando si può acquistare anche semplicemente utilizzandolo?

Innanzitutto un motivo può essere che a volte c'è incertezza sulla valutazione relativa all'estensione non puramente locale della notorietà. Ma c'è un aspetto che riguarda **l'onere della prova in giudizio**, chi fa valere un marchio registrato non ha l'onere di dimostrare che il suo marchio sia valido.

Es. se l'imprenditore A è titolare di un marchio registrato e si accorge che l'imprenditore B sta utilizzando il medesimo marchio per i medesimi prodotti, può limitarsi a convenire in giudizio l'imprenditore B dimostrando di aver registrato il medesimo marchio che è stato utilizzato dall'imprenditore B. Poi sarà l'imprenditore B, se vuole dimostrare di non essere contraffattore, a dover dimostrare la prova della nullità del marchio registrato.

Quindi nei procedimenti di contraffazione relativi a marchi registrati è colui che è stato chiamato in giudizio, colui che non ha il marchio registrato ad avere l'onere di dimostrare che il marchio registrato è nullo.

Nel caso del marchio di fatto la situazione è capovolta, in questo caso è **colui che fa valere il marchio a dover dimostrare che sussistono tutti i requisiti di validità del marchio che fa valere**. Esiste una serie di requisiti che la legge richiede perché si possa acquistare un valido marchio, se non si riesce a dimostrare tutti i requisiti, o anche solo uno dei requisiti si perde la causa.

Innanzitutto c'è un primo **principio generale** che è quello secondo cui **il marchio deve essere estraneo al prodotto**. Il marchio non si può identificare con il prodotto, è necessaria una scindibilità concettuale tra il marchio e il prodotto su cui è apposto. Questo è un problema che si pone soltanto per i marchi di prodotto, nel caso dei marchi di servizi non è concepibile una sovrapposizione tra il marchio e il servizio.

Es. io imprenditore potrei essere tentato di registrare come marchio la forma di un prodotto che mi risolve un problema tecnico, come un ingranaggio meccanico fatto in un particolare modo, e potrei essere tentato di depositare una domanda di registrazione del marchio per il mio ingranaggio che ho inventato in modo da acquistare un diritto esclusivo senza passare per i requisiti di brevettabilità, ma questo naturalmente non si può fare perché difetterebbe l'estraneità del marchio dal prodotto.



La legge vuole che il marchio sia un modo per indicare la provenienza imprenditoriale di un prodotto, serve a dire qual è l'imprenditore che ha realizzato il prodotto.

L'ideale è che il marchio sia di fantasia rispetto al prodotto, **la ragione è l'inappropriabilità dei contenuti ideativi con lo strumento del marchio**, poiché l'appropriabilità dei contenuti ideativi è materia del brevetto o del diritto d'autore, se si tratta di idee espressive, non del marchio.



Art.13 del codice della proprietà industriale → il marchio deve anche avere capacità distintiva.

Questa regola serve ad eliminare dall'area dell'appropriabilità come marchio, in via generale, tutti quei segni che il pubblico non è abituato a percepire come indicazioni di provenienza. È il caso di segni che non siano sufficientemente riconoscibili, come un colore banale, il rosso; nel caso di colori invece molto particolari è possibile la registrazione come marchio.

Es. un segno che è stato ritenuto privo di capacità distintiva pochi anni fa sono le tre bande dell'adidas, peraltro anche non dotate di colori distintivi.

In questo articolo, accanto alla regola generale secondo cui non si possono acquistare marchi privi di capacità distintiva, troviamo anche delle **ipotesi puntuali relative a tipologie di segni che non possono essere registrati**, una di queste è relativa alle **denominazioni generiche o descrittive di prodotto**, qui abbiamo una specificazione della regola generale che richiede la capacità distintiva. È chiaro che il pubblico non è abituato a percepire il nome comune dell'oggetto come indicativo della sua provenienza imprenditoriale del prodotto. Nel caso delle denominazioni generiche o descrittive c'è anche **una ragione ulteriore** rispetto a quella generale, che impone la capacità distintiva, se per ipotesi permettessimo di **registrare il termine** computer, di acquistare un diritto di marchio per il termine computer avremmo il problema che nessuno potrebbe usare quella parola per descrivere il proprio prodotto, sarebbe in sostanza un effetto anti competitivo del diritto del marchio eccessivamente forte, ci sarebbe quindi uno sbilanciamento esagerato a favore del titolare del diritto di marchio, motivo per cui la legge vuole che le denominazioni generiche e descrittive possano essere utilizzate da tutti. La legge tuttavia non vieta in assoluto di includere in un marchio delle denominazioni generiche o descrittive, si può registrare un marchio che contenga anche una denominazione di questi tipi, quello che non si può fare è registrare un marchio che consiste esclusivamente in quella indicazione. I marchi che sono in parte costituiti da indicazioni generiche o descrittive sono talvolta detti **marchi espressivi**, cioè marchi che suggeriscono qualcosa delle qualità del prodotto, ma hanno anche una componente distintiva, sono detti espressivi perché esprimono e comunicano dati relativi al prodotto senza fare solo quello.

Es. catena di torrefazione "**caffex**" → l'aggiunta della X è sufficiente a rendere il marchio dotato di capacità distintiva, poi bisogna tenere presente che **la parte**

tutelata del marchio sarà solo quella distintiva, non ci si deve lamentare se altri usano la parola caffè.



Art. 13 → prevede che ***non possono essere acquistati o registrati i diritti di marchio sui segni costituiti esclusivamente da indicazioni geografiche.***

Anche qui si osserva che il consumatore non è abituato a percepire come indicazione di provenienza imprenditoriale l'indicazione relativa alla provenienza geografica, in un luogo geografico possono esserci tanti imprenditori che realizzano legittimamente i medesimi prodotti. Accanto a questa osservazione ritroviamo anche la ratio costituita dall'esigenza di non permettere a un singolo soggetto di appropriarsi di segni che devono poter essere utilizzati anche da altri concorrenti.

Es. immaginiamo che si possa registrare la parola Biella per filati di lana, è chiaro che ci sarebbe una posizione di vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti che deriverebbe dal fatto che la zona del biellese è una zona largamente nota per la produzione di lane pregiate e se si avesse un monopolio sull'uso del termine Biella come marchio si potrebbe impedire ai concorrenti biellesi di avvalersi nella loro comunicazione d'impresa dell'importante comunicazione della provenienza del loro prodotto. Se invece si registra il nome Zara per abbigliamento, in questo caso non ci sarebbe eccessiva carica anti competitiva o concorrenziale del marchio, Zara è una città di mare della Dalmazia che non ha alcun legame con la produzione di capi d'abbigliamento, quindi non c'è nessuna ragione per impedire a un produttore industriale di capi d'abbigliamento di utilizzare il nome Zara per indicare la provenienza del suo prodotto. In questo caso non vi è neanche il problema dell'assenza di capacità distintiva, poiché il pubblico non associa il nome Zara a un particolare produttore di abbigliamento, che avrebbe invece nel caso di Biella.

Dagli esempi fatti possiamo comprendere perché la legge non si limita a dire che non sono registrabili i segni costituiti da indicazioni geografiche, innanzitutto la legge dice, relativamente alle denominazioni generiche o descrittive, che il divieto di registrazione concerne soltanto i segni costituiti esclusivamente dall'indicazione di provenienza geografica; ma poi si aggiunge anche che il divieto opera soltanto quando la denominazione geografica è riconducibile a particolari qualità del prodotto. Quindi la regola opera senz'altro per l'esempio del marchio Biella, e non per l'esempio del marchio Zara.



Non può essere acquistato il diritto esclusivo di marchio sui segni divenuti di uso comune.

Occorre porre l'accento sul termine "divenuti", qui la legge allude a una perdita di capacità distintiva di un segno dovuta a un uso massiccio che ne è stato fatto nelle prassi del commercio.

Es. la corona d'alloro, il leone, l'aquila...sono simboli usati più o meno in tutti i campi del commercio.

Questi impedimenti alla registrazione relativi alla capacità distintiva, quindi generale assenza di capacità distintiva, denominazioni generiche o descrittive, indicazioni geografiche e segni divenuti di uso comune, **sono sanabili**. Può accadere che un segno che non aveva capacità distintiva la acquisti, sono segni che hanno acquistato un secondo significato accanto a quello descrittivo vi è quello distintivo, si parla allora di **Secondary Meaning**.

Es. si pensi al giornale nel momento in cui si fondò "Il Giornale" il pubblico percepiva il giornale come una comunicazione descrittiva, oppure "Scarpa" che è un marchio di prodotti di calzature tecniche di montagna, eppure oggi chi pensa a "Il Giornale" capisce subito che ci si riferisce a quel prodotto giornalistico, stessa cosa al segno distintivo "Scarpa", sono segni che attraverso un uso consistente e anche grazie ad una forte pubblicità da parte di un solo imprenditore sono passati dall'essere dei segni puramente descrittivi ad essere invece percepiti come delle indicazioni di provenienza,

L'acquisto di un secondary meaning sana l'iniziale difetto di capacità distintiva. Può succedere anche il contrario e cioè si ha la **volgarizzazione del marchio**, un marchio che inizialmente è dotato di capacità distintiva la perde.

Es. si pensi alla pellicola impermeabile cellofan, era un marchio registrato ma è stato utilizzato talmente tanto come sinonimo del prodotto che nella percezione collettiva è passato come prodotto stesso.

La conseguenza della volgarizzazione è che il marchio decade e il titolare perde il diritto.

Come si fa a vedere se un marchio si è volgarizzato?

Si possono fare interviste a tante persone per vedere come percepiscono il marchio, altrimenti si ricorre ad altri indizi, uno dei quali è la presenza della parola, se si tratta

di marchi denominativi, nei vocabolari, in cui si trovano i nomi comuni, e se si trova anche un marchio registrato vuol dire che quello è diventato un'indicazione generica. Il **ricorso al dizionario** è diventato talmente diffuso che la legge prevede espressamente che il titolare del diritto di marchio può pretendere dall'editore di dizionari che sia inserita la precisazione che si tratta di un marchio registrato. Il fenomeno della volgarizzazione si realizza frequentemente relativamente ai prodotti brevettati, poiché il brevetto conferisce un monopolio sulla realizzazione del prodotto, soltanto un imprenditore può realizzare il prodotto dunque egli metterà il suo marchio sul prodotto e quindi in sostanza avviene un'associazione tra il marchio e il prodotto, come avvenuto per cellofan.

| *Come si evita la volgarizzazione ?*

Un modo per evitare la volgarizzazione del proprio marchio è fare tanta pubblicità, in cui si tiene ben distinto il marchio dalla tipologia di prodotto.

Es. se il titolare del marchio cellofan avesse voluto evitare la volgarizzazione, avrebbe potuto fare campagne pubblicitarie in cui diceva "cellofan la prima pellicola impermeabile" o diciture simili che facciamo capire al consumatore che quello contraddistinto dal marchio non è l'unico prodotto di quella tipologia.

Inoltre ci sono altri impedimenti alla registrazione, altro requisito, che sono costituiti ad esempio dalla **decettività, cioè il marchio non deve essere ingannevole**. Questo requisito fa riferimento specialmente al marchio registrato, è rara l'applicazione ai marchi di fatto, la ragione la si vede se si chiede come viene valutato questo requisito. Si ritiene che il marchio sia decettivo, ingannevole, soltanto quando c'è incompatibilità tra il significato del marchio e i prodotti o i servizi per cui il titolare ha chiesto di essere protetto.

Es. il marchio cotonelle per la carta igienica, questo marchio suggerisce che il prodotto sia fatto almeno in parte di cotone, componente che è totalmente assente in un prodotto cartaceo, c'è incompatibilità ontologica tra il nome del marchio e il prodotto.

Questo criterio di valutazione chiarisce il perché sia un impedimento che riguarda prettamente i marchi registrati. Soltanto per il marchio registrato c'è una domanda di protezione e quindi un'indicazione di alcuni settori in cui il titolare desidera essere protetto, nel marchio di fatto non vi è alcuna domanda di registrazione, non vi è nemmeno un elenco di settori in cui è richiesta protezione. Un altro impedimento è costituito col **conflitto con diritti anteriori di terzi**, non si può registrare come marchio un'opera dell'ingegno altrui, il nome di un'altra persona senza

l'autorizzazione, non si può registrare un segno distintivo che appartiene ad altri. Si possono verificare tre tipi di conflitto :

- Nel primo caso, il secondo marchio è identico a quello precedente e se ne chiede la registrazione per prodotti e servizi identici, hanno uguale **identità**. In questo caso il secondo marchio non può essere registrato
- C'è **un'affinità**, una semplice somiglianza tra prodotti o servizi. In questo caso il secondo marchio è comunque registrabile se non c'è rischio che il consumatore si confonda. Invece se c'è il pericolo che il consumatore pensi che il prodotto su cui è apposto il secondo marchio provenga dall'imprenditore titolare del primo marchio allora sussiste impedimento, vi è impedimento solo se c'è confondibilità, per verificare ciò, si guarda ai requisiti di confondibilità della concorrenza sleale.
- La terza ipotesi di conflitto riguarda quei prodotti identici o simili o anche non affini, e opera anche se non c'è il rischio di confusione purché il primo marchio sia notoriamente conosciuto, cioè è un marchio dotato di notevole notorietà, e vi è un rischio di approfittamento della notorietà.

Es. assumiamo che il marchio Ferrari sia registrato solo per automobili, comunque non si può acquistare un diritto sul medesimo marchio Ferrari nemmeno per prodotti particolarmente distinti, o se vi è rischio di approfittarsi della notorietà del marchio.

Tutte queste ipotesi corrispondono anche a fattispecie in cui è vietato l'uso del marchio registrato, cioè non solo non si può registrare il secondo marchio, ma non si può neanche usare perché usarlo viola il diritto di marchio del titolare, questi oltre ad essere impedimenti sono anche ipotesi di contraffazione.

| Quando finisce il diritto di marchio?

Il diritto di marchio dura per 10 anni dal deposito della domanda, è rinnovabile indefinitamente e decade se non lo si usa per 5 anni, come in materia di brevetto vi è un onere di usare la creazione.



Decettività sopravvenuta → acquisto il marchio di un imprenditore che garantiva uno standard qualitativo elevato, ma invece produco qualcosa di bassissimo livello, se questo cambio di proprietà del marchio viene comunicato al pubblico di riferimento non vi è nessun problema, in caso contrario il marchio decade.

